

**FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO
FGV DIREITO RIO**

PEDRO HENRIQUE CHRISTOFARO LOPES

**ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS: O *PERFORMANCE BOND* EM CONTRATOS DE
OBRAS PÚBLICAS COMO INSTRUMENTO PARA MITIGAR A
ASSIMETRIA DE INFORMAÇÕES**

RIO DE JANEIRO

2019

PEDRO HENRIQUE CHRISTOFARO LOPES

**ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS: O *PERFORMANCE BOND* EM CONTRATOS DE OBRAS
PÚBLICAS COMO INSTRUMENTO PARA MITIGAR A ASSIMETRIA DE
INFORMAÇÕES**

Dissertação apresentada à Escola de Direito
do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio
Vargas para obtenção de grau de mestre.

Área de Concentração: Direito da Regulação.

Linha de Pesquisa: Economia, Intervenção e
Estratégias Regulatórias.

Orientador: Prof. Dr. Antônio José
Maristrello Porto.

O presente trabalho foi realizado com apoio
financeiro da Fundação Getúlio Vargas.

O presente trabalho foi realizado com apoio
da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) -
Código de Financiamento 001.

Rio de Janeiro

2019

Lopes, Pedro Henrique Christofaro

Análise econômica do direito e contratações públicas: o performance bond em contratos de obras públicas como instrumento para mitigar a assimetria de informações / Pedro Henrique Christofaro Lopes. – 2019. 147 f.

Dissertação (mestrado) - Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas.

Orientador: Antônio José Maristrello Porto.

Inclui bibliografia.

1. Contratos administrativos. 2. Obras públicas. 3. Performance (Direito). 4. Seguros. 5. Garantia (Direito). I. Porto, Antônio José Maristrello. II. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas. III. Título.

CDD – 341.3526

Elaborada por Maria do Socorro Almeida – CRB-7/4254

PEDRO HENRIQUE CHRISTOFARO LOPES

“ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS: UM ESTUDO SOBRE O USO DO PERFORMANCE BOND EM CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS”.

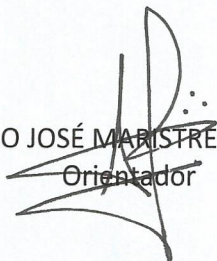
Dissertação apresentado(a) ao Curso de Mestrado Acadêmico em Direito da Regulação do(a) Escola de Direito do Rio de Janeiro para obtenção do grau de Mestre(a) em Direito da Regulação.

Data da defesa: 23/01/2020

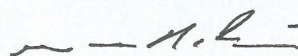
ASSINATURA DOS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA

Presidente da Comissão Examinadora: Profº ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO

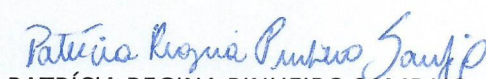
ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO
Orientador



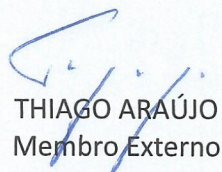
MARCOS NÓBREGA
Membro Externo



PATRÍCIA REGINA PINHEIRO SAMPAIO
Membro Interno



THIAGO ARAÚJO
Membro Externo



A Maria Clara Paiva Teles
(in memoriam)

Agradecimentos

Galadriel: Mithrandir, why the halfling? Gandalf: I do not know. Saruman believes that it is only great power that can hold evil in check, but that is not what I've found. I've found it is the small things, everyday deeds of ordinary folk that keeps the darkness at bay; simple acts of kindness and love. Why Bilbo Baggins? Perhaps it is because I am afraid, and he gives me courage.

Diálogo entre Gandalf e Galadriel em “The Hobbit: An Unexpected Journey”

Para aqueles de paciência mais curta, pode ser que esses agradecimentos sejam muito longos. Talvez sejam, de fato. São poucas as oportunidades que temos de agradecer, por isso devem ser aproveitadas.

Escrever uma dissertação é, essencialmente, um trabalho solitário. Por mais que haja diálogo com professores, colegas e amigos, são meras intermitências em um trabalho que, no fim do dia, só pode ser feito por você. Existe, porém, uma diferença entre solidão e solitude. A primeira está ligada a um sentimento de abandono e desconexão, enquanto a segunda denota a sua capacidade de se sentir bem consigo mesmo quando apenas na sua companhia. Se eu consegui superar os momentos de solidão e transformá-la em solitude, ao longo de todo esse percurso, foi graças à participação de cada um dos aqui mencionados, aos quais passo a agradecer.

Em primeiro lugar, a Deus, Nsa. Senhora e meus santos de devoção. Existem momentos que apenas o apego ao transcendente nos permite superar nossas adversidades e o “demônio que devasta ao meio-dia”.

Aos meus pais, por todo apoio material e emocional. Sei que fui mais amargo que o meu costume nos últimos dois anos, mas agora deve melhorar, eu acho. A minha irmã, que não perde seu dom peculiar, e pouco útil (e talvez por isso mereça ser valorizado), de levar alegria às pessoas, mesmo que temperada por doses elevadas de “folga”.

A Aline (Lines), que acredita mais em mim que eu mesmo, por ter tirado vários cochilos que me permitiram trabalhar com mais tranquilidade e ter a capacidade de me trazer confiança que sozinho não conseguiria ter.

Aos meus amigos, de modo especial aos da 201: Rodrigo (companhia constante nos corredores da FGV), Manu, Massami, Mari, Isaac, Dani, Nath, Saulo, Deb, Fabinho, Isa entre outros. Aos meus colegas de treino na Escola de Kung Fu, e ao Sifu

Leonardo, por serem sempre um bom momento da minha semana. Aos amigos da Secretaria que teve vários nomes enquanto eu fiz parte dela: Vitor, Daniel, Marcones, Renan, Isabel, Patrícia, Camille, Yasmin, Dra. Ana, Dra. Cristiane, Dr. Marcelo entre outros. Aos amigos da PGE, tanto da época do estágio quanto da residência, de maneira especial a Patrícia, Dri, Camila, André, Fernanda, Danilo, Dr. Guilherme (quem me deu uma das cartas de recomendação que me permitiram entrar no mestrado), entre outros com quem tive a alegria de trabalhar.

À Dna. Ieda, por tão bem ter me recebido em sua casa e por todo carinho ao longo desse ano e meio de convivência.

Aos meus colegas de turma da FGV (inclusive das turmas anteriores e posteriores), por todas as discussões valiosas durante as aulas e todo o apoio mútuo fora delas.

De maneira institucional à Fundação Getúlio Vargas, que acreditou em mim e me deu a oportunidade de cursar o mestrado. Agradeço, ainda, aos seus funcionários, de forma especial à Jaqueline Nobre e Thais Gouveia, por toda disponibilidade e presteza em resolver praticamente tudo.

Aos meus professores, de maneira especial ao meu orientador o Professor Porto, por todo o auxílio durante a elaboração desta dissertação e em todos os assuntos acadêmicos, sou muito grato por toda generosidade oferecida ao longo desses dois anos de mestrado. Ao professor Thiago Araújo, por todo o auxílio acadêmico determinante para esta dissertação sair. À professora Patrícia Sampaio por ter aceitado fazer parte da minha banca e pelas valiosas críticas fornecidas na banca de qualificação. Tudo de bom que sair dessa dissertação certamente tem um toque de todos esses professores. Por fim, ao professor Marcos Nóbrega, por ter aceitado fazer parte da minha banca.

A todos o meu mais sincero obrigado pelos seus pequenos atos cotidianos de gentileza e carinho que me ajudarem a tornar essa dissertação possível.

Do or do not, there is no try.

Mestre Yoda

If one day you make it back to the west, what will you tell man of these strange words “Kung fu” Will you tell them it means “to fight” or will you say, like a monk from shaolin, “to summon the spirit of the crane and the tiger” “Kung fu”. It means, “supreme skill from hard work.” A great poet has reached kung fu. The painter, the calligrapher, they can be said to have kung fu. Even the cook, the one who sweeps steps or a masterful servant can have kung fu. Practice. Preparation. Endless repetition. Until your mind is weary, and your bones ache. Until you’re too tired to sweat, too wasted to breathe. That is the way, the only way one acquires kung fu.

Hundred Eyes.

RESUMO: O tema das contratações públicas é muito trabalhado no Direito Administrativo brasileiro. Todavia, a literatura especializada dedica poucos esforços para realizar uma análise do tema sob a perspectiva econômica. Com isso em mente, a presente dissertação busca realizar uma análise econômica dos contratos de obras públicas, buscando compreender quais as causas do elevado percentual de obras paralisadas, e eventualmente abandonadas pelo Brasil. Diagnosticado o problema, busca-se no seguro garantia na modalidade garantia de cumprimento de obrigação contratual (performance bond), um instrumento para endereçar tal problema no ordenamento jurídico, tendo em vista o seu sucesso no ordenamento jurídico americano. Para tanto, faz-se a análise de sua natureza jurídica e mecânica de funcionamento. No capítulo final, há análise dos possíveis benefícios da aplicação do performance bond nos contratos de obras públicas no Brasil, sem contudo se deixar de realizar um estudo sobre as eventuais dificuldades de sua implantação. Por fim, realiza-se uma breve análise das mudanças propostas para o instituto no PL 1.292/1995, em tramitação no Congresso Nacional;

Palavras-Chave: Análise Econômica do Direito. Contratos de Obras Públicas. Performance Bond. Seguro Garantia. Normas jurídicas como incentivos.

ABSTRACT: The subject of public procurement is much worked by the Brazilian Administrative Law. However, the specialized literature makes little effort to analyze the subject from an economic perspective. With this in mind, this dissertation seeks to perform an economic analysis of public works contracts, aiming to understand the causes of the high percentage of works paralyzed, and eventually abandoned throughout Brazil. Having diagnosed the causes of the problem, we seek in the performance bond, an instrument to address such problem in the legal system, due to its success in the American legal system. To this end, it will be done an analysis of its legal nature and how it can be operated in the administrative practice. In the final chapter, there is an analysis of the possible benefits of applying the performance bond in public works contracts in Brazil, but without forgetting to study the possible difficulties of its implementation. Finally, there is a brief analysis of the proposed changes to the institute in PL 1,292 / 1995, being processed in the National Congress.

Keywords: Law and Economics; Public Procurement; Performance Bond; Legal rules as incentives.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	12
2. CAPÍTULO 1: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E O SISTEMA BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	17
2.1. Teoria Econômica dos Contratos	17
2.2. Análise Econômica dos Contratos Públicos.	24
2.2.1. Eficiência em Contratos Administrativos.....	32
2.2.2. Custos de Transação em Contratos Administrativos.	34
2.3. Sistema Brasileiro de Contratações de obras públicas.....	37
2.3.1. O problema das obras públicas no Brasil.....	37
2.3.2. A Lei 8.666/93 e a Captura do seu Processo Legislativo.	42
2.3.3. No Regime Diferenciado de Contratação (RDC).....	50
2.3.4. Um Balanço do Sistema: Falhas de Mercado no Sistema de Contratação de Obras Públicas.	54
2.3.4.1. Assimetria de informação	55
2.3.4.2. Problema de Hold Up da Administração (ou Administração Refém)	59
2.3.4.3. Problema de Agência	62
2.3.4.4. Maldição do Vencedor.....	63
3. CAPÍTULO 2: Estudo sobre o Performance Bond	65
3.1. Conceito.	65
3.2. Natureza Jurídica.	69
3.3. Finalidade e Funcionamento.....	77
3.4. Como é regulado no Brasil.....	83
3.5. Mercado Brasileiro de Seguro Garantia.....	91
4. CAPÍTULO 3: Análise do uso de Performance Bond nos contratos públicos....	94
4.1. A Utilização do Seguro Garantia de Execução (<i>Performance Bond</i>) em obras públicas no Direito Estrangeiro.	94
4.1.1. Estados Unidos (EUA).....	98
4.2. Institutos Semelhantes Aplicáveis em Obras Públicas.....	104
4.2.1. Responsabilidade Ambiental do Financiador de Projetos.	104
4.2.2. Acordos Trilaterais da ARTESP.....	107
4.3. Benefícios Esperados pela ampliação do <i>Performance Bond</i>	111
4.3.1. Quanto ao Incentivo à Conclusão de Obras Públicas por meio da Cooperação entre as Partes.	112
4.3.1.1. Monitoramento e Assimetria de informações.	115

4.3.1.1.1. Combate ao Risco Moral (<i>Moral Hazard</i>) e à seleção adversa.....	118
4.3.1.2. Continuidade do Projeto e Menor Custo de Substituição do Contratado.	119
4.3.2. Quanto ao Combate à Corrupção	120
4.4. Dificuldades à Implantação.	124
4.4.1. Insuficiência do Mercado.....	124
4.4.2. Capacidade Regulatória da SUSEP.	125
4.4.3. Prejuízo à Concorrência (competitividade) na Licitação.....	127
4.5. Comentários sobre o Projeto de Lei n.º 1292/1995.	128
5. CONCLUSÃO.....	132
6. REFERÊNCIAS.....	135

1. INTRODUÇÃO

O sistema de compras públicas no Brasil, apesar de várias reformas recentes que melhoraram a sua capacidade de obter bens e serviços no mercado a preços mais favoráveis para a Administração¹, ainda se mostra muito ineficiente e burocratizado.²

O problema de compras públicas ineficientes se revela ainda mais preocupante quando se percebe elevado percentual do PIB brasileiro passando pelo Estado³. Ou seja, o poder de comprar estatal responde por uma parte muito significativa da economia nacional.

A gravidade da questão é acentuada quando se observa a atual realidade das obras públicas. Nesse sentido, é comum ver uma grande quantidade de obras públicas inacabadas ou muito atrasadas⁴. Tal fato é um indicativo de que tanto o sistema de seleção de parceiros privados em contratos de empreitadas, per si, é pouco eficiente, bem como seus mecanismos para lidar com o inadimplemento, total ou parcial. Ou, ainda, o problema pode estar no parceiro público, incapaz de atrair bons parceiros, seja

¹ Entre as quais se pode citar: A criação do Pregão (Lei n.º 10.520/2002, a partir da conversão da Medida Provisória n.º 2.026/2000), recentemente regulamentado pelo Decreto n.º 10.024/2019; das Parcerias Público-Privadas (Lei n.º 11.079/2004); do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (criado pela Lei n.º 12.462/2011 e ampliado pelas Leis n.º 12.688/2002; n.º 12.722/2012; n.º 12.745/2012; n.º 12.815/2013; n.º 12.833/2013; n.º 12.873/2013; n.º 12.980/2014; 12.983/2014; n.º 13.190/2015; n.º 13.243/2016), e as normatizações relativas aos Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI) e Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada (MIP).

² Nesse sentido: “Creio que a maioria das ineficiências advém da modelagem inadequada das licitações que prioriza o procedimento em vez da eficiência. Há um emaranhado de regras que aumentam em demasia o custo de transação e não levam a canto algum. Os Tribunais, por sua vez, se enredam em debates bizantinos sobre esse ou aquele dispositivo, muito pouco contribuindo para o debate. Ademais, qualquer modificação proposta fitando aumentar a eficiência do sistema é obstaculizada pelo apego aos princípios da Administração Pública, cristalizados como dogmas pelos doutrinadores brasileiros e empecilhos para uma discussão mais técnica sobre licitações no país”. NÓBREGA, Marcos. Novos Marcos Teóricos em Licitação no Brasil: Olhar para além do sistema jurídico. **Revista Eletrônica de Direito do Estado – REDE**. N.º 30, abril/maio/junho de 2012, Salvador, Brasil. p. 20. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/artigo/marcos-nobrega/novos-marcos-teoricos-em-licitacao-no-brasil-olhar-para-alem-do-sistema-juridico>; Acesso em 11 de dezembro de 2019.

³ No Brasil, investimento do setor público equivale a 12,7% de todo o PIB. OECD (2019), Investment by sector (indicator). doi: 10.1787/abd72f11-en (Accessed on 07 January 2019)

⁴ A título de exemplos citam-se as seguintes matérias jornalísticas; SANTOS, Altair. **Brasil tem mais de 20 mil obras públicas inacabadas** <https://www.cimentoitambe.com.br/brasil-obras-publicas-inacabadas/> (acesso em 22/05/2019); ALVES, Murilo Rodrigues; BORGES, André; MERGULHÃO, Alfredo. **Das dez maiores obras do primeiro PAC, apenas duas foram concluídas**. Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-noticia,1824792> (Acesso em 22/05/2019).

BRASIL. Tribunal de Contas da União. TC 011.196/2018-1. **Diagnóstico das obras paralisadas. Identificação das principais causas e das oportunidades de melhoria. Recomendações. Monitoramento**. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2019/05/011.196-2018-1-VR-diagnostico-de-obras-paralisadas.pdf> Acesso em: 17 de outubro de 2019.

por conta do processo seletivo não ser adequado para a produção de um cenário verdadeiramente competitivo, ou pela sua pouca confiabilidade como parte contratual.⁵

Com isso em mente, apresenta-se a seguinte pergunta de pesquisa: como a utilização do Seguro Garantia, na espécie de garantia de execução (*performance bond*), pode ser um instrumento para gerar incentivos ao adimplemento de contratos de obras públicas?

A hipótese inicial de pesquisa é que o *performance bond*, o seguro garantia na espécie garantia de cumprimento de obrigação, é um mecanismo contratual apto a incentivar a execução adequada, e o consequente adimplemento, nos contratos de obras públicas, a partir do alinhamento dos incentivos dos polos contratuais, contribuindo, ainda, para dificultar práticas de corrupção.

Quanto ao possível aumento dos custos financeiros para a efetivação da contratação, acredita-se que a majoração, quando houver, não será proporcional aos benefícios gerados. Com isso, o saldo positivo, justifica a utilização de mecanismos securitários em contratos administrativos.

O objetivo central desta dissertação, portanto, é analisar quais as possíveis vantagens, desvantagens e custos da ampliação do uso do mecanismo de seguro garantia de cumprimento de obrigação (*performance bond*)⁶ no bojo dos contratos de obras públicas, bem como as possíveis dificuldades a serem enfrentadas para a sua efetivação.

Esta pesquisa se justifica, do ponto de vista científico, em razão da pouca produção bibliográfica relacionada ao tema das garantias em contratos público a partir de uma perspectiva da teoria econômica dos contratos, isto é, para além da mera análise de previsões normativas sobre a questão. Da ótica social, por sua vez, a presente dissertação busca analisar as causas e estudar uma possível solução para o problema dos constantes atrasos e paralisações nas obras públicas, o que, como se verá em capítulo dedicado ao tema, causa prejuízos diretos e indiretos à população, tanto no aspecto financeiro quanto no social. Outra questão que amplia a relevância do tema e

⁵ Por exemplo, o Estado possui a sua disposição as cláusulas exorbitantes, mas a sua utilização não vem gerado maior adimplemento, seja por motivos da própria estrutura normativa das cláusulas, seja por problemas relativos a sua aplicação. FREITAS Rafael Veras de, **Análise Econômica das Contratações Públicas**. S. N. T. p. 4. Disponível em: <https://www.compraspublicasbrasil.gov.br/portal/pdf/2018-05-22 - Análise Economica das Contratações Públicas.pdf>; Acesso em 13 de outubro de 2019.

⁶ Na presente dissertação, para evitar constantes repetições, tais expressões serão tratadas como sinônimas.

justifica a presente pesquisa é a circulação, no Congresso Nacional do Projeto de Lei n.º 1.292/1995

Para cumprir o objetivo apresentado e responder à pergunta de pesquisa proposta, utiliza-se a Análise Econômica do Direito (AED)⁷ como método de estudo, por meio da aplicação do ferramental teórico e metodológico da economia à teoria jurídica.

Não se trata da utilização da análise econômica como objeto específico de estudo, mas sim da aplicação do método econômico para a investigação do problema de pesquisa. A abordagem a partir do instrumental da economia presta-se a analisar qualquer espécie de escolha humana, tanto em nível individual quanto coletivo, seja no âmbito diretamente do mercado ou não. A AED, portanto, é a aplicação da análise econômica como método para a compreensão, explicação e previsão de efeitos dentro do ordenamento jurídico⁸⁻⁹.

Com isso, o propósito da AED é compreender quais os efeitos das normas jurídicas sobre as decisões dos agentes, e, ainda, se tais efeitos podem ser considerados socialmente desejáveis. Como consequência, quando se utiliza a AED como método de estudo, deve-se questionar se as políticas públicas, leis, normas administrativas ou

⁷ Embora seja possível pensar de formas diferentes, nessa lógica: “num plano fenomenológico, a AED pode se apresentar sob três formas: método, teoria e ideologia, em construção haurida de Norberto Bobbio.”. ARAÚJO, Thiago Cardoso. **Análise Econômica do Direito no Brasil. Uma leitura à luz da teoria dos sistemas**. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2017. p. 325.

⁸ Assim, quando se fala em análise econômica, não se faz referência a um objeto de estudo específico (e.g. mercado, dinheiro, lucro), mas ao método de investigação aplicado ao problema, o método econômico, cujo objeto pode ser qualquer questão que envolva escolhas humanas (e.g. litigar ou fazer acordo, celebrar ou não um contrato, poluir ou não poluir). Assim, a abordagem econômica serve para compreender toda e qualquer decisão individual ou coletiva que verse sobre recursos escassos, seja ela tomada no âmbito de mercado ou não. Toda atividade humana relevante, nessa concepção, é passível de análise econômica. A Análise Econômica do Direito, portanto, nada mais é que a aplicação desse método para se tentar compreender, explicar e prever as implicações fáticas do ordenamento jurídico, bem como da lógica (racionalidade) do próprio ordenamento jurídico. A AED é a utilização da abordagem econômica para tentar compreender o direito no mundo e o mundo no direito. GICO JR., Ivo. Introdução à Análise Econômica do Direito. In: RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; KLEIN, Vinicius (coord.). **O que é Análise Econômica do Direito: Uma Introdução**. 2ª Edição. Belo Horizonte, Editora Fórum, 2016, Pp. 19-20.

⁹ Thiago Araújo, por sua vez, vê a AED como um método mais capaz de conferir cientificidade ao Direito, nesse sentido: “A AED então, teria o condão de funcionar como um conjunto de ferramentas a serem apropriadas pelo Direito, mas também, numa leitura epistemológica, como uma nova teoria abrangente do Direito, apta a explicar racionalidade intrínseca às regras jurídicas.” ARAÚJO, Thiago Cardoso. **Análise Econômica do Direito no Brasil. Uma leitura à luz da teoria dos sistemas**. Op. Cit.. p. 12.

decisões judiciais em estudo são capazes de gerar os incentivos “adequados” para as pessoas tomarem decisões desejáveis para a coletividade.¹⁰

Esclarecido o método de trabalho, passa-se a estrutura adotada nesta dissertação. Para endereçar a presente pergunta de pesquisa e avaliar sua respectiva hipótese, dividiu-se o presente trabalho em três capítulos.

No capítulo inicial, serão apresentadas as bases da aplicação da Análise Econômica do Direito aos contratos de obras públicas, a partir da exposição dos conceitos básicos da AED contratual já aplicados ao tal contexto. Para dar concretude à parte abstrata da disciplina, será feita a análise do atual sistema brasileiro de contratação de execução de obras públicas à luz da teoria econômica apresentada. Nesse ponto, serão analisadas as principais normas relacionadas com o tema, quais sejam, a Lei n.º 8.666/1993 e a Legislação relacionada com o Regime Diferenciado de Contratações (RDC).

Neste ponto, serão destacados os motivos pelos quais as compras públicas devem ser pensadas para além de mero processo administrativo, e sim como verdadeira técnica de seleção de um parceiro privado adequado para a Administração.¹¹

Na conclusão do capítulo inicial, serão apresentadas as principais falhas de mercado (e de governo) que se manifestam na atual normativa das contratações de obras públicas, buscando suas origens, especialmente, num sistema normativo muito preocupado com formalismos procedimentais e pouco concentrado em resultados.

O segundo capítulo é dedicado à explicação do Seguro Garantia, especialmente a sua modalidade de garantia de execução de obrigação contratual (*performance bond*), mostrando-se, ainda, como ele pode ser aplicado aos contratos de obras

¹⁰¹⁰ TABAK, Benjamin Miranda. **A Análise Econômica do Direito: Proposições Legislativas e Políticas Públicas**. Núcleos de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa. Texto para discussão 157. Outubro de 2014. p. 5 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td157> Acesso em 05 de novembro de 2019.

¹¹ Nesse sentido: “Procurement design and management is a complex issue though, as contractual problems directly interact with competitive screening and risk management problems. Moreover, procurement is most often a dynamic, repeated activity, with short-term objectives often conflicting with longterm ones. Strategic procurement decisions must be taken with a focus on the future dynamics of the demand–supply relationship. Neglecting the importance of repeated relationships with potential suppliers and the effects of procurement choices on an industry or a district dynamic could have very undesirable consequences for a large buyer, in terms of both price and quality. This dynamic distinguishing feature of procurement also greatly enlarges the role for reputational forces.” DIMITRI, Nicola; PIGA, Gustavo; SPAGNOLO, Giancarlo. Introduction. In: **Handbook of Procurement**. Edited By Nicola Dimitri; Gustavo Piga; Giancarlo Spagnolo. Cambridge University Press. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo. 2006. p. 3.

públicas. Nesse sentido, será explicado quais efeitos benéficos o seguro é capaz de gerar no sistema de incentivos internos à dinâmica contratual, para além de sua função primária de garantia da execução da obra relevante para os cidadãos dentro do prazo estipulado. Ao final deste segmento, será exposto um breve panorama da situação do mercado brasileiro de seguro garantia e sua evolução nos últimos anos.

No capítulo final, haverá a aplicação das premissas estabelecidas nos tópicos anteriores para determinar como a utilização do *performance bond* em contratos de obras públicas pode contribuir não apenas para o incentivo da execução contratual, como também no combate à corrupção nos contratos envolvendo o Estado, e na melhora no próprio método de seleção do contratante. Com isso, os principais possíveis benefícios do instituto serão analisados, sem, todavia, esquecer quais os desafios devem ser superados para a utilização efetiva dos seguros em contratos públicos. Por fim, serão realizados breves comentários em relação às inovações propostas pelo PL 1.292/1995, ainda em tramitação no Congresso Nacional, o qual amplia a aplicação do *performance bond* no Brasil.

Ao final, na síntese conclusiva, a pergunta de pesquisa será revisitada, assim como se verificará a adequação da hipótese de trabalho inicial aos resultados da pesquisa, a partir das ideias discutidas ao longo da dissertação.

2. CAPÍTULO 1: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E O SISTEMA BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

2.1. Teoria Econômica dos Contratos

Um campo rico para a aplicação e crescimento da Análise Econômica do Direito sempre foi o direito contratual. Isso porque a realização de contratos “aumenta a riqueza e a utilidade de seu objeto”¹². A realização de trocas voluntárias, juridicamente instrumentalizadas pelos contratos, aumenta a riqueza e o bem estar da sociedade. Portanto, um objetivo da economia, e, por decorrência, da AED, é facilitar a formação e execução de contratos entre agentes dentro do mercado.

Do ponto de vista econômico, o contrato permite que os bens se desloquem para novos titulares que valorizam mais tais bens em comparação com os antigos, aumentando seus valores subjetivos (o que gera aumento de riqueza).¹³

Já na perspectiva jurídica, um contrato pode ser entendido como “um conceito jurídico que exprime uma realidade econômica subjacente, superior a si própria, uma realidade de interesses, de relações, de situações econômicas, em relação aos quais cumpre uma função instrumental.”¹⁴.

Para esclarecer, pense na compra e venda de uma maçã. O comprador analisa a fruta e conclui que está disposto a pagar até R\$ 3,00 por ela, já para o vendedor, aquela maçã vale R\$ 2,00, dessa maneira, vendê-la, a partir desse valor lhe traria benefícios. Supondo que a venda seja concretizada no preço de R\$ 2,50. Nesse cenário, o vendedor lucra R\$ 0,50, enquanto o comprador gasta R\$ 2,50 para obter um bem cuja utilidade fornecida é de R 3,00, tendo, portanto, um benefício líquido de R\$ 0,50. Com isso, essa transação simples deixou a sociedade como um todo R\$ 1,00 mais rica (somando-se o benefício das duas partes).¹⁵ O contrato seria apenas um recurso jurídico para instrumentalizar essa relação econômica.

¹² KLOH, Gustavo, Teoria Econômica da Propriedade e dos Contratos” In: **Direito e Economia Diálogos**. (Coord) Armando Castelar Pinheiro; Antônio José Maristrello Porto; Patrícia Regina Pinehiro Sampaio. Rio de Janeiro, FGV Editora, 2019. p. 306.

¹³ “In economic parlance, the contract has allowed resources to move to higher valued uses”. MACKAAY, Ejan. **Law and Economics for Civil Law Systems**. Edward Elgar Publishing. Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA. 2013. p. 413.

¹⁴ BURANELLO, Renato Macedo. **Do Contrato de Seguro: O seguro garantia de obrigações contratuais**. Editora Quartier Latin do Brasil. São Paulo, 2006. p. 79.

¹⁵ Exemplo adaptado de: idem,

Naturalmente, as questões são mais complicadas na realidade. Com frequência, as obrigações não são prestadas de forma simultânea, ou seja, uma das partes cumpre a sua obrigação para, apenas posteriormente, a outra cumprir a contraprestação.¹⁶ Em situações em que não há o pronto cumprimento mútuo das obrigações, abre-se espaço para oportunismo dos contratantes, e, por conseguinte, problemas na relação contratual.

A possibilidade da ocorrência desses problemas é uma das causas dos chamados custos de transação. Estes podem ser entendidos como “todos os eventos que intercedem uma finalidade econômica e sua efetiva concretização, isto é, todos os esforços envidados para a obtenção de resultados eficientes”¹⁷. Dito de outra forma, eles podem ser compreendidos como todos os custos necessários à realização de uma operação econômica de qualquer natureza.

Especificamente, em relação à teoria dos contratos, é possível identificar três categorias de custos de transação: (i) relacionados à localização de um parceiro econômico e a respectiva redação das cláusulas contratuais, os quais irão variar a depender da complexidade do objeto da avença; (ii) ligados à disciplina contratual e sua normatividade; (iii) decorrentes de imprevistos cuja solução deve ser dada no curso da relação já iniciada.¹⁸

Tais custos ocorrerão, necessariamente, para o estabelecimento de qualquer relação contratual. Não obstante, eles podem se manifestar em maior ou menor intensidade. Nesse cenário, o direito contratual deve ser formado precisamente para reduzi-los. É possível elaborar uma “meta-regra” de intervenção do direito contratual da seguinte maneira:

A Intervenção corretiva através do direito contratual é justificada sempre que seu próprio custo é superado pelas economias em custos

¹⁶ Nesse sentido, Ejan Mackaay apresenta os seguintes exemplos: “Things get more complicated when the two parties do not perform their obligation simultaneously; or where their prestations – as civil law English terms their performance – are separated in space; or where the qualities of the object to be bought do not reveal themselves upon simple inspection; where parties are not engaged in a long-term relationship; where the prestations involve a number of objects to be produced or transported, or depend upon contingencies that were uncertain at the time of contracting; or where the value to the buyer of what the seller is to deliver depends upon the care he takes of it. By way of example, the sale of next year’s crop, the chartering of a ship or airplane, franchising, a turnkey contract for the installation of a computer system, the purchase of a building yet to be construct or the enterprise contract – civil law English terminology again – to build it, the contract for services you enter into with a stock broker to manage your investment portfolio are all complex operations in which naturally occurring contingencies and potential opportunism of your contracting partner cannot be ignored. Law then may have a significant role to play”. *Idem*.

¹⁷ KLOH, Gustavo, *Teoria Econômica da Propriedade e dos Contratos*. Op. Cit., p. 310.

¹⁸ *Idem*.

de transação geradas em comparação com o que as partes contratantes seriam capazes de, sozinhas, atingir, em outras palavras, sempre que permitisse às partes “baixar a guarda”, sempre que as suas economias em custos de transação superassem o custo da própria medida interventiva.¹⁹

Ou seja, o direito contratual deve interferir quando o custo de criar e aplicar suas normas mandatórias²⁰ é superado pelo benefício da aplicação uniforme. Quando há uma norma mandatória capaz de levar as partes a um resultado melhor do que elas conseguiriam negociar caso a norma em questão não existisse, esta poderá ser considerada, do ponto de vista da AED, como eficiente.²¹

Dessa maneira, a norma mais adequada é a promotora de maiores ganhos líquidos. Isto é, a capaz de oferecer maiores ganhos em aumento de realização de contratos com menores custos de transação em comparação com os custos, vistos acima, incorridos para sua elaboração e aplicação.²²

Compreender o funcionamento e a aplicação de tais normas mandatórias, e entender quando elas são necessárias, é a função do direito contratual.

Por outro lado, os contratos, como instrumento de circulação de riqueza, possuem funções econômicas. Isto é, são elaborados com vistas ao cumprimento de determinadas funções econômicas extrínsecas a eles mesmos, as instrumentalizando. Nesse sentido Richard Posner elenca cinco funções, quais sejam:

(1) prevenir oportunismo; (2) interpolar termos eficientes tanto como um todo como em questões pontuais (complementação de lacunas versus interpretação *ad hoc*); (3) punir erros evitáveis no processo

¹⁹ Livremente traduzido de: “Corrective intervention through contract law would be justified whenever its own cost is more than offset by the savings in transaction costs it generates by comparison to what the contracting parties could themselves achieve, in other words whenever it allows parties so to lower their guard that their savings more than offset the cost of the measure itself”. MACKAAY, Ejan. **Law and Economics for Civil Law Systems**. Op. Cit., pp. 423-424.

²⁰ Pode-se identificar os quatro custos envolvendo normas contratuais mandatórias: (i) o custo de formular, legislativa ou judicialmente a norma, computando-se o risco de captura (*rent-seeking*), no processo; (ii) o custo das partes aplicarem a norma a partir de algum procedimento (judicial ou arbitral); (iii) o custo de oportunidade de acordos mais arrojadados, proibidos pela norma; (iv) o custo da norma, na prática, não ser a solução adequada para o problema identificado. Ibidem, p. 425.

²¹ Ibidem, pp. 423-424.

²² Nesse sentido: “Any rule that promises gains from more ample contracting and savings in the transactions costs of private parties in excess of its own cost as just specified – net gains, in other words – has a proper place in the law of contract; the Wittman test implies that where several competing rules are conceivable for the same subject matter, the one promising the highest net gain should have preference. One must expect such gains where public authorities have access to greater scale economies in framing and enforcing rules than are open to private actors.”. Ibidem, p. 426.

contratual; (4) alocar o risco para quem pode melhor suportá-lo, e; (5) reduzir o custo da resolução das disputas oriundas do contrato.²³

Thomas Ulen e Robert Cooter, por sua vez, elencam seis funções.

1. Possibilitar que as pessoas cooperem convertendo jogos com soluções não cooperativas em jogos com soluções cooperativas
2. Incentivar a divulgação eficiente de informações dentro da relação contratual;
3. Assegurar o compromisso ótimo com o cumprimento do contrato;
4. Assegurar a confiança ótima;
5. Minimizar os custos de transação da negociação de contratos, fornecendo condições e regulamentações padrão eficientes;
6. Promover relações duradouras, que resolvem o problema da cooperação recorrendo menos aos tribunais para fazer cumprir os contratos.²⁴

As semelhanças entre as listas permitem concluir que a grande preocupação dos contratos é de levar às partes a se visualizarem mais como parceiras ao invés de antagonistas. Em outras palavras, conduzir à cooperação, cuja manifestação pode ocorrer de diversas formas, mas, especialmente, a partir do compartilhamento mútuo de informações relevantes, permitindo decisões mais informadas e, portanto, melhores dentro da dinâmica contratual. Com isso, há a redução de imprevistos e maior facilidade de sua resolução quando ocorrem. Nesse sentido:

Cada uma dessas funções leva a arranjos para evitar reveses dentro da relação contratual, bem como para minimizar o custo do processo em si. Vale à pena buscá-las através de normas mandatórias justamente porque, e na medida em que, elas reduzem o custo de reveses e sua prevenção para além do que as partes, per si, poderiam atingir: o *Wittman test*. Na maior parte dos casos, isso é feito atribuindo-se a responsabilidade à parte que melhor, ou de forma mais barata, pode influenciar a ocorrência ou o custo de um revés, ou a ambas as partes, quando não for possível determinar quem está em melhor posição.²⁵

²³ Livrentemente traduzido de: (1) to prevent opportunism, (2) to interpolate efficient terms either on a wholesale or a retail basis (gap-filling versus ad hoc interpretation), (3) to punish avoidable mistakes in the contracting process, (4) to allocate risk to the superior risk bearer, and (5) to reduce the costs of resolving contracts disputes. POSNER, Richard A. **Economics Analyses of Law**. Aspen Publishers, 2010, p. 123.

²⁴ COOTER, Robert; ULEN, Thomas. **Direito & Economia**. Porto Alegre. Brokman Companhia Editora. 5ª ed., 2010, p. 237.

²⁵ Livrentemente traduzido de: "Each of these functions points to arrangements seeking to avoid mishaps in and to minimize the cost of the contracting process. They are worth pursuing through public law precisely because, ant to the extent that, they reduce the cost of mishaps an their prevention beyond what parties themselves could achieve: the Wittman test. In most cases, this is done by attributing a burden to the party who can best or most cheaply influence the occurrence or cost of

Na parte final do trecho acima, encontra-se a ideia do “*cheapest cost avoider*”, introduzida por Guido Calabresi. Para este autor, o fardo de evitar uma ocorrência negativa em uma relação deve ser atribuído à parte que pode evitá-la ao menor custo.²⁶

A grande utilidade da abstração do *cheapest cost avoider* é a sua aplicabilidade no contexto de contratos incompletos. Pode-se entender o conceito de contratos incompletos a partir de sua antítese, isto é, os contratos completos. Para os economistas, considera-se completo um contrato no qual se assume que as partes, perfeitamente informadas e agindo de forma completamente racional, conseguiram prever soluções para quaisquer contingências possíveis e imagináveis com potencial de surgir durante a performance do contrato. Nesse cenário, todos os possíveis reveses já foram internalizados pelo instrumento contratual.²⁷

Como é fácil de perceber, o contrato completo não existe na realidade, é uma construção abstrata.

Não obstante, a sua utilidade está em permitir imaginar como as partes poderiam ter negociado sobre determinada contingência, caso tivessem se dado ao trabalho de fazê-lo, qual teria sido a disposição prevista de forma a beneficiar ao máximo a relação contratual.²⁸

Ao se considerar a realidade, necessariamente todo contrato será incompleto, bem como as normas civis, o direito contratual, também possuirá incompletudes, pois há um custo, como exposto acima, para elaboração e aplicação de normas mandatórias.²⁹ Certamente, há diferentes graus de incompletude entre os contratos, os mais simples e envolvendo ativos menores serão mais completos, pois estão vulneráveis a menos contingências, enquanto os mais complexos, e geralmente com ativos mais volumosos, estão expostos a mais reveses.³⁰

²⁶ CALABRESI, GUIDO; MELAMED, A. DOUGLAS. Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral. **Harvard Law Review**, [s. l.], v. 85, n. 6, p. 1089, 1972. Disponível em: <<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=edsjsr.10.2307.1340059&lang=pt-br&site=eds-live>>. Acesso em: 11 outubro de 2019.

²⁷ MACKAAY, Ejan. **Law and Economics for Civil Law Systems**. Op. Cit., p. 428.

²⁸ Idem.

²⁹ Até porque todo instituto jurídico será, necessariamente, incompleto em alguma medida: “Hence statutes are necessarily incomplete, as indeed are all legal instruments. Furubotn and Richter have proposed the term *rational incompleteness* to capture this idea” Ibidem, p. 429.

³⁰ Idem.

O grande problema da incompletude, relacionado com as funções do contrato, é que ela abre espaço para o oportunismo de algum dos contratantes, ou mesmo ambos. Questão agravada pela assimetria de informações³¹.

Oportunismo, igualmente chamado de comportamento estratégico, é a prática de uma das partes, utilizando astúcia ou poder de barganha dominante, para modificar o acordo para sua vantagem em detrimento da contraparte, drenando para si os ganhos conjuntos do contrato em comparação com o inicialmente projetado. O efeito negativo do oportunismo está em piorar o acordo para uma das partes, criando incentivos para ou se investir mais em precaução no ato de contratar ou, ainda, para que os agentes diminuam seu nível de contratação. As duas hipóteses representam aumentos dos custos de transação, diminuindo, dessa maneira, a eficiência geral das trocas na sociedade.³²

Portanto, para cumprir sua função, um contrato deve prevenir o oportunismo. Para isso, seus dois principais efeitos são a vinculação das partes à performance do contrato, cujo objeto deve ter as qualidades descritas no ato negocial ou, ao menos, ser compatível com o costumeiramente esperado dele.³³

Entende-se que houve o adimplemento contratual quando o objeto foi entregue na forma, lugar e tempo ajustados, portanto, o oposto, o inadimplemento é a falha de uma das partes em realizar a prestação prometida, ou fazê-lo de forma incompleta ou atrasada. Como resultado desse revés, o contrato não mais fornece um ganho Paretiano para as partes. Logo, vale à pena criar incentivos às partes para evitar este resultado.³⁴

³¹ O conceito de assimetria de informação será trabalhado de forma mais detalhada nos capítulos subsequentes, não obstante, de forma preliminar, é possível entender a assimetria de informação como a situação na qual alguma das partes da relação “sabe mais que a outra sobre o que está acontecendo. Uma diferença de acesso a conhecimento relevante é chamada *informação assimétrica*.” (grifo do autor). MANKIW, N. Gregory. **Introdução à Economia**. Tradução da 6ª edição norte-americana. Tradução: Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. Revisão Técnica Manuel José Nunes Filho. São Paulo. Cengage Learning, 2018. p. 442.

³² Nesse sentido: “The victim of opportunistic behavior regrets having ‘been had’. This regret casts its shadow, in advance, over its decision, and that of others in similar circumstances, to enter into such contracts in the first place. All of them, fearing to fall victim to opportunism, look for preventive measures to avoid being done out of their fair share of the spoils of the contract. (...) They may better inform themselves about their contracting partner or specify the contract in more detail, so as to fend off the possibility that a gap will be exploited opportunistically; ultimately, they may refrain from contract altogether”. MACKAAY, Ejan. **Law and Economics for Civil Law Systems**. Op. Cit., p. 430.

³³ Ibidem, p. 479...

³⁴ Sobre a ocorrência do inadimplemento: “Non-performance occurs where one of the parties fails to provide the prestations agreed upon, or provides it incompletely or late. As a result of this ‘mishap’ the contract may no longer provide a Pareto gain. Hence it would seem worthwhile to create incentives for parties to avoid this outcome”. MACKAAY, Ejan. **Law and Economics for Civil Law Systems**. Op. Cit., p. 479.

Assim, o direito contratual deve criar incentivos para o adimplemento do avençado. Um mecanismo para isso é, nos casos de inadimplemento, sancionar o culpado, se houver. A sanção deve servir como um critério pelo qual os devedores irão ajustar quanto de precaução devem investir para garantir o adimplemento³⁵. Por outro lado, a proporção da sanção também sinaliza a dimensão do risco ao qual o credor está exposto, no caso a não compensação, ou subcompensação, pelo inadimplemento, permitindo ajustar sua precaução.³⁶

Ainda dentro da ideia de prevenção de oportunismo³⁷, o contrato pode ser utilizado como um instrumento para fazer uma alocação inicial dos reveses mais comuns no tipo de negócio em questão, assim entendidos como os riscos, seus efeitos gravosos, e as compensações de quem deve arcar com tais imprevistos.³⁸

Uma alocação adequada de riscos significa menos discussões, inclusive judiciais, durante a execução contratual, por consequência, reduz os custos de transação.

Não obstante, deve-se pensar da seguinte maneira: pode ser que um risco seja tão raro e improvável de acontecer que os custos para negociar a cláusula não seriam eficientes ao se considerar o custo esperado da sua ocorrência, quando, de fato, causará mais custos de transação a prevenção *ex ante*. Todavia, se o risco for muito elevado, certamente será vantajoso adiantar esse custo para o momento da formação do contrato.³⁹ Entendendo a ocorrência de um risco como um prejuízo, é possível pensar da seguinte maneira para reduzir os custos de transação:

³⁵ Como foge ao escopo da presente dissertação uma discussão sobre a teoria da quebra eficiente do contrato (*Efficient Breach*), deixa-se apenas a referência à: COOTER, Robert and ULEN, Thomas, **Law and Economics**. 6th edition. 2016. Berkeley Law Books. Disponível em: <https://scholarship.law.berkeley.edu/books/2/>. Acesso em 11 de outubro de 2019. p. 325 e seguintes.

³⁶ MACKAAY, Ejan. **Law and Economics for Civil Law Systems**. Op. Cit., p. 482.

³⁷ Para Richard Posner, o direito contratual teria o objetivo claro de evitar o comportamento oportunista e encorajar a atividade econômica ótima, nesse sentido: “The basic aim of contract law (as recognized since Hobbes’s day) is, by deterring people from behaving opportunistically toward their contracting parties, to encourage the optimal timing of economic activity and (the same point) obviate costly self-protective measures. But it is not always obvious when a party is behaving opportunistically”. POSNER, Richard A. **Economics Analyses of Law**. 8ª ed. Aspen Publishers, 2010. p. 117.

³⁸ Ibidem, p. 503.

³⁹ Nesse sentido: “‘Riscos *ex ante*’ designam o risco de prejuízos futuros com que as partes se defrontam ao negociar um contrato. ‘Prejuízos *ex post*’ designam prejuízos que de fato acontecem depois da formação do contrato. Em geral, as partes de um contrato precisam optar entre alocar riscos *ex ante* e alocar prejuízos *ex post*. Pense na diferença de custos de transação entre a alocação de riscos e perdas. Se as partes negociarem condições explícitas para alocar os riscos, certamente arcarão com custos de transação. Se elas deixarem uma lacuna, arcarão com os custos de transação com uma probabilidade positiva. O custo de transação *esperado* de uma lacuna no contrato é igual à probabilidade de que o prejuízo se efetive multiplicado pelo custo da sua alocação. As partes esperam economizar em custos de transação deixando lacunas em contratos sempre que o custo efetivo da negociação de

Custo de alocação de um risco (Cr)⁴⁰

Custo de alocação de uma perda (Cp)⁴¹

Probabilidade de um prejuízo (ρ).

Quando $Cr > Cp \cdot \rho$, deve-se deixar a lacuna, mas quando $Cr < Cp \cdot \rho$, o mais eficiente é preencher a lacuna.⁴²

Ao final, a teoria econômica dos contratos permite entender que o objetivo principal do direito contratual é minimizar o custo geral de reveses contratuais e sua prevenção. Mas também é o primeiro passo para se pensar em modelos normativos visando à redução dos custos de transação e facilitando a realização e cumprimento das avenças contratuais.⁴³

2.2. Análise Econômica dos Contratos Públicos.

Como afirmado no tópico anterior, parte considerável da dogmática da Análise Econômica do Direito volta-se ao estudo do direito contratual. Nesse passo, avultam estudos sobre a formação dos contratos, custos de transação, mecanismos de incentivo à confiança e cooperação, teoria da quebra eficiente e aplicação da teoria dos jogos à dinâmica contratual.

Todavia, a metodologia da AED pode ser aplicada não apenas em contratos envolvendo partes privadas. Na medida em que o Estado também pode agir como uma parte contratual, apesar de todas as particularidades decorrentes de seu regime jurídico peculiar, é possível aplicar a teoria econômica dos contratos no âmbito das contratações públicas como instrumento para o aprimoramento de gestão pública.⁴⁴

condições explícitas exceda o custo esperado do preenchimento de uma lacuna.” (grifo dos autores). COOTER, Robert; ULEN, Thomas. **Direito & Economia**. Op. Cit. p. 223.

⁴⁰ O custo para as partes negociarem e deixarem já previsto em contrato quem vai arcar com os efeitos gravosos de eventuais reveses, bem como a sua compensação.

⁴¹ Assim entendido como o custo para alocar o efeito gravoso de um revés contratual após a sua ocorrência, isto é, sem que aquele risco tenha sido alocado inicialmente no momento da elaboração contratual.

⁴² Idem.

⁴³ Trata-se, aqui, da dimensão normativa, prospectiva, da AED. Para Richard Posner “economic analysis can be helpful in designing reforms of the legal system” POSNER, Richard A. *The Economic Approach to Law*. **Texas Law Review**. 1975, Pp. 757-782. p. 764.

⁴⁴ Nesse sentido: “No caso do fenômeno da contratação pública, o estudo do sistema legal e de sua aplicação – para que sirva de instrumento de desenvolvimento econômico – pode se valer da AED para o aprimoramento da gestão pública e sua normatividade” DIAS, Maria Tereza Fonseca. **Análise Econômica do Direito nas Contratações Públicas: estudo de casos da legislação e experiência brasileira**. Trabalho apresentado e debatido no “II Congresso Internacional de Compras Públicas: Para um crescimento da Economia Assente na Contratação Pública Sustentável, Inteligente e Inovadora”,

Aqui, entende-se contratos públicos como aqueles em que uma das partes é a Administração Pública na qualidade de promotora de algum interesse público primário, bem como trata-se de relação jurídica submetida às constrações do Direito Administrativo⁴⁵. Nesse sentido, Diogo de Figueiredo Moreira Neto afirma:

O *contrato administrativo*, como espécie de contrato, embora apresente os mesmos elementos deste gênero, se distingue com relação a um deles – o *interesse* – por ser qualificado pela ordem jurídica como da natureza *pública*, submetendo-o, assim, ao regime do Direito Administrativo. (grifos do autor).⁴⁶

Dessa forma, parece claro que um contrato administrativo deve ser visto como um instrumento para a consecução de uma finalidade maior, transcendente a ele, qual seja “um interesse público que necessite de tutela”⁴⁷. Consequência disso é que a inexecução, ou execução deficiente, qualquer seja o motivo, de um contrato administrativo reverbera em um dano à sociedade como um todo.⁴⁸⁻⁴⁹

Este é o motivo mais abstrato pelo qual o tema das compras públicas é muito debatido na seara do direito administrativo. Porém, de forma mais concreta, é possível destacar três razões especiais para seu estudo: (i) é o mecanismo pelo qual a Administração Pública adquire bens e serviços instrumentais para realizar suas atividades finalísticas; (ii) o sistema normativo apresenta-se como exaustivamente complexo, exigindo um esforço da doutrina em deixá-lo mais claro aos gestores, e; (iii) o volume das compras governamentais é tão expressivo ao ponto de torná-lo um dos principais agentes da economia, portanto a forma pela qual se dá a aquisição de bens e serviços no mercado é capaz de gerar efeitos sobre a economia como um todo⁵⁰.

promovido pelo Serviço Nacional de Contratação Pública (SNCP) de Angola em colaboração com a Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas de Cabo Verde (ARAP) e a Universidade do Minho, entre os dias 16 a 18 de novembro de 2016, em Luanda.

⁴⁵ Para um breve histórico do sistema brasileiro de contratações públicas recomenda-se: FREITAS Rafael Veras de, **Análise Econômica das Contratações Públicas**. Op. Cit.

⁴⁶ MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. **Curso de Direito Administrativo. Parte introdutória, parte geral, parte especial**. 16ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2014. p. 179..

⁴⁷ SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. ARAÚJO, Thiago Cardoso. Previsibilidade ou Resiliência? Notas sobre a repartição de riscos em contratos Administrativos. **Revista de Direito da Procuradoria Geral**, Rio de Janeiro, (Edição Especial): Administração Pública, Risco e Segurança Jurídica. 2014, pp. 311-333, p. 311.

⁴⁸ Ibidem, p. 312.

⁴⁹ “Se o projeto licitado não for implementado, se o serviço público não for prestado a contento, se o contratado não entregar a obra ou o serviço, perde a população, mas perde também o gestor, especialmente se titular de cargo comissionado ou eletivo.” Idem.

⁵⁰ Exemplificativamente: “Contudo, considerando que as aquisições e contratações governamentais representam expressivo volume econômico, sendo assim hábeis a causar impacto nos mercados ou induzir comportamentos dos agentes econômicos, o legislador por vezes opta por utilizar os

Embora o tema seja, repita-se, muito trabalhado pelo direito público brasileiro, o foco da literatura especializada é mais procedimental do que finalístico, isto é, preocupa-se mais em compreender, esmiuçar o intrincado rito licitatório e contratual no lugar de buscar desenvolver mecanismos eficientes de compras. Sintetizando essa afirmação, expõe Marcos Nóbrega:

Apesar de dezenas de livros escritos no Brasil desde a edição da lei de licitações (lei 8.666) em 1993, a grande maioria se restringiu a uma análise procedimental do instituto, dirimindo dúvidas pontuais sobre questões ainda abertas. Foram livros que olharam para dentro do sistema sem qualquer questionamento sobre o porquê das coisas e como aperfeiçoá-las. Infundáveis debates sobre temas como hipóteses de contratação direta (dispensa e inexigibilidade) ou mesmo requisitos de habilitação se seguiram dando ao gestor público condições de tomar decisões diante de uma legislação confusa, extensa e com muitas imperfeições.⁵¹

Como alerta Rafael Veras, o estudo das compras públicas é uma disciplina na qual o método da AED possui pouca penetração⁵², pois o “Direito Administrativo Brasileiro foi concebido a partir de entendimentos doutrinários, e não para ser eficiente”⁵³. O foco no princípio da legalidade, valor máximo da dogmática administrativista, acabou por cegar os legisladores, e os juristas, para outros valores relevantes, especialmente a eficiência, na dogmática administrativista.⁵⁴

Contudo, essa pouca simpatia ao uso da eficiência como parâmetro, e, por conseguinte, a pouca penetração da AED no direito administrativo brasileiro, não nos parece justificada, isso porque onde há espaço para aumentar a eficiência da criação e aplicação de normas jurídicas, é possível utilizar AED, não sendo um obstáculo o fato de se estar na seara do Direito Público, dessa maneira:

mecanismos licitatórios como forma de intervenção na economia, buscando, desse modo, regular mercados ou promover determinadas práticas, políticas públicas ou valores constitucionais.” CARVALHO, Victor Aguiar de. A função regulatória da licitação como instrumento de promoção da concorrência e de outras finalidades públicas. **Fórum de contratação e Gestão Pública – FCGP**, Belo Horizonte, ano 16, n. 186, p. 65-74, jun. 2017. p. 66.

⁵¹ NÓBREGA, Marcos. Novos Marcos Teóricos em Licitação no Brasil: Olhar para além do sistema jurídico. Op. Cit. p. 1.

⁵² VERAS, Rafael. O que a Análise Econômica do Direito tem a ver com os contratos administrativos? **Revista Eletrônica de Direito do Estado**. Ano 2016. Número 294. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Rafael-Veras/o-que-a-analise-economica-do-direito-tem-a-ver-com-os-contratos-administrativos> (acesso em: 05 de novembro de 2019)

⁵³ Idem.

⁵⁴ Apesar da promulgação da Emenda constitucional n.º 19 de 1998 incluir a eficiência entre os princípios da Administração Pública, parece-nos que a preponderância absoluta da legalidade ainda é a tônica das práticas estatais brasileiras.

Enquanto há ramos relevantes do ordenamento jurídico que não são organizados de acordo com as exigências da eficiência, o economista pode desempenhar um papel importante ao sugerir mudanças para aumentar a eficiência do sistema. Decerto, não compete ao economista, enquanto tal, determinar se a eficiência deve superar outros valores em caso de conflito.⁵⁵

A partir desse método, se consegue visualizar como o sistema brasileiro de contratações públicas, notadamente aquelas submetidas à Lei n.º 8.666/93, amarra o administrador a regras e procedimentos uniformes, pouco ou nada flexíveis e, no geral, extremamente ineficientes. Além de não garantir, como casos recentes de corrupção têm demonstrado, a lisura nas avenças estatais, igualmente não assegura compras a preços equivalentes ou próximos àqueles praticados no mercado.⁵⁶

Isso porque um direito contratual eficiente é capaz de reduzir os custos de transação, especialmente a partir do incentivo à cooperação e desincentivo ao comportamento estratégico, isto é, oportunista, das partes.

Rafael Veras nos adverte que o paradigma atual da Lei n. 8.666/93 é um verdadeiro multiplicador de custos transacionais, desde a fase pré-contratual até a após sua execução, assim assevera:

O regime jurídico dos contratos administrativos, tal como delineado pela Lei nº 8.666/1993, é um exemplo (quase que de manual) de como se celebrar um contrato com elevados custos de transação nas fases pré e pós contratual.⁵⁷

Eduardo Fiuza, em estudo sobre licitações e governança dos contratos, conclui pela grande ineficiência do nosso arcabouço jurídico quanto às contratações, fazendo, ainda, sugestões para apurar o marco legal das compras públicas. Nesse seguimento, o autor sintetiza as discussões em dois grandes eixos, o primeiro relativo à eficiência do arcabouço institucional, no qual congrega a rigidez das regras de compras públicas e o formalismo prejudicial à inteligência nas compras, e o segundo correspondente à

⁵⁵ Livremente traduzido de: "So long as there remain important areas of the legal system that are not organized in accordance with the requirements of efficiency, the economist can play an important role in suggesting changes designed to increase the efficiency of the system. Of course, it is not for the economist, *qua* economist, to say whether efficiency should override other values in the event of a conflict. POSNER, Richard A. *The Economic Approach to Law*. p. 765.

⁵⁶ Nesse sentido, vide: ROSILHO, André Janjácomo. **As Licitações Segundo a Lei 8.666: um Jogo de Dados Viciados?** S.n.t. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2675943/mod_resource/content/1/20120312%20-%20As%20licita%C3%A7%C3%B5es%20segundo%20a%20Lei%208666_um%20jogo%20de%20dad%E2%80%A6%20%282%29.pdf; Acesso em: 12 de dezembro de 2019;

⁵⁷ VERAS, Rafael. O que a Análise Econômica do Direito tem a ver com os contratos administrativos? *Revista Eletrônica de Direito do Estado*. Op. Cit.

eficiência dos contratos públicos e critérios de adjudicação, onde inclui os tipos contratuais, as atividades de planejamento das compras, remuneração dos particulares, elaboração de um cadastro positivo de fornecedores e avaliação das regras de adjudicação inexistência com vistas à obtenção de produtos de melhor qualidade com preço mais competitivo.⁵⁸

Conforme mencionado no tópico acima, em relação às funções econômicas do direito contratual, ao confrontar tais funções com as afirmações de Rafael Veras, as conclusões de Eduardo Fiuza e as propostas de Richard Posner é possível verificar um abismo entre o que o direito contratual deve se propor ao fazer e o que o nosso arcabouço jurídico de contratações públicas oferece. A legislação brasileira de licitações e contratos não é capaz de gerar contratos eficientes e nem de proteger as finanças públicas de ações ilícitas, não cumprindo nenhuma das funções do direito contratual apontadas no tópico anterior.⁵⁹

Diversas são as razões para tais incapacidades, e a utilização da AED à dogmática das compras públicas é capaz de abrir caminhos nos becos sem saída produzidos pelas normas licitatórias nacionais.

Como já dito anteriormente, a utilização da eficiência como parâmetro também pode ser aplicada em contratos públicos. Na realidade, não deveria causar nenhuma

⁵⁸ Nesse sentido: “Este trabalho procurou, a partir das informações e dos dados disponíveis, empreender um mapeamento das principais questões econômicas envolvidas no processo licitatório, no ambiente institucional que o rege e nas regras que regem os contratos resultantes das licitações. Podemos resumir a discussão acima em dois grandes eixos:

1) Eficiência do arcabouço institucional:

a) pôde-se observar que as regras das compras públicas são por demais rígidas, cristalizadas em lei, e não há uma harmonização de procedimentos, editais, contratos, pareceres jurídicos etc; b) as regras de compras são por demais formais e não favorecem a inteligência em compras; a falta de uniformização da interpretação da lei e a ausência de incentivos a boas compras confundem os gestores de compras e os induzem a comportamentos burocráticos.

2) Eficiência dos contratos públicos e critérios de adjudicação:

a) os tipos de contratos ou empreitadas utilizados na contratação de obras públicas podem ser expandidos e aperfeiçoados, com vistas a reduzir os custos de transação com aditamentos; b) devem ser feitas pesquisas sobre o impacto da complexidade de obras na ocorrência de aditamentos, para que se possa pensar em melhores critérios e regras de remuneração e de garantia dos contratos; c) a habilitação dos fornecedores deve ser integrada num grande cadastro positivo, que daria maiores incentivos ao bom desempenho dos fornecedores, especialmente nos quesitos de qualidade não-contratáveis; d) o melhor planejamento de compras e financeiro é fundamental para se baixar os custos financeiros dos fornecedores e obter melhores preços para a Administração Pública. Os atrasos de pagamentos só prejudicam o Estado, pois favorecem a corrupção e/ou elevam os custos financeiros embutidos nos preços pagos; e) precisa ser avaliado o impacto das regras de inexistência atuais sobre os preços obtidos nos leilões licitatórios; f) o uso de critérios de adjudicação a propostas economicamente mais vantajosas ajudaria a melhorar a qualidade dos bens e serviços adquiridos.” FIUZA, Eduardo P. S. (2009). “Licitações e contratos no Brasil: a visão dos economistas.” In: SALGADO, L. H.; FIUZA, E. P. S. (Ed.). Marcos regulatórios no Brasil: é tempo de rever regras? Rio de Janeiro: IPEA. Pp. 271/272.

⁵⁹ Cf. GARCIA, Flávio Amaral. **Licitações e Contratos Administrativos: Casos e polêmicas**. 4ª Edição. São Paulo. Editora Malheiros, 2016. p. 54.

estranheza aos administrativistas imbuir o seu discurso de preocupações relativas à eficiência, vez que a própria CRFB/88 elenca como princípio⁶⁰ da Administração a eficiência. Muito embora, como destacado em seção anterior, nos pareça mais adequado aplicá-la, juridicamente, como um postulado normativo aplicativo, ou seja, uma norma de segundo grau, a qual se dirige à aplicação de outras normas.

Uma das facetas da preferência pelo formalismo sobre métodos mais eficientes de contratação pode ser visto a partir da uniformidade de tratamento dos métodos de contratação e dos contratos propriamente ditos, estabelecidos pela Lei n.º 8.666/93. Tal norma se limita a diferenciar apenas os métodos de seleção (modalidades e tipos de licitação) pensados a partir de porte econômico. Ou seja, a depender do valor será adotado um tipo diferente de modalidade de licitação, os quais, na prática, não diferem tanto entre si, apenas com algumas alterações de prazos e exigências formais mais ou menos rígidas.

Essa visão, parece não perceber que “cada contrato tem sua própria lógica econômica, sendo irreal pretender subjugar toda e qualquer relação contratual às regras rígidas da Lei n.º 8.666/93”⁶¹.

Todavia, a partir da edição da Lei n.º 8.987/95, cujo foco foi normatizar a concessão e permissão da prestação de serviços públicos, mesmo que de forma ainda tímida, observou-se a edição de diplomas normativos relativos às contratações públicas com o objetivo de fugir da Lei Geral de Licitações.⁶² Cita-se como exemplos: a Lei n.º 10.520/02, criadora do pregão, nova modalidade de licitação mais simples, com vistas às compras mais simples da Administração, capazes de suprimento pelo mercado a partir de definição objetivamente descrita pelo edital mediante especificações usualmente utilizadas pelo mercado; a Lei n.º 11.079/04, a qual regulamentou as parcerias público-privadas, enquanto não fez grandes alterações no regime licitatório, ela ofereceu novas possibilidades de arranjos do Poder Público com o setor privado; e a Lei 12.462/11, que criou o Regime Diferenciado de Contratações, inicialmente com o objetivo de adequar as obras ligadas aos grandes eventos

⁶⁰ Parece-nos, até, que ao incluir a eficiência no art. 37 da CRFB/88 o constituinte derivado a alçou à categoria dos principais princípios da Administração Pública.

⁶¹ GARCIA, Flávio Amaral. **Licitações e Contratos Administrativos: Casos e polêmicas**. 4ª Edição. Op. Cit., p. 340.

⁶² “O regime e o tratamento uniformes para todos os contratos administrativos é outro tema bastante questionado nos dias de hoje. (...) é necessário compreender e aceitar a heterogeneidade de dos regimes jurídicos dos contratos no Brasil, que é, por vezes, distorcida na prática, para se cogitar de um único regime jurídico a todo e qualquer contrato administrativo.” Idem.

esportivos sediados no Brasil (olimpíadas e copa do mundo), mas cujas inovações foram bem recebidas pela prática de tal forma que seu escopo foi continuamente ampliado⁶³.

Ainda que se possa observar essa tendência, não se pode falar que tenha ocorrido uma verdadeira reforma do sistema de compras públicas como um todo. Na realidade, parte considerável das alterações realizadas pelas normas mencionadas acima foram alvo de resistência da opinião pública, a qual, em boa medida, defendia a necessidade de uma norma constritiva do administrador, nos moldes da Lei Geral de Licitações. Ademais, a própria Lei n.º 8.666/93 é, ainda, utilizada de forma subsidiária, em maior ou menor intensidade, em relação a todas as outras citadas no parágrafo anterior⁶⁴, conduzindo-nos à conclusão de que mesmo sendo alvo de um esvaziamento, ela não deixou de ser o elemento central do sistema de compras públicas.

Encontra-se, ainda, certa dificuldade na compreensão de haver algum nível de flexibilidade dentro dos contratos públicos. Nesse sentido, falou-se no tópico anterior em relação à natureza inerentemente incompleta dos contratos, isto porque é faticamente impossível antever todas as contingências capazes de atingir uma relação contratual, mesmo considerando-se possível, seria muito custoso (elevados custos de transação). Não obstante, as normas relativas aos contratos públicos buscam, em boa medida, endereçar diversas contingências, o que acaba refletindo em ofertas que precificam tal exagero de previsões, sem uma avaliação de custo benefício entre o melhor momento para lidar com esses reveses, se antes ou depois de sua ocorrência, bem como em contratos com pouco espaço para adaptações diante de imprevistos e mudanças da realidade, especialmente econômica⁶⁵.

Com isso, é necessário entender os contratos públicos como de natureza incompleta, até porque o interesse público primário subjacente ao contrato administrativo pode se modificar com o tempo⁶⁶. Como consequência da incompletude

⁶³ “... essa parece ser a tendência, eis que vários diplomas legais têm surgido com adequações às realidades de mercado que os orientam”. Idem.

⁶⁴ Por exemplo: art. 9º da Lei n.º 10.520/2002 e art. 39 da Lei n.º 12.462/2011.

⁶⁵ Cf. NÓBREGA, Marcos. O Leviatã retroalimentado: quem paga a conta das Cláusulas Exorbitantes? **Revista Direito do Estado**. Ano 2018, n.º 397. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/marcos-nobrega/o-leviata-retroalimentado-quem-paga-a-conta-das-clausulas-exorbitantes>; Acesso em: 15 de dezembro de 2019.

⁶⁶ “Contratos Administrativos são mutáveis por natureza. Essa característica se explica, em parte pela vinculação desses ajustes ao atendimento de interesses públicos, em especial aqueles definidos como

contratual também atingindo os contratos administrativos, é possível inferir como uma de suas características a mutabilidade⁶⁷, conforme afirma Flávio Amaral Garcia:

A mutabilidade é inerente aos contratos, não sendo razoável cristalizar e tornar excessivamente rígidos os instrumentos contratuais, mormente diante das diversas contingências futuras que podem acometer a execução das obrigações durante o prazo do ajuste.⁶⁸

Não apenas em contratos de concessão, com durações até mesmo trintenárias, mas também contratos com objetos complexos, tais quais infraestruturas de grande porte, como ferrovias, usinas de energia e outras construções que podem ser alvo de diversas intempéries, cuja execução irá se protrair no tempo. Com isso, espera-se do contrato administrativo a capacidade de considerar “de maneira mais objetiva as perturbações que possam ocorrer, advindas de um ambiente externamente suscetível a mudanças, e possa a elas se adaptar”⁶⁹.

Na realidade, mais do que resistente ao tempo, espera-se que o contrato administrativo seja resiliente, ou seja, “dotado da capacidade de adaptar-se às contingências, reestabilizando-se ao mesmo tempo em que se preservam os princípios da Administração Pública e do procedimento licitatório”⁷⁰.

Todavia, os resultados práticos das contratações indicam, como será demonstrado ao longo do capítulo, que os contratos públicos, especialmente de obras públicas, acabam sofrendo alterações desequilibradas e, com frequência, atrasados ou, até mesmo, abandonos por longos períodos, resultando em prejuízos para o erário e para toda a sociedade, que deixa de se beneficiar do resultado das infraestruturas públicas.

primários.” GARCIA, Flávio Amaral. **Licitações e Contratos Administrativos: Casos e polêmicas**. Op. Cit. p. 341.

⁶⁷ “Outra característica dos contratos administrativos é a sua mutabilidade, pois que seu objeto está afeto ao atendimento de determinado interesse público, que é, por natureza, sujeito a variações. Essa mutabilidade foi expressamente reconhecida no art. 65 da Lei 8.666/93, que disciplina acerca das alterações contratuais, tudo com vistas a conferir maior flexibilidade a esses ajustes sua adequação ao princípio da realidade. De nada adianta um instrumento contratual que se encontre em descompasso com o mundo dos fatos” Ibidem. P. 350. Todavia haja a previsão de hipóteses em que poderá haver alteração, inclusive unilateral, do contrato, são possibilidades fechadas, e, em boa medida, insuficientes, mais preocupadas em alterações quantitativas do objeto contratual.

⁶⁸ Ibidem, p. 342.

⁶⁹ SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. ARAÚJO, Thiago Cardoso. Previsibilidade ou Resiliência? Notas sobre a repartição de riscos em contratos Administrativos. Op. Cit. p. 313

⁷⁰ Idem.

2.2.1. Eficiência em Contratos Administrativos

Nos tópicos anteriores, mencionou-se a necessidade de mais eficiência no bojo dos contratos administrativos. Neste tópico, busca-se esclarecer o que se entende, no presente trabalho, como um contrato administrativo eficiente.

A teoria econômica, e por consequência, a Análise Econômica do Direito, preocupa-se como as pessoas (ou agentes) comportam-se em resposta ao sistema jurídico⁷¹. Difere, portanto, de outras formas de pensar a resposta dos jurisdicionados ao direito porquanto considera a possibilidade de desviarem de forma racional e, ainda, se beneficiarem do não cumprimento, mesmo que efetivamente sofram alguma sanção.⁷² Isto é, a AED trata a conformação às normas não como algo absoluto dentro do espectro de escolhas dos agentes, mas sim como uma possibilidade, a qual apenas ocorrerá se, e na medida em que, for mais vantajoso do ponto de vista da utilidade para o agente.

Para AED, não necessariamente os agentes irão conformar seus comportamentos diretamente às normas. Considera-se as pessoas como capazes de realizar uma análise de custo-benefício entre o cumprimento ou não de determinado comando legal, portanto decidindo qual a melhor ação adotar para seu benefício próprio, sem, de maneira geral, levar em conta o melhor para a sociedade, portanto, para a AED a “avaliação e entendimento das normas jurídicas deve ir além da discussão sobre o que é socialmente desejável ou necessário para fazer um esforço para ver através das normas e enxergar os comportamentos que elas induzem.”⁷³

Para tanto, a AED

Oferece ao menos três paradigmas distintos em relação às influências de normas jurídicas sobre o comportamento. De acordo com a análise econômica das obrigações, agentes consideram a

⁷¹ KORNHAUSER, LEWIS A.. The New Economic Analysis of Law: Legal Rules as incentives. In: **Law And Economics**. Recent Economic Thought Series. Nicholas Mercuro (org.). Kluwer Academic Publishers. Boston; Dordrecht; London. 1988. pp.27-55. p. 28.

⁷² Nesse sentido, Lewis Kornhauser considera as teorias que tratam a norma jurídica como per si realizável como ingênuas: “Prior to the emergence of the new economic analysis of law, assumptions concerning the effects of legal rules or behavior were generally implicit rather than explicit, often *ad hoc*, occasionally inconsistent, and almost always ‘naïve’. According to the tacit, naïve that underlay, and continues to underlie, much discussion and debate of law, individuals conform their behavior to that required by the legal rule. Thus, under the naïve theory, evaluation of a legal rule reduces to an inquiry of what society wants or requires”. Idem.

⁷³ No original como: “our appraisal and understanding of legal rules must extend beyond a discussion of what is socially desirable or necessary to an effort to ‘see through’ the legal rules to the behavior that they induce” Idem.

consequência da violação de uma norma ao escolher suas ações. A análise econômica dos direitos de propriedade argumenta que diferentes distribuições e pacotes de direitos irão induzir diferentes comportamentos. A perspectiva da teoria da escolha pública foca nas tentativas dos agentes de determinar as normas as quais estão submetidos.⁷⁴

Ou seja, passa-se a entender a ação humana em relação à norma de forma não direta, isto é, a norma jurídica não é o único elemento determinante do comportamento de um agente, mas apenas um deles, funciona, assim, como um incentivo, no meio de tantos outros.

Não se considera a lei como um elemento totalmente irrelevante na tomada de decisão dos agentes, mas sim destacar a ideia de que uma norma não impõe, necessariamente, um resultado, mas sim determina qual o jogo de barganha a ser jogado pelas partes de alguma relação.⁷⁵ Isto é, uma relação econômica deve ser vista como um jogo induzido pelos responsáveis de um sistema normativo.⁷⁶

Nesse sentido, considerando as normas jurídicas como incentivos pode-se concluir que:

Se os incentivos estão em equilíbrio, cada um deles gera incentivos para que o promitente tome precauções eficientes para a conclusão das obras ou reformas. Já, por exemplo, se o custo de oportunidade do não cumprimento do contrato for menor que os custos pelo cumprimento, ocorre um desequilíbrio com a criação de incentivos para uma precaução deficiente.

Estas informações corroboram o que Cooter e Ulen (2010) comentam que é mais vantajoso e eficiente a negociação quando os custos impostos por punições ou demandas judiciais são superiores aos custos do não cumprimento das cláusulas contratuais. Esta negociação, inclusive, pode gerar um excedente devido à economia de custos de transação, a chamada barganha sendo que este excedente pode ser dividido entre as partes gerando um incentivo a mais para a conclusão dos serviços.⁷⁷

⁷⁴ Traduzido livremente de: “Economic analysis of law currently offers at least three distinct paradigms of the influence of legal rules on behavior. According to the economic analysis of legal duties, agents consider the consequences of violation of a legal rule in choosing their actions. The economic analysis of property rights argues that different distributions and bundling of entitlements will induce different behaviors. The public choice perspective focuses on the agents’ attempts to determine the legal rules they face”. Idem.

⁷⁵ Ibidem, Pp. 39-40.

⁷⁶ Ibidem, p. 36.

⁷⁷ SILVA, Marcos José da. **Economia das Licitações, a Contratação de Obras e Reformas em Prédios Públicos: O caso da UFRGS**. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Economia da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Economia. Orientador: Prof. Dr. Giacomio Balbinotto Neto. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Porto Alegre, 2018. p. 34.

Com o caso dos contratos públicos em mente, estes podem ser entendidos, na prática, como um jogo de final fechado, mesmo quando se repetem. Isso acontece porque para o contratado, não importa a sua performance no contrato atual, ela não afetará a forma pela qual a seleção de futuros contratantes ocorrerá, de forma que sua má-performance não será punida em uma rodada seguinte, pois a Administração Pública não possui meios de evitar a reentrada do jogador no futuro.

Supondo que um particular vença uma licitação, realize o objeto do contrato de forma pouco satisfatória, e mesmo que sofra alguma sanção contratual, pode ser que o preço da sanção, em comparação com a economia obtida por meio da performance fraca, seja baixo, nesse caso, na próxima licitação, nada impedirá que ele participe e ganhe novamente, repetindo o ciclo, sem que a Administração possa se livrar do contratado ruim. Então, embora o jogo seja, de alguma maneira repetitivo, por conta do método de contratação da Administração, ele acaba sendo convertido em um jogo de rodada única, criando incentivo para o desvio do contratado.

Nesse cenário, as normas jurídicas devem servir para, depois de percebido como os agentes desenvolvem a sua barganha, alinhar os incentivos entre as partes de forma a beneficiar comportamentos mais eficientes, capazes de maximizar a riqueza como um todo, preferencialmente a partir de um modelo Paretiano, quando dentro de uma dinâmica contratual.

2.2.2. Custos de Transação em Contratos Administrativos.

Acima, falou-se brevemente sobre a teoria econômica dos contratos e os custos de transação. Neste tópico, busca-se detalhar um pouco mais sobre sua natureza e como se pode entendê-los no contexto de contratos administrativos.

Como o próprio nome sugere, eles são os custos inerentes à realização de transações, ou seja, são instrumentais à própria realização de uma operação. Explicados de forma mais extensa:

Os custos de transação podem ser definidos como os custos para estabelecer, manter e utilizar os direitos de propriedades, ou seja, para transacionar; custos de formação de contratos, de monitoramento e imposição de contratos, de acesso à informação, etc.⁷⁸

⁷⁸ KLEIN, Vinicius. Teorema de Coase. In: RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; KLEIN, Vinicius (coord.). **O que é Análise Econômica do Direito: Uma Introdução**. 2ª Edição. Belo Horizonte, Editora Fórum, 2016, Pp. 67-68.

Os custos de transação são formados, precipuamente, a partir de três espécies de despesas: “(1) custos da busca para a realização do negócio, (2) custos da negociação; e (3) custos do cumprimento do que foi negociado”⁷⁹. No primeiro grupo incluem-se os gastos de barganhar o preço, encontrar um parceiro comercial, eventuais anúncios, custos para obter informação sobre um produto. No segundo, inclui-se o tempo de negociação, os gastos para as partes se encontrarem, discussões entre as partes em relação a alguma informação. Finalmente, no terceiro grupos, é possível computar os custos de fiscalização dos pagamentos, de cumprimento de eventuais cláusulas contratuais relativas à execução do contrato.⁸⁰

Visto isso, parece claro como o sistema legal deveria funcionar para reduzir os custos de transação, facilitando as trocas voluntárias, portanto que os bens fluíssem de forma mais fácil àqueles que mais os valorizam.

Frequentemente ignorados pela literatura do Direito Administrativo, eles

... são significativos e pouco avaliados na contratação pública, notadamente na fase interna (ou preparatória) da contratação, que antecede, portanto, a licitação, considerando a necessidade, por parte do setor público, de promover estudos e pesquisas visando a correta descrição dos objetos de contratação e a elaboração do Edital do certame em conformidade com a legislação de regência. Além disso, outro representativo custo de transação do setor público é a manutenção de um aparato administrativo capacitado e permanente para o acompanhamento do processo de compra (licitação, contratação, execução e fiscalização dos contratos).⁸¹

Ou seja, eles são pouco avaliados e ainda menos considerados no contexto das compras públicas⁸², geralmente não se leva em conta os custos de se treinar e manter um corpo técnico (que pode incluir engenheiros em casos de obras públicas) capacitado para lidar com as diversas avenças estatais.

Em estudo sobre a contratação de obras e reformas na UFRGS, Marcos José da Silva, a partir da utilização do parâmetro hora/funcionário, conclui que, em média, no caso estudado, o custo operacional médio de uma licitação seria de 1.60% do custo

⁷⁹ COOTER, Robert; ULEN, Thomas. **Direito & Economia**. Op. Cit., p. 105.

⁸⁰ Idem.

⁸¹ DIAS, Maria Tereza Fonseca. **Análise Econômica do Direito nas Contratações Públicas: estudo de casos da legislação e experiência brasileira**. Op. Cit. pp. 10-11.

⁸² Ibidem, p. 11.

total médio de realização de uma obra e reforma na unidade.⁸³⁻⁸⁴ O problema acaba agravado na medida em que os custos são ampliados a partir do aumento do número de licitantes, uma vez que cada particular acaba incorrendo nos custos necessários para participar do certame.

Patrícia Helena Murta Lemos, ao estudar os custos de transação no pregão eletrônico, por muitos considerada a modalidade mais econômica de licitação, elenca cinco categorias de custos transacionais nele presentes: (i) informação, por conta da necessidade de elaborar editais e especificações técnicas de forma clara em critérios e textos objetivos, e com frequência, os licitantes não analisam de forma adequada todas as informações do contrato, focando-se, somente nas relacionadas aos preços de produção ou entrega do bem ou serviço; (ii) tecnologia, por duas razões, primeiro por questões de indisponibilidades temporárias no sistema virtual, e pela necessidade da Administração constantemente pesquisar avanços tecnológicos para evitar a aquisição de bens e serviços obsoletos; (iii) fatores econômicos, entre os quais a autora inclui elementos macroeconômicos e as cláusulas exorbitantes; (iv) segurança jurídica, relacionada a escassez de agentes públicos aptos e motivados para atuar em procedimentos licitatórios, bem como pela falta de recursos para o treinamento adequado dos mesmos, tendo em vista a multiplicidade de normas (leis, decretos, instruções) regentes do tema, sendo, ainda, insuficiente o efetivo de funcionários para a fiscalização adequada dos processos de contratação; (v) riscos e incertezas, ligados a possíveis discontinuidades dos contratos, inclusive por falta de liquidez das contratadas, as quais podem se comprometer além da sua capacidade operacional, problema agravado pelas exigências econômico-financeiras meramente documentais, restringindo a possibilidade de avaliar, *ex ante*, a verdadeira aptidão das empresas, somado a isso, a autora ainda aponta a possível ocorrência de eventos imprevisíveis,

⁸³ SILVA, Marcos José da. **Economia das Licitações, a Contratação de Obras e Reformas em Prédios Públicos: O caso da UFRGS**. Op. Cit. p. 47.

⁸⁴ Em estudo de 2007, o então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, chegou a uma média de 0,9% de custos de cada processo licitatório em relação à média das compras realizadas, não obstante seja possível encontrar órgãos nos quais se atingiu o percentual de aproximadamente 6%. Cf. BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG (2007). **Mapeamento e Análise dos Custos Operacionais dos Processos de Contratação do Governo Federal - Relatório Técnico 12 – Consolidação do Levantamento de Custos**. Disponível em: <https://groups.google.com/group/nelca/attach/384e45db63a7e8/RT%2012%20-%20Levantamento%20de%20custos%20-%20consolidacao%20de%20todos%20os%20custos.pdf?part=0.1> Acesso em 16 de outubro de 2019.

tais como greves setoriais e acidentes de trabalho, os quais podem ensejar responsabilidade subsidiária da Administração Pública.⁸⁵

Embora o estudo tenha se limitado ao pregão eletrônico, é possível inferir a ocorrência dos mesmos problemas em outras searas. Uma vez que o pregão eletrônico é a modalidade mais simples e, teoricamente, com menos custos de transação, é razoável considerar que os mesmos problemas devem ocorrer em outras modalidades de contratação, em especial naquelas nos quais há maior dificuldade de especificação do objeto e de avaliar a capacidade operacional dos licitantes.

2.3. Sistema Brasileiro de Contratações de obras públicas.

2.3.1. O problema das obras públicas no Brasil

Para além das questões relativas às contratações públicas descritas no tópico anterior, os contratos envolvendo obras públicas, no Brasil, representam uma questão especialmente sensível no Sistema Brasileiro de Contratações Públicas, não apenas pela frequência na qual ocorrem problemas no curso da relação contratual, como também pelo montante do prejuízo sofrido tanto pelo Erário quanto pela sociedade, atingida pela privação de estruturas adequadas à prestação dos serviços públicos.

Em auditoria operacional realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SEINFRAURBANA)⁸⁶, cujas partes foram adotadas como relatório do Acórdão n.º 1079/2019 do Tribunal de Contas da União (Processo n.º TC 011.196/2018-1), o qual tinha por escopo avaliar as obras financiadas com o repasse de recursos federais, restou consignado que a própria aferição dos prejuízos causados pela paralisação de uma obra é de difícil realização, pois deve-se somar os custos “relacionados ao desgaste e manutenção das obras, o comprometimento dos serviços já executados e prejuízo ocasionado pela privação dos benefícios assistenciais que o empreendimento viria gerar”⁸⁷.

⁸⁵ LEMOS, Patrícia Helena Murta. **Custos de Transação dos Contratos Administrativos Celebrados Através da Modalidade Pregão Eletrônico**. S.n.t. Disponível em: <https://www.correios.com.br/sobre-os-correios/a-empresa/revista-de-estudo-de-direito-postal-da-ect/edicao-atual/pdf/2016/artigo6.pdf> Acesso em 16 de outubro de 2019. pp. 71-72.

⁸⁶ Órgão do Tribunal de Contas da União, conforme estrutura organizacional disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/institucional/estrutura-organizacional/>

⁸⁷ BRASIL. Tribunal de Contas da União. TC 011.196/2018-1. **Diagnóstico das obras paralisadas. Identificação das principais causas e das oportunidades de melhoria. Recomendações. Monitoramento**. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2019/05/011.196-2018-1-VR-diagnostico-de-obras-paralisadas.pdf> Acesso em: 17 de outubro de 2019.

A Lei n.º 8.666/93, o estatuto geral de licitações do Brasil, delimita, em seu art. 6º, I, o conceito de obra pública para o ordenamento nacional. Entende-se por “Obra – toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta”. O Tribunal de Contas da União, em seu relatório, ressaltou que não há uma correspondência unidimensional na relação entre contratos e obras. Isto é, a um contrato, podem estar ligadas uma ou mais obras, enquanto, por outro lado, uma mesma obra pode ser regida por mais de um contrato.

O relatório do mencionado acórdão, inicialmente, delimita o que considerou como “obra paralisada”, pois se trata de conceito não uniforme dentro da Administração Pública⁸⁸. Nesse sentido, considera-se:

Paralisado: contrato que obedeça a qualquer dos seguintes critérios:

- a. Declaração pelo órgão como paralisada;
- b. Declaração da empresa executora de que não dará continuidade à obra.
- c. Baixa execução física do contrato. Considera-se baixa execução aquele contrato que durante 3 meses avança menos que 10% da evolução física prevista inicialmente.
- d. Não houver novas medições de serviços em período superior a 90 dias. Não devem ser admitidas como medições que alterem a classificação dos contratos aquelas que se refiram apenas a manutenção do canteiro e/ou administração local.(grifos no original).⁸⁹

Destacou-se que um dos critérios utilizados para classificação de uma obra como paralisada é a falta de avanço prático em sua execução. Portanto, “falsos avanços” também são computados como paralisação. Do contrário, seria possível distorcer, de forma relativamente barata, os dados, escamoteando obras que, na prática, não progridem.

Dito isso, a partir da análise de uma série de dados⁹⁰, segundo a auditoria de operação:

⁸⁸ Para o TCU, “A falta de uniformização desse conceito compromete a transparência e pode prejudicar a tomada de decisões, bem como a priorização da alocação dos recursos para aqueles projetos que gerarão mais benefícios à sociedade. Ibidem, p. 5.

⁸⁹ Ibidem, pp. 5-6;

⁹⁰ “As bases de dados analisadas foram as seguintes: a. Órgãos Públicos – Acompanhamento de Obras – TCU da Caixa Econômica Federal (CEF) – abril/2018; b. Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (MEC) – abril/2018; c. Fundação Nacional da Saúde (Funasa) – abril/2018; d. Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – fevereiro/2018; e. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) – abril/2018.” Ibidem, p. 6.

Observa-se que, dos 38.412 contratos consolidados, cerca de 14 mil se encontram paralisados, representando cerca de 37,5% das obras que deveriam estar em andamento. Os valores totais previstos destes contratos paralisados somam R\$ 144 bilhões. Em capítulo posterior será analisado o valor já investido nesses instrumentos.⁹¹

Para colocar o problema em perspectiva mais ampla, reproduz-se a tabela elaborada pela auditoria com os dados relativos ao andamento das obras analisadas (grifos no original):

Tabela 1 Situação dos contratos relacionados a obras do diagnóstico consolidado.

Situação	Quantidade de Contratos	Investimento	% Quantidade	% Investimento
Em reformulação	540	R\$ 204.988.942,85	1,54%	0,03%
Adiantada	950	R\$ 957.961.227,72	2,47%	0,13%
Atrasada	2.700	R\$ 4.105.680.314,13	7,03%	0,57%
Normal/em execução/ em obras/ativo	19.728	R\$ 575.829.146.944,31	51,36%	79,37%
Obra iniciada sem medição	41	R\$ 44.541.721,12	0,11%	0,01%
Paralisada/inacabada	14.403	R\$ 144.314.132.476,62	37,50%	19,89%
Total Geral	38.412	R\$ 725.456.451.626,74	100%	100%

Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas da União. TC 011.196/2018-1. Diagnóstico das obras paralisadas. Identificação das principais causas e das oportunidades de melhoria. Recomendações. Monitoramento. p. 8.

Com isso, os dados indicam que mais de um terço das obras públicas no país estão paralisadas, somadas a mais 7% de obras em atraso, se está diante de um problema crítico, conforme reconhece o TCU:

Em face da criticidade do problema das paralisações de obras públicas acima apresentado e de sua permanência ao longo do tempo, bem como da complexidade e transversalidade das causas envolvidas, entende-se que deve ser objeto de um esforço de caráter mais permanente por parte dos diversos atores envolvidos, visando o desenvolvimento, intercâmbio e compartilhamento de conhecimentos a respeito de paralisações e retomadas de empreendimentos.⁹²

⁹¹ Ibidem, p. 8.

⁹² Ibidem, p. 9.

Outro aspecto agravante do problema em análise é a dificuldade de se mensurar a verdadeira extensão dos prejuízos. Para além dos montantes investidos nas construções paralisadas, as estruturas já edificadas ficam vulneráveis a intempéries e danos de toda sorte (climáticos, vandalismo, furtos) e acabam se deteriorando, gerando novos custos para reformar uma estrutura que sequer foi completada, além dos materiais estocados, suscetíveis ao perecimento, demandando nova aquisição⁹³. Além desses danos mais concretos, deve-se computar como prejuízo o prolongamento na deficiência cujas obras visavam a endereçar, por exemplo, a falta de creches⁹⁴ e a falta de saneamento básico⁹⁵, além do desaquecimento da economia, uma vez que o setor da construção civil responde por parte considerável das circulações de riquezas no Brasil.

Mais ainda, há os custos de oportunidade da paralisação de tais ativos. Ou seja, os recursos destinados a estas obras paralisadas poderiam ter sido empregados de maneira diferente, atendendo verdadeiramente às necessidades dos contribuintes.

Para ilustrar o problema, destaca-se a situação de cinco obras grande vulto, e grande importância socioeconômica: (i) Usina Termonuclear de Angra 3, paralisada desde 2015; (ii) Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ), estagnado desde 2015; (iii) Porto de Salvador (ampliação do quebra-mar), desde 2017 inerte; (iv) Ferrovia Norte-Sul (FNS), com trechos paralisados desde 2018; (v) Ferrovia de integração Oeste-Leste (FIOL), desde 2017 com trechos inativos. Conjuntamente, já foram investidos mais de 15 bilhões de reais em tais infraestruturas, atualmente sem continuidade.⁹⁶

Ao estudar as causas, a Corte de Contas da União conclui que três razões respondem por “80% das paralisações em termos quantitativos e cerca de 71% em termos de volume de recursos. São elas: a) abandono pela empresa; b)

⁹³ Nesse sentido: “Há ainda o custo associado ao desgaste das obras que permanecem por muito tempo sem execução, com suas estruturas sob a ação de intempéries. Em alguns casos, a obra não pode ser retomada sem intervenções para recuperar os estragos decorrentes do abandono, e tais medidas envolvem custos adicionais incorporados ao valor total da obra.” Ibidem, p. 15.

⁹⁴ Neste caso: “Considerando, assim, a quantidade de obras paralisadas, tem-se quase 75 mil vagas que deixaram de ser criadas em virtude da não conclusão dos empreendimentos. Esse número prejudica o atingimento da meta 1 do Programa Nacional de Educação (PNE), que se refere a ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o fim da vigência do PNE, em 2024.” Ibidem, p. 17.

⁹⁵ Quanto ao saneamento básico: “Exemplo disso, segundo Frischtak, as obras paradas nos três municípios com os piores índices de saneamento no País — Ananindeua (PA), Nova Iguaçu (RJ) e Jaboatão dos Guararapes (PE) — implicam o dobro de gastos com saúde. As cidades têm projetos inacabados no valor de R\$ 147 milhões enquanto os custos com internações e afastamento do trabalho por doenças transmitidas pelo mosquito *Aedes Aegypti* somam R\$ 300 milhões. O estudo demonstra que as paralisações nas obras de saneamento impactam diretamente a saúde da população” Idem.

⁹⁶ Ibidem, p. 52.

orçamentário/financeiro, e; c) técnico.”⁹⁷, em respectivamente 23%; 10% e 47% das obras paralisadas.

A nomenclatura aberta das paralisações por motivo “técnico” acaba abrangendo uma série de categorias⁹⁸, com as duas principais sendo sobrepreço/superfaturamento e projeto básico deficiente, inexistente ou desatualizado.

Uma das razões atribuídas à baixa qualidade dos projetos básicos é o incentivo aos políticos para anunciarem obras de forma mais célere, a fim de o fazerem antes do período eleitoral, o que acaba açodando o planejamento, feito às pressas para adiantar o anúncio das obras.⁹⁹⁻¹⁰⁰

Atribui-se, ainda, à baixa capacidade técnica dos entes menos abrangentes, especialmente municípios menores, para fiscalizar a execução de um contrato de obra pública. Assim, frequentemente, o Poder Público encontra dificuldades em acompanhar de forma adequada o andamento de suas obras por falta de corpo técnico devidamente capacitado.¹⁰¹

Com isso, a Administração Pública vive hoje com um grande passivo de compromissos estruturais, cuja consequência

(...) tem sido um ciclo vicioso no qual, conhecendo a incapacidade de execução e de avanço físico dos compromissos assumidos, o poder público continua iniciando novos empreendimentos cuja execução acaba se estendendo por períodos muito superiores aos previstos, criando um enorme passivo de compromissos que não se sustenta ao longo do tempo.

Em outras palavras, conhecendo o baixo percentual de sucesso, dá-se início a um número excessivo de empreendimentos, na expectativa de que somente uma parcela seja realizada, mas essa lógica tem resultado em alto grau de ineficiência, desperdício e sobrecarga

⁹⁷ Ibidem, p. 20.

⁹⁸ Ibidem, p. 24.

⁹⁹ Ibidem, p. 25.

¹⁰⁰ Trata-se de problema complicado, igualmente, em razão da ligação entre as obras públicas e o ciclo orçamentário. Pois como o chefe do Poder Executivo somente irá elaborar seu Plano Plurianual, refletindo seus planos de governo, ao final do primeiro ano de governo. Dessa forma, ele só terá dois anos e meio, em razão do período eleitoral, para planejar e executar as licitações, celebrar contratos e executar as obras.

¹⁰¹ Nesse sentido: “muitos municípios não possuem profissionais para atender a demanda. Por vezes, quando o ente dispõe de profissionais, estes não possuem competência técnica para atender as exigências de uma obra pública. Há diversos fatores que condiciona essa limitação, sendo um dos mais críticos a alta rotatividade de pessoal associada à dificuldade de se atrair e fixar profissionais qualificados em localidades mais afastadas dos grandes centros” e “Um problema recorrente verificado nos órgãos que atuam com a execução de obras públicas, seja de forma direta ou indireta, é a escassez de recursos humanos e tecnológicos para gerenciar adequadamente a carteira de projetos. No entanto, há uma grande pulverização de iniciativas que consomem recursos de forma pontual e ineficiente.”. Ibidem, p. 33; 41.

administrativa, quando a racionalização do processo apontaria no sentido da redução do número total de iniciativas, com aplicação de critérios mais rigorosos, buscando um maior percentual de sucesso entre as propostas selecionadas¹⁰².

Portanto, atualmente, o Poder Público não consegue resolver seu passivo, prejudicando sobremaneira a sua capacidade de investimento e de assumir novos compromissos, gerando incerteza no mercado e oferecendo pouco para os contribuintes.

2.3.2. A Lei 8.666/93 e a Captura do seu Processo Legislativo.

A Lei n.º 8.666/93 representa o marco fundador do atual sistema de compras públicas brasileiro, tratando de forma minuciosa de diversos tipos de contratos e licitações. Embora a norma, na qualidade de Estatuto Geral das Contratações Públicas, não se limite a tratar apenas de contratos de obras públicas¹⁰³, entende-se por começar por ela a análise do sistema nacional de contratação de obras públicas.

Conforme já citado acima, a própria lei define, em seu art. 6º, I o conceito de obra pública. Porém, mais do que apresentar o que a lei diretamente expressa, considera-se relevante que, por trás das intenções de controle do administrador público, acabou ocorrendo uma captura camuflada do processo legislativo, resultando em uma norma pouco eficiente tanto para a contratação de boa qualidade em favor da Administração como também para o controle de corrupção nos processos licitatórios.

Para compreender melhor a norma em questão, André Rosilho pesquisou o processo de gênese da lei, a primeira relativa a contratações públicas editadas em ambiente democrático, a partir dos seguintes questionamentos:

Assim, tendo-se em mente a transparência inerente ao processo legislativo democrático, emergem as seguintes dúvidas: como, de fato, surgiu a Lei nº 8.666/93? O que motivou a reforma? O que preocupava o legislador à época? Objetivou-se melhorar a gestão pública ou tornar as compras governamentais mais eficientes? Como

¹⁰² Ibidem, p. 31.

¹⁰³ Assim entendidos como: “*Contrato de obra pública*: é aquele no qual a Administração Pública contrata a execução de determinada obra, com a remuneração do particular advindo dos próprios cofres públicos, sendo que a definição de obra é prevista no art. 6º da Lei 8.666/93” (grifos do autor). GARCIA, Flávio Amaral. **Licitações e Contratos Administrativos: Casos e polêmicas**. Op. Cit. p. 351.”

se desenvolveu o atual sistema de contratações? É possível observar a atuação de grupos de interesses no processo legislativo?¹⁰⁴

Para o presente estudo, há mais valor em focar na questão de existência (ou não) de grupos de interesses direcionando o processo legislativo para atingir objetivos próprios. Essa prática é chamada de *Rent Seeking*¹⁰⁵, uma espécie de falha de governo¹⁰⁶

Gordon Tullock, Arthur Seldon e Gordon L. Brady¹⁰⁷, o descrevem como o uso de recursos com o objetivo de obter rendas (*rents*) para pessoas nas quais a renda, per si, é oriunda de uma atividade com valor social negativo¹⁰⁸. Exposto de outra forma, a expressão pode ser entendida como a obtenção de lucros, apesar de legais, de efeitos perniciosos para a sociedade como um todo¹⁰⁹, a partir de métodos que podem ser ora legais ora ilegais.¹¹⁰

Trata-se de um problema relacionado à atuação de grupos de interesses. Há a tendência à organização em tal categoria quando se está diante de uma coletividade relativamente pequena cujo benefício ou prejuízo advindo da política em debate

¹⁰⁴ ROSILHO, André Janjácómo. **Qual é o Modelo Legal das Licitações no Brasil? As reformas legislativas federais no sistema de contratações públicas**. Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, como requisito parcial para a obtenção do título de MESTRE no Programa de Mestrado em Direito e Desenvolvimento. Orientador: Prof. Dr. Carlos Ari Sundfeld. São Paulo, 2011. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8824/20111018%20-%20Vers%C3%A3o%20Final%20Disserta%C3%A7%C3%A3o%20%28dep%C3%B3sito%29%20.pdf>. Acesso em 03/07/2018., p. 73.

¹⁰⁵ Optou-se, por motivos estilísticos e para facilitar a compreensão de mais leitores, em manter os termos em seu idioma original.

¹⁰⁶ As quais ocorrem “quando o governo cria ineficiências porque interferiu quando não deveria ou quando poderia ter resolvido determinado problema ou conjunto de problemas de forma mais eficiente, ou seja, gerando maiores benefícios líquidos” WINSTON, Clifford. “Government Failure vs. Market Failure: Microeconomics Policy Research and Government Performance”. Disponível em: <https://www.brookings.edu/research/government-failure-vs-market-failure-microeconomics-policy-research-and-government-performance/> Acesso em 19/02/2019

¹⁰⁷ TULLOCK, Gordon; SELDON, Arthur, BRADY, Gordon L. **Government Failure: a primer in public choice**. Catho Institute. Washington, DC. 2005. Pp. 29-51.

¹⁰⁸ Ibidem, p. 43.

¹⁰⁹ Um exemplo clássico capaz de facilitar a compreensão é o uso de tarifas alfandegárias para proteger empreendedores ineficientes. Nesse caso, no lugar de melhorar seu processo produtivo para competir com agentes internacionais, o privado busca, a partir de uma ação estatal juridicamente legítima, se proteger da concorrência, causando prejuízos para os consumidores, que não terão acesso aos produtos estrangeiros potencialmente melhores e mais baratos.

¹¹⁰ O *rent seeking* pode ocorrer de duas maneiras diferentes. A mais aberta, através de transferências diretas, quando um grupo recebe benefícios financeiros do erário público, mediante subvenções diretas, ou de forma menos ostensiva, por meio de um regime regulatório mais favorável a determinado grupo de agentes econômicos.

poderá ser grande,¹¹¹ há a busca de lucros às custas da sociedade como um todo. Tullock, Seldon e Brady sintetizam o conceito da seguinte maneira:

O conceito de *rent seeking* como popularmente compreendido refere-se às atividades legais ou ilegais para obter privilégios especiais, como a aquisição do status de monopolista, zoneamento especial, restrições quantitativas em importações, tarifas protecionistas, subornos, ameaças e contrabando. Até muito recentemente, economistas argumentavam que privilégios estatais, monopólios e assim por diante, não eram muito custosos para a sociedade.¹¹²

O processo legislativo da Lei n. 8.666/93 é um exemplo de como o *rent seeking* pode ocorrer na prática. O contexto político da reforma do estatuto licitatório foi o de emergência e confirmação de suspeitas de irregularidades, compras superfaturadas e corrupção descontrolada na administração do então Presidente Fernando Collor. A crise institucional e política aguda culminou com o seu *impeachment* e abriu a “janela de oportunidade para que fosse alterado o diploma normativo que regulamentava justamente o grande foco de corrupção do momento: as contratações públicas”¹¹³

Nesse cenário, o processo legislativo do PL 1.491/1991, embrião da Lei n. ° 8.666/93, foi marcado pela disputa entre duas correntes legislativas, uma maximalista e a outra minimalista. A primeira defendia um modelo normativo capaz de antever, o máximo possível, as alternativas decisórias do administrador, já deixando pavimentado o caminho para uma (suposta) boa contratação. Por sua vez, o grupo rival sustentava paradigma diametralmente oposto, no qual apenas as diretrizes fundamentais e os elementos mais essenciais à realização das licitações deveriam estar previstos em lei, evitando o casuísmo, permitindo que as decisões pontuais fossem tomadas em âmbito administrativo.¹¹⁴

Como o texto minucioso e detalhista da Lei n. ° 8.666/93 sugere, a facção maximalista prevaleceu, sob as seguintes justificativas:

¹¹¹ TULLOCK, Gordon; SELDON, Arthur, BRADY, Gordon L. **Government Failure: a primer in public choice**. Op. Cit. Pp. 37-38.

¹¹² Livremente traduzido de: “The concept of rent seeking as popularly perceived refers to legal and illegal activities to obtain special privilege such as seeking monopoly status, special zoning, quantitative restrictions on imports, protective tariffs, bribes, threats, and smuggling. Until quite recently economists argued that government privileges, monopolies and so on were not very costly to the society”. Ibidem, p. 44.

¹¹³ ROSILHO, André Janjácomo. **Qual é o Modelo Legal das Licitações no Brasil? As reformas legislativas federais no sistema de contratações públicas**. Op. Cit., p. 76.

¹¹⁴ Ibidem, p. 84.

Não porque há mais parlamentares que, no plano das ideias, defendem a existência de um modelo legal de licitações públicas do tipo maximalista, mas porque eles tiveram que assumir uma postura pragmática. Tendo-se em vista que o modelo legal que estava sendo votado pelo Congresso Nacional já era do tipo maximalista, aos congressistas restou a possibilidade de trabalharem com o produto que tinham em mãos, ajustando-o da maneira que achassem mais conveniente.¹¹⁵

O pragmatismo empurrou a maioria parlamentar para o maximalismo, bem como o momento político, no qual um diploma legal mais rígido para o administrador seria visto como um escudo para fraudes futuras.

Contudo, André Rosilho argumenta a favor de outra possibilidade, a captura¹¹⁶ do processo legislativo por empreiteiras emergentes.¹¹⁷

Em nossa análise específica, a Lei Geral de Licitações e Contratos não possui, então, normas neutras. A clausura normativa da lei direcionou o mercado de compras públicas para as empreiteiras de médio porte (empreiteiras, à época, emergentes), com capacidade de cumprir suas exigências, especialmente de experiência prévia.

Com o início das discussões quanto à modificação das normas licitatórias, as associações mais organizadas tomaram a dianteira no tabuleiro político; no caso, as empreiteiras emergentes viram uma oportunidade de conduzir o processo legislativo para o atendimento de seus interesses.

Diversos são os indícios desse fato, principalmente nas inovações do novo estatuto de licitações em relação à lei antecessora, o Decreto-Lei 2.300/83. A primeira alteração foi a permissão de parcelamento da execução de obras e serviços. Isto porque

¹¹⁵ Ibidem, p. 88.

¹¹⁶ Para fins de informações teóricas, o argumento do autor supramencionado é a teoria da captura. Tal construção epistemológica, concebida por George Stigler preconiza que, via de regra, todo o arcabouço jurídico regulatório é encomendado pela própria indústria regulada, assim, toda a regulação é arquitetada e operacionalizada para atender aos interesses dos regulados. O caso em questão parece confirmar a teoria. Uma vez que os regulados, ou pelo menos um grupo deles, utilizou sua influência política para obter uma legislação favorável à manutenção da sua posição no mercado. Todavia, salienta-se a existência de críticas contundentes à teoria da captura, especialmente a de Steven Croley, no sentido de que ela não pode ser superdimensionada e utilizada como um argumento para se questionar a própria existência da regulação como um todo. Nesse passo, para o autor, a teoria da captura seria insuficiente para explicar um percentual elevado das normas regulatórias, pois, em grande medida, elas atacariam os interesses dos agentes de mercado, no lugar de promovê-los. Nesse sentido, vide: STIGLER, George J. The Theory of Economic Regulation. **The Bell Journal of Economics and Management Science**. Vol. 2, nº 1. Rand Corporation. (Spring, 1971), Pp. 3-21; CROLEY, Steven P. Beyond Capture: Towards a new theory of regulation. In: LEVI-FAUR, David. **Handbook on the Politics of Regulation**. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publisher, 2011. Pp. 50-65

¹¹⁷ ROSILHO, André Janjácomo. **Qual é o Modelo Legal das Licitações no Brasil? As reformas legislativas federais no sistema de contratações públicas**. Op. Cit, p. 91.

a fragmentação do objeto contratual possibilitou a atuação de empreiteiras de menor escala em projetos antes ao alcance apenas das grandes empresas.¹¹⁸ Assim:

A fragmentação de obras e serviços é um nítido incentivo legal à participação de pequenas e médias empresas – tanto entrantes como aquelas já estabelecidas no mercado. Dessa forma, projetos que, antes, em função de sua magnitude, naturalmente ensejariam a contratação de grandes empreiteiras, agora, poderiam ser levados adiante por um conjunto de empreiteiras menores.¹¹⁹

Mais uma evidência do favorecimento do grupo lobista em questão relaciona-se com os critérios de qualificação econômica e financeira fixados na lei. Reforçou-se o art. 37, XXI da CRFB/88, segundo o qual as exigências de qualificação deveriam ser as estritamente necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações, sem prejudicar a ampla participação no certame. Em decorrência disso, restringiu-se os instrumentos de avaliação de seus futuros contratados pela Administração. Mais uma porta era aberta para as empreiteiras de médio porte.¹²⁰

Soma-se aos indicadores da influência do grupo empresarial o veto presidencial à exigência de comprovação de experiência prévia compatível com o objeto do contrato. Houve a redução dos requisitos técnicos, facilitando a entrada e crescimento de pequenos e médios operadores.¹²¹⁻¹²²

¹¹⁸ Ibidem. Op. Cit. , p. 115.

¹¹⁹ Idem.

¹²⁰ Ibidem, p. 116

¹²¹ Ibidem, p. 117

¹²² Nesse caso, tem-se uma situação interessante a qual pode ser explicada pela teoria econômica da regulação, de Richard Posner. Para o autor, a regulação funciona como um bem (*good*) disponível no mercado, portanto passível de ter uma oferta e demanda, cujo fornecedor seria o governo e os consumidores seriam os grupos de interesse dispersos pela sociedade. Nesse ponto, parece-nos que a Lei n. 8.666/93 acabou moldada por uma mistura de demandas. De um lado, a sociedade como um todo reivindicava maiores mecanismos de controle sobre o procedimento de aquisição de bens e serviços pela Administração, refletindo nas fortes amarras burocráticas da norma. Por outro lado, a indústria conseguiu camuflar demandas próprias no meio dos pleitos sociais, sendo responsável pela inserção de mecanismos que, à primeira vista pareciam elementos bloqueadores de práticas de corrupção, mas acabaram beneficiando a indústria. Em sentido semelhante, Peltzman criticou a conclusão de Stigler sobre reguladores servirem apenas a um interesse (ou grupo de interesse) econômico¹²². O autor desenvolve um modelo econômico para demonstrar como a captura funcionaria na prática. Dessa maneira, uma das conclusões que o autor chega é que a regulação (oferecida como um bem [*good*]) pode variar entre um escopo mais protetivo dos fornecedores (da indústria de modo geral) ou dos consumidores. Compreender essas nuances da teoria da captura (ou da teoria econômica da regulação) nos permite visualizar de forma mais clara como os interesses de grupos privados conseguem penetrar no debate público normativo, visão a qual pode ser ampliada para toda a categoria de normas e seus produtores. Isto é, não apenas as agências reguladoras podem sofrer esse tipo de influência, os próprios legisladores, diretamente, também podem ser manipulados a partir de uma mistura de interesses públicos e privados no debate das escolhas normativas. Nesse sentido, vide: POSNER, Richard A. “Theories of Economic Regulation”. **The Bell Journal of Economics and Management Science**. Vol. 5, nº. 2 (Autumn, 1974). Pp. 335-358; PELTZMAN, Sam. “Toward a More General Theory of

Nesse sentido, é possível destacar quatro características da sistemática da Lei n. 8.666/93 capazes de corroborar a tese da captura camuflada sob interesses públicos.

A primeira delas se relaciona com o modelo procedimental adotado pela norma, com uma fase eliminatória de habilitação prévia ao julgamento das propostas.

Dessa forma, avalia-se apenas as propostas dos habilitados. Duas importantes consequências disto decorrem: limita-se o número de propostas de preço que serão conhecidas pelo poder público e, em virtude da rigidez formal e da demora dos procedimentos, incentiva-se a litigância entre os proponentes – já que eles têm a possibilidade de inabilitar uns aos outros.¹²³⁻¹²⁴

O segundo traço é a imutabilidade das propostas dos licitantes. O lance de cada licitante é apresentado em um envelope fechado, conjuntamente entre todos os concorrentes. A possibilidade de uma rodada de descontos e competição dinâmica fica inviabilizada, “Trata-se, assim, de uma *competição controlada* em que se bloqueia a instauração de disputas acirradas entre os licitantes”¹²⁵.

A terceira característica que sugere a captura da norma em estudo é a figura da proposta inexecutável. Isso porque, no lugar de um expediente para proteger a Administração de licitantes aventureiros, os quais tenderiam oferecer preços irrealmente baixos e proibitivos da execução contratual, tal instituto funcionou como “um freio à competição na medida em que há a possibilidade de ser fixado um piso para os preços, abaixo do qual se presume que o licitante seja incapaz de entregar o objeto contratado.”¹²⁶⁻¹²⁷

Justamente pelo principal grupo de pressão ser o das empreiteiras de médio porte, as disposições sensíveis em relação às obras públicas acabaram sofrendo maior impacto.

Regulation. **The Journal of Law and Economics**. Vol. 19, nº. 2. Conference on the Economics of Politics Regulation (aug. 1976). Pp. 211-240; STIGLER, George J. The Theory of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*. Vol. 2, nº 1. Rand Corporation. (Spring, 1971), Pp. 3-21

¹²³ ROSILHO, André Janjácomo. **Qual é o Modelo Legal das Licitações no Brasil? As reformas legislativas federais no sistema de contratações públicas**. Op. Cit., p. 117.

¹²⁴ Uma alternativa encontrada pelo Pregão foi a inversão de fases, na qual primeiro se escolhe a melhor proposta, forçando a abertura de informações pelos licitantes e apenas ao final haverá a habilitação apenas do vencedor, com isso apenas uma habilitação poderá ser impugnada pelos outros participantes e não há uma tentativa mútua entre todos os licitantes de eliminarem uns aos outros.

¹²⁵ Ibidem, p. 118.

¹²⁶ ROSILHO, André Janjácomo. **Qual é o Modelo Legal das Licitações no Brasil? As reformas legislativas federais no sistema de contratações públicas**. Op. Cit., p. 118.

¹²⁷ A figura da proposta inexecutável, em tese, é pensada para proteger o Poder Público de aventureiros na licitação, ou seja, particulares que oferecem um valor teoricamente abaixo do mercado e impossíveis de serem cumpridos.

Por fim, considerando o tema a ser desenvolvido nos próximos capítulos, deixou-se a temática da captura em relação ao seguro-garantia para concluir o presente tópico. Em relação a tal instrumento de garantia, André Rosilho afirma:

A redação final do PL, tal como visto, determinou que o seguro-garantia fosse mandatório apenas para as obras e serviços de grande vulto; ele seria facultativo às de médio e pequeno vulto. Reforçou-se, ainda, que o poder público não poderia contemplar custo ou valor de cobertura que impedisse ou até mesmo restringisse a participação de qualquer interessado na licitação. Nota-se, assim, que o Congresso Nacional pretendeu, a qualquer custo, impedir que a administração, nas suas contratações, fizesse exigências que fossem prejudiciais aos interesses das empreiteiras de menor porte – em tese, pequenas e médias.¹²⁸

Na realidade, mais do que seu âmbito reduzido, a previsão do seguro-garantia foi vetada pelo poder executivo¹²⁹. Porém, ressurgiu nas reformas legislativas imediatamente posteriores à edição da Lei n.º 8.666/93.¹³⁰

Qualifica-se, todavia, como tímido seu ressurgimento, pois, conforme deixa claro o texto atual, a norma impôs o teto de 10% do valor da contratação, isso apenas para os casos de projetos complexos e de grande, do contrário o limite fixado foi de apenas 5%.¹³¹⁻¹³² Na realidade,

¹²⁸ Ibidem, p. 116.

¹²⁹ No dispositivo original o art. 56, II incluía o seguro garantia no rol de garantias apresentáveis à Administração, enquanto o §3º previa a sua obrigatoriedade para obras de grande vulto e a possibilidade de ser exigido em obras de médio e pequeno porte, desde que justificada por parecer técnico, com o seguinte texto: “§3º O seguro-garantia será exigido na contratação de obras e serviços de grande vulto, podendo, ainda ser exigido na contratação de obra e serviço de médio e pequeno vulto, desde que a sua necessidade seja justificada em prévio parecer técnico constante do processo, e, principalmente, não contemple custo ou valor de cobertura que impeça ou restrinja a participação de qualquer interessado e que atenda aos demais requisitos do instrumento convocatório.” Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Vep335-L8666-93.pdf; Acesso em 14 de dezembro de 2019.

¹³⁰ Destaca-se o fato de haver a previsão do seguro garanti já no Decreto-Lei 2.300/1986, no art. 46, §1º, 3, o qual era limitado, como todas as espécies de garantia, ao máximo de 5% do valor do contrato, sem a possibilidade de ampliação ao patamar de 10%.

¹³¹ A lei 12.462/2011 incluiu, em seu artigo 4º, a possibilidade de utilização de garantias compatíveis com o mercado privado, o que nos leva a crer na possibilidade de extrapolar os limites do art. 56 da lei n. 8.666/93, tendo em vista o vulto da contratação em questão. O Tribunal de Contas, discordando de sua unidade técnica, admitiu a possibilidade da superação de tais limites. Nesse sentido: “Acredito, pelo que expus, que a contratação integrada tenha criado um novo cenário factual e mercadológico, então não coberto pelas possibilidades então previstas pelo art. 56 da Lei de Licitações, em seu rol de garantias. Desde que devidamente motivado e proporcional aos riscos assumidos, pode-se superar aqueles limites. Nesse ponto, entendo não haver reprimendas ao instrumento editalício criticado” em TC-012.242/2013-6.

¹³² Por outro lado, na Lei n.º 13.303/2016 (Estatuto Jurídico da Empresa Pública), em seu artigo 70, manteve os limites percentuais da Lei geral de licitações (5% como regra e 10% para contratos de grande vulto, complexidade técnica e riscos financeiros elevados).

Fica evidente a partir da leitura da norma que se evitou contrariar os interesses das pequenas e médias empreiteiras – visto que esta modalidade de seguro não se aplicaria a obras de médio ou pequeno porte e que a Lei a ela impôs um teto –, impedindo que barreiras legais fossem erigidas de modo a bloquear seu acesso ao mercado público.¹³³

Merece uma ressalva o fato de haver, por conta desse percentual tão baixo de cobertura, dúvidas se é mesmo possível falar na existência de *performance bond* no sistema brasileiro de contratações públicas. Trata-se de conclusão que leva em conta uma questão prática: com um percentual tão baixo, muito dificilmente alguma seguradora irá precisar executar o objeto contratual aventado, se limitando a indenizar na proporção da apólice. Assim, a garantia cujo objetivo era levar a seguradora a executar o contrato, garantindo economia procedimental e de tempo para a Administração se converte em apenas mais um mecanismo de indenização do erário.

Em suma, a investida reformadora da Lei n. 8.883/1994 foi freada diante da influência consolidada das empreiteiras emergentes sobre o processo legislativo renovador do estatuto de compras públicas. Portanto, diversos dispositivos da Lei 8.666/93 foram o produto da captura do Congresso Nacional, e aqui destaca-se, pelo objeto da presente dissertação, as normas relativas às garantias das compras públicas, elaboradas, dessa maneira para atender a conveniência de um grupo de interesse específico.

Para além do problema da captura, o Estatuto Geral de Licitações é ineficiente e burocratizado, já que, conforme já ressaltado, foi editado quando a maior preocupação era com os meios, não com os fins da contratação. Era mais importante “verificar o cumprimento das formalidades pelo agente público do que avaliar se a contratação pública concretizava os princípios da eficiência e economicidade. Refletia o direito administrativo do início da década de 1990.”¹³⁴

A norma tinha como propósito disciplinar de forma muito detalhista, todos os estágios da contratação estatal, reduzindo a discricionariedade do gestor ao mínimo necessário, com o objetivo de coibir a corrupção.¹³⁵

¹³³ ROSILHO, André Janjácómo. **Qual é o Modelo Legal das Licitações no Brasil? As reformas legislativas federais no sistema de contratações públicas.** Op. Cit., p. 163.

¹³⁴ GARCIA, Flávio Amaral. **Licitações e Contratos Administrativos: Casos e polêmicas.** Op. Cit. p. 54.

¹³⁵ FREITAS Rafael Veras de, **Análise Econômica das Contratações Públicas.** p. 29

Com isso, a Lei n.º 8.666/1993 acabou criando um sistema com custos de transação endógenos muito elevados, gerando compras, no geral, ineficientes. O que não passou despercebido, pois as modificações posteriores no sistema nacional de compras públicas criaram mecanismos de fuga do procedimento da Lei geral de licitações¹³⁶.

2.3.3. No Regime Diferenciado de Contratação (RDC).

Pensado para os grandes eventos esportivos realizados no Brasil (copa e olimpíadas), o Regime Diferenciado de Contratações acabou sendo ampliado para abarcar uma gama de obras de grande porte, como os referentes ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), ao Sistema Único de Saúde (SUS), instalações prisionais, entre outras.

Além de uma tentativa de melhorar o sistema de compras governamentais, buscando mais eficiência na contratação. Sua criação representa um *institutional bypass*¹³⁷ em relação à Lei n.º 8.666/93, isto é, a partir da sua utilização, pretendeu-se

¹³⁶ Nesse sentido: “Diante de todas essas vicissitudes, desde o início dos anos 2000, teve lugar um movimento de revogação paulatina da Lei n.º 8.666/1993. De fato, na medida em que a revogação integral da LGL teria um custo político muito elevado, a estratégia que se adotou foi a edição de diversos normativos que tinha o objetivo de interditar a sua incidência – o que foi denominado de “fuga da Lei n.º 8.666/1993”. Essa fuga teve início, no âmbito da própria LGL, pela ampliação das hipóteses de dispensa de licitação, previstas no art. 24 do referido diploma, modalidade em que o administrador pode se valer da contratação direta, seja por razões de urgência, seja a bem da economicidade. Tanto é verdade que, por ocasião da edição da LGL, a redação original do art. 24 contava com, apenas, quinze incisos, sendo que, atualmente, esse número cresceu para trinta e três. E prosseguiu pela edição de diplomas contratuais que visavam criar regimes licitatórios com um racional distinto da LGL. Preambularmente, por intermédio da Lei n.º 9.742/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), que, ao prever a modalidade de licitação pregão teve, justamente, o propósito de excluir a incidência da LGL aquele setor regulado. A utilização de tal modalidade de licitação, como se sabe, foi ampliada para toda a Administração Pública Federal, por intermédio da Medida Provisória n.º 2.026/00, e, pela Lei n.º 10.520/2012 para os demais entes federativos. Do mesmo modo, nos contratos de longo prazo, previu-se, por intermédio das Leis de Concessão de Concessão (Lei n.º 8.987/95) e das Parcerias Público-Privadas (Lei n.º 11.079/04), um regime licitatório mais compatível com projetos de infraestrutura. E, por fim, por meio da Lei n.º 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações), pretendeu-se instituir um regime de contratação mais eficiente para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Tal regime foi ampliado para as ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) (incluído pela Lei n.º 12.688/12); para as obras e serviços de engenharia do Sistema Único de Saúde (SUS) (incluído pela Lei n.º 12.745/12); obras e serviços de engenharia em estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativos (incluído pela Medida Provisória n.º 630/13); pode ser utilizado para os recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil (FNAC); para a construção ou reformas de presídios e unidades socioeducacionais para adolescentes infratores (nos termos da Lei n.º 12.980/14”. Ibidem, pp. 17-18.

¹³⁷ Que pode ser conceituado como: “A estratégia ocorre da seguinte forma: a instituição existente é preservada, nos termos em que estava funcionando. Cria-se uma nova instituição, objetivando alcançar os mesmos fins da pré-existente, mas que utilize meios diferentes, uma nova abordagem. Há aí um componente de escolha. O ator que precisa chegar àqueles fins pode eleger qual o caminho pretende adotar: a primeira instituição ou a nova, originária do *institutional bypass*.” GABRIEL, Yasser Reis. O

revogar, de forma paulatina, a norma em questão. O custo político de uma revogação feita de uma vez seria muito elevado, especialmente no atual contexto de operações contra corrupção, dessa maneira, criou-se alguns microssistemas, dentro do complexo normativo das compras públicas, mais eficientes e adaptáveis aos objetos contratados e às entidades que os utilizam.¹³⁸⁻¹³⁹

A própria Lei n.º 12.462/2011, em seu art. 1º, § 1º, I elenca explicitamente como objetivo do RDC “ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes”. Para tanto, criou mecanismos como a remuneração variável, contratação integrada e orçamento sigiloso, as quais não deixaram de ser alvo de polêmicas.

Para Flávio Amaral Garcia, o RDC não pode ser considerado meramente uma nova modalidade de licitação, mas sim, “um novo e especial regime jurídico que se revela alternativo à Lei n. 8.666/93”¹⁴⁰. Contudo, não parece se tratar de um regime totalmente alternativo ao definido no estatuto geral das licitações, nesses termos, uma vez que, subsidiariamente, ainda são aplicáveis algumas disposições de lei geral, especialmente em matéria contratual.

Como salientado acima, uma das principais inovações foi a remuneração variável. O art. 10 da Lei n.º 12.462/2011 prevê tal mecanismo, o qual consiste na possibilidade da contraprestação em favor do particular ser maior em caso de realização eficiente do avençado, a partir da avaliação de parâmetros objetivos, como metas, padrões de qualidade e prazos de entrega.¹⁴¹

O objetivo desse mecanismo é criar incentivos para o particular executar os contratos com o maior zelo possível. A possível crítica a tal instrumento é a necessidade de maior elaboração dos contratos que prevejam a remuneração variável, bem como a verificação, na prática, do atendimento dos parâmetros de qualidade. Como exposto anteriormente, um dos maiores problemas da Administração é ter corpo técnico capaz de elaborar e fiscalizar contratos, dessa forma, o custo para elaborar e fiscalizar esse tipo de contrato deve ser levado em conta na elaboração de cláusulas de

regime diferenciado de contratações: um caso de Institutional Bypass?. **Revista de Direito Público da Economia – RDPE**, Belo Horizonte, ano 13, n. 49, p. 223-246, jan./mar. 2015.

¹³⁸ FREITAS Rafael Veras de, **Análise Econômica das Contratações Públicas**. p. 18.

¹³⁹ No mesmo sentido: “O Regime Diferenciado de Contratações/RDC, instituído pela Lei 12.462/2011, foi ditado em um claro contexto de esvaziamento da Lei 8.666/1993 como diploma legal central do sistema de licitações e contratação pública.” GARCIA, Flávio Amaral. **Licitações e Contratos Administrativos: Casos e polêmicas**. Op. Cit. p. 484

¹⁴⁰ Ibidem, p. 488.

¹⁴¹ Ibidem, p. 499.

variabilidade na remuneração. Ademais, os valores precisam ser adequados de tal maneira que o contratado, de fato, se sinta estimulado a buscar melhores resultados, não apenas de fazer o mínimo para não ser considerado inadimplente, levando em conta em seu cálculo o custo/benefício marginal da ação do particular.

Mais uma inovação polêmica, o orçamento sigiloso (art. 6º da Lei n.º 12.462/2011), o qual na verdade não é propriamente sigiloso, mas simplesmente de revelação postergada, consiste na publicização do orçamento “apenas e imediatamente após o encerramento da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas”¹⁴². Trata-se de mecanismo para reequilibrar a assimetria de informações entre a Administração Pública e os licitantes, os quais não possuem o referencial do máximo de quanto o Poder Público está disposto a pagar pelo contrato, fortalecendo o poder de barganha deste¹⁴³.

Outra inovação cujo objetivo é a melhora na eficiência das contratações estatais é o regime de contratação integrada (art. 9º da Lei n.º 12.462/2011). Nesse tipo de regime, o contratado é responsável pela elaboração não apenas do projeto executivo da construção, mas também por seu projeto básico. Nesse caso,

A premissa é que em determinados objetos a Administração Pública não dispõe de condições de identificar, com precisão, as tecnologias e as soluções técnicas mais adequadas, o que justifica atribuir. Ao contratado o encargo de elaborar os projetos. Portanto, a contratação integrada é o regime de execução de obras e serviços de engenharia indicado nas situações que a Administração não tem como definir previamente a solução mais eficiente no edital. Por isso que deve ser reservada para as obras com maior grau de complexidade e cuja contribuição do setor privado seja decisiva para a definição da melhor solução técnica e econômica para o empreendimento.¹⁴⁴

Dois são os benefícios. O particular, empreiteiro, com maior expertise na elaboração de projetos de engenharia, irá realizar tanto o projeto básico quanto o

¹⁴² Ibidem, p. 503.

¹⁴³ No mesmo sentido: AFONSO, Marjorie Gressler. **A Eficiência do Regime Diferenciado de Contratações Públicas: um estudo comparado entre as licitações dos contratos de recuperação, restauração e manutenção rodoviária do DNIT sob o RDC e sob a Lei no 8.666/93**. Trabalho de Conclusão de Curso, sob orientação da professora Patrícia Regina Pinheiro Sampaio e co-orientação de Thiago Cardoso Araújo apresentado à FGV DIREITO RIO como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito. 2014. p. 12. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/13895/TCC%20MARJORIE%20GRESSLER%20AFONSO.pdf>. Acesso em 22 de outubro de 2019.

¹⁴⁴ GARCIA, Flávio Amaral. **Licitações e Contratos Administrativos: Casos e polêmicas**. Op. Cit. p. 507;

executivo. Ademais, na medida em que a mesma entidade responsável pelo projeto básico irá executar a obra, seus incentivos são para a realização de um projeto básico bem elaborado. Todavia, há um problema para a fiscalização da Administração Pública. Pois se ela sequer possui pessoal capaz para fiscalizar contratos cujo projeto básico foi de sua elaboração, tampouco terá para projetos mais complexos, produzidos por terceiros. Assim, a capacidade de fiscalização do poder público pode, também, ficar prejudicada nesse cenário.

Mais uma polêmica envolvendo o RDC, enfrentada pela ADI n.º 4.655, foi em relação à utilização do instrumento de pré-qualificação, conforme previsão nos arts. 29 e 30¹⁴⁵ da Lei n. 12.462/2011. A Administração Pública, caso entenda conveniente, pode manter uma lista de possíveis licitantes já previamente qualificados, os quais deverão reunir as condições de habilitação exigidas para a execução do objeto contratual licitado. A pré-qualificação não é obrigatória para os agentes, ou seja, mesmo os não pré-qualificados poderão participar do certame.¹⁴⁶

O objetivo do instituto é evitar a necessidade de sempre se realizar a habilitação de licitantes recorrentes, o que permite a “sintetização da habilitação e qualificação e a realização destas fases em momento anterior ao certame”¹⁴⁷, gerando

¹⁴⁵ Art. 29. São procedimentos auxiliares das licitações regidas pelo disposto nesta Lei: I - pré-qualificação permanente; II - cadastramento; III - sistema de registro de preços; e IV - catálogo eletrônico de padronização. **Parágrafo único.** Os procedimentos de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento.

Art. 30. Considera-se pré-qualificação permanente o procedimento anterior à licitação destinado a identificar: I - fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos prazos, locais e condições previamente estabelecidos; e II - bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade da administração pública. § 1º O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para a inscrição dos eventuais interessados. § 2º A administração pública poderá realizar licitação restrita aos pré-qualificados, nas condições estabelecidas em regulamento. § 3º A pré-qualificação poderá ser efetuada nos grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores. § 4º A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação ou técnicos necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes. § 5º A pré-qualificação terá validade de 1 (um) ano, no máximo, podendo ser atualizada a qualquer tempo.

¹⁴⁶ Nesse sentido: “Além de garantir que os licitantes aprovados possam participar de diversas licitações, a pré-qualificação permanente continuará aberta para outros interessados, de acordo com o que dispõe o artigo 30, §1º da Lei n 12.462 e o artigo 81 do Decreto 7.581.” Memorial apresentado pela ABD&E – Associação Brasileira de Direito e Economia, no Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.655. [s.n.t.]. Disponível em:

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/18464/2012_nov_memorial_abde_adi_465_5_reg_dif_de_contratacoes.pdf?sequence=1&isAllowed=y; Acesso em 12 de dezembro de 2019.

¹⁴⁷ Idem.

otimização do uso do tempo, evitando o gasto de recursos tanto da Administração quanto dos particulares em cada licitação.¹⁴⁸

Quanto à eficiência de tal instrumento, em memorial apresentado na mencionada ADI n. 4.655, a Associação Brasileira de Direito e Economia afirmou:

O RDC é eficiente dentro desta lógica, portanto. Como desenvolvido ao longo do memorial, tanto o tempo economizado, quanto o número de vezes que se evita a repetição da fase de habilitação, a partir do uso da pré-qualificação permanente, redundam em uma redução do custo de transação para ambos os polos contratuais em relação à modalidade concorrência, cuidada pela Lei 8.666/93. Constata-se aplicação otimizada da eficiência uma vez que na relação entre poder público e os privados todos se beneficiam pela nova lei.

Assim, sob a perspectiva jurídico econômica da pré-qualificação, o RDC atende ao ditame da eficiência, reduzindo custos de transação e diminuindo o tempo necessário à realização dos certames licitatórios.¹⁴⁹

Em síntese, o Regime Diferenciado de Contratações buscou acelerar o processo licitatório, reduzir seus custos de transação, e, conseqüentemente propiciar a contratação de obras a preços mais vantajosos e de melhor qualidade para a Administração Pública. Todavia, estudos empíricos sobre o tema ainda não concluíram se as mudanças desse novo regime de contratação foram efetivas em cumprir tais objetivos.¹⁵⁰

2.3.4. Um Balanço do Sistema: Falhas de Mercado no Sistema de Contratação de Obras Públicas.

Em tópico anterior, mencionou-se a ocorrência de uma falha de governo (*rent seeking*) no processo legislativo responsável pela criação da atual norma geral de licitações e contratos administrativos.

¹⁴⁸ Cf. “A pré-qualificação permanente no RDC compartilha a mesma lógica de redução dos custos de transação proposta por Coase. Organizar o processo licitatório em uma oportunidade prévia, gerando efeitos em inúmeras situações supervenientes é uma solução análoga a um contrato de longo prazo. Além de representar um ganho de tempo, há uma redução no número de vezes em que tais análises seriam submetidas à Administração Pública. Em vez de se averiguar as qualidades dos licitantes a cada certame, numa situação análoga a contratos de curto prazo, a análise acontecerá *ex ante* para licitações futuras.” Idem.

¹⁴⁹ Idem.

¹⁵⁰ Cf. AFONSO, Marjorie Gressler. **A EFICIÊNCIA DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS: um estudo comparado entre as licitações dos contratos de recuperação, restauração e manutenção rodoviária do DNIT sob o RDC e sob a Lei no 8.666/93.** Op. Cit. p. 42.

Todavia, na prática, é possível encontrar nas licitações, uma vez que representa a ida do Estado ao mercado para obter bens e serviços para suas atividades finalísticas, as falhas de mercado.

Estas podem ser entendidas como “uma situação em que o mercado, por si só, não consegue produzir uma alocação eficiente de recursos”¹⁵¹. Ou seja, os problemas que ocorrem no contexto do mercado real, não a abstração do mercado perfeito, acabam se reproduzindo quando o Poder Público realiza uma licitação.

Pode-se medir o sucesso de um projeto de construção pela sua conclusão dentro do cronograma, de acordo com as especificações projetadas e dentro do orçamento proposto.¹⁵² Tais empreendimentos possuem riscos inerentes¹⁵³, os quais são inevitáveis por um lado, mas, por outro, transferíveis.

2.3.4.1. Assimetria de informação

Assimetria de informação pode ser, simplificada, entendida como um desequilíbrio entre a posse de informação entre as partes de uma relação¹⁵⁴. Ou seja, uma das partes sabe mais sobre o que está acontecendo em comparação com a outra. Patrícia Sampaio e Thiago Araújo a definem da seguinte maneira:

O fenômeno da assimetria de informação corresponde ao fato de que os contratantes, no momento da celebração dos contratos, não dispõem de informações sobre todas as variáveis relevantes à realização do ato. Dessa forma, a escolha é, em realidade, limitada pelo conjunto de informações que a parte conseguiu angariar, de forma que os agentes econômicos apresentam “racionalidade limitada” pelas informações que não possuem.¹⁵⁵

¹⁵¹ MANKIW, N. Gregory. **Introdução à Economia**. Op. Cit. p. 12.

¹⁵² ADNAN, Hamimah; SUPARDI, Azizan. Legal Analysis on Malaysian Construction Contract: Conditional versus Unconditional Performance Bond. **Journal of Politics and Law**. Vol. 2, n.º 3. Malásia, Setembro, 2009, pp. 25-34. p. 27., p. 27.

¹⁵³ Entre os quais é possível citar: questões físicas (condições do solo, materiais, clima); atrasos e disputas (propriedade do local da obra, atrasos das partes); direção e supervisão (ganância, funcionários incompetentes ou não razoáveis, falta de comunicação, erros em documentos); danos pessoais e materiais; fatores externos (mudanças em políticas públicas ou normas, limites financeiros); pagamento (atrasos e contestações, insolvência de alguma das partes); judicialização e arbitragem (atrasos em solucionar disputas, injustiça, incerteza em relação às decisões, custos de obter e executar a decisão), *idem*.

¹⁵⁴ MANKIW, N. Gregory. **Introdução à Economia**. Op. Cit. p. 442.

¹⁵⁵ SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. ARAÚJO, Thiago Cardoso. Previsibilidade ou Resiliência? Notas sobre a repartição de riscos em contratos Administrativos. Op. Cit. pp. 315-316.

A assimetria de informação ocorre em razão de ser custoso, tanto financeiramente, como em tempo (que, em última instância, pode ser convertido para termos financeiros), obter informações.¹⁵⁶

Não necessariamente uma assimetria de informação irá gerar um contrato fora de um ganho Paretiano. Uma das partes pode se precaver de forma eficiente e, mesmo com os custos dessa precaução, se beneficiar do contrato. O problema ocorre quando a parte melhor informada usa essa vantagem, geralmente de forma oculta, para drenar os ganhos conjuntos da transação para si, caracterizando um comportamento estratégico (oportunismo).¹⁵⁷

Um exemplo tradicional para explicar a assimetria de informação é o caso do mercado de carros usados. Ao comprar um carro usado, não há como ter certeza sobre o passado do veículo, nem confiar plenamente no vendedor, uma vez que ele é visto como um agente cujo único objetivo é conseguir o melhor preço possível, mesmo quando o carro não está em condições muito boas. Nesse cenário, a estratégia geral é oferecer um valor menor, se preparando para o pior, pois não é possível distinguir os bons produtos dos ruins. Com isso, há um desestímulo à colocação no mercado de carros usados de boa qualidade.¹⁵⁸

No caso de uma obra pública, o particular executor da obra possui mais informações sobre a sua capacidade de realizar o projeto, o ritmo capaz de empregar na sua execução, a qualidade dos insumos obtidos. Para descobrir tais informações, o Poder Público precisa investir em fiscalização, portanto incorrendo em custos, e nem sempre é capaz de fazê-lo de forma adequada¹⁵⁹, até porque, exatamente para obter

¹⁵⁶ Os custos de obter informação correspondem a uma das dimensões dos custos de transações, e pode ocorrer por diversos motivos, tais como: “The information asymmetry between the parties may stem from many sources. One of them may be an expert or otherwise have special knowledge, the other not. One of them may control appearances on which the other has to rely. Or one may be a large-scale operator with access to scale economies in the acquisition and processing of information (for instance to test complex objects), the other a mere consumer. Or again the information asymmetry may stem from the difficulty for a person effectively to supervise another hired to do a particular job.” MACKAAY, Ejan. **Law and Economics for Civil Law Systems**. Op. Cit., p. 417.

¹⁵⁷ Ibidem, pp. 418-419.

¹⁵⁸ Ibidem, p. 417.

¹⁵⁹ Nesse sentido: “Mas esse maior diálogo com o setor privado na concepção da melhor solução em empreendimentos mais complexos exige cada vez mais conhecimento e investimento no corpo técnico da Administração Pública, a fim de evitar que soluções inadequadas ou ineficientes sejam impostas em razão de uma aguda assimetria de informação”. GARCIA, Flávio Amaral. **Licitações e Contratos Administrativos: Casos e polêmicas**. Op. Cit. p. 507.

maiores benefícios com o contrato, o parceiro privado terá incentivos para dificultar o acesso a tais informações¹⁶⁰.

Por exemplo, a Administração possui algumas dificuldades em fazer pesquisa de mercado, porque muitos agentes privados acabam criando um sobrepreço para compensar lances que poderão dar nas licitações (dificuldade de pedir orçamentos, já que se o privado quiser participar posteriormente da licitação, pode haver algum tipo de confronto entre o preço apresentado na época da pesquisa de mercado e o preço ofertado na licitação).¹⁶¹ Esse cenário não cria incentivos para que os privados ofereçam informações muito precisas na própria fase de pesquisa de mercado.

Especificamente em relação à licitação,

As assimetrias de informação (...) decorrem, entre outras causas: a) das falhas de descrição dos objetos a serem contratados; b) da ausência de informações adequadas, por parte do setor público, da capacidade operacional das empresas no mercado; c) da estrutura de custos da empresa vencedora do certame.¹⁶²

Quando a assimetria de informação ocorre no momento pré-contratual, o problema será de seleção adversa¹⁶³. Ocorre principalmente porque¹⁶⁴ o vencedor da licitação tem, naturalmente, mais informações sobre sua capacidade de execução do contrato, que o ente licitante, o qual tem suas informações limitadas aos requisitos de habilitação previstos na Lei n.º 8.666/93. Portanto há informações ocultas que conduzem a escolhas erradas¹⁶⁵. Entre as consequências desencadeadas pela seleção adversa, é possível citar: dificuldades na execução contratual, bem como atrasos na

¹⁶⁰ É um caso de *ação oculta*, cf.: MANKIW, N. Gregory. **Introdução à Economia**. Op. Cit. p. 442.

¹⁶¹ Muito embora a Administração também possa buscar bancos de preço ou realizar pesquisa direto no mercado para fazer sua cotação,

¹⁶² DIAS, Maria Tereza Fonseca. **Análise Econômica do Direito nas Contratações Públicas: estudo de casos da legislação e experiência brasileira**. Op. Cit., p. 12.

¹⁶³ Pode-se entender a seleção adversa como "...consistente no fato de que, na impossibilidade de o contratante avaliar corretamente as distintas características do produto ou serviço e, portanto, estando presente o risco de a outra parte agir oportunisticamente, o contratante racional optará pelo de menor custo, de forma que, no limite, apenas os produtos e serviços de qualidade inferior terminam por ser comercializados". SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. ARAÚJO, Thiago Cardoso. Previsibilidade ou Resiliência? Notas sobre a repartição de riscos em contratos Administrativos. Op. Cit., p. 317.

¹⁶⁴ Nesse sentido: "... além de decorrente da assimetria das informações entre os contratantes, a seleção adversa decorre, na maioria dos casos, em virtude de: imprecisão na descrição do objeto e de projetos básicos e executivos mal elaborados, sobretudo quando se tratam de obras públicas." DIAS, Maria Tereza Fonseca. **Análise Econômica do Direito nas Contratações Públicas: estudo de casos da legislação e experiência brasileira**. Op. Cit., p. 13.

¹⁶⁵ SILVA, Marcos José da. **Economia das Licitações, a Contratação de Obras e Reformas em Prédios Públicos: O caso da UFRGS**. Op. Cit. p. 17.

entrega da prestação; constantes pedidos de recomposição de preços; escolha de propostas inadequadas ao interesse da Administração, e; judicialização de conflitos¹⁶⁶.

Por outro lado, quando a assimetria de informações ocorre durante a execução do contrato, a falha de mercado será o risco moral (*moral hazard*)¹⁶⁷, uma vez que vence o certame, o licitante, possui incentivos para se comportar de forma oportunista, reduzindo ao máximo os custos da execução do contrato, especialmente a partir do uso de insumos de baixa qualidade¹⁶⁸. Um dos indicativos de risco moral é o fato da empreiteira apenas se mobilizar, contratando funcionários e adquirindo insumos, após se sagrar vencedora do certame, atrasando o início das obras de tal forma a possibilitar um reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos.¹⁶⁹

Outro problema também decorrente da assimetria de informações é o jogo de planilhas, os quais

(...) consistem na manipulação das planilhas orçamentárias com a finalidade de obtenção de lucros extras por parte do licitante vencedor ou para conseguir vencer a licitação de uma maneira desleal em relação aos demais participantes. Isto pode ocorrer devido à assimetria de informações dentre os concorrentes, pois um participante pode ter informações privilegiadas sobre detalhes da licitação, ou ainda, por assimetria de informação entre a Administração Pública e o licitante. Em outras palavras, é um artifício que visa a legitimar o superfaturamento de obras e reformas públicas para auferir vantagens através de contratos Administrativos. (...)

O *Jogo de Planilhas* ocorre quando uma proposta orçamentária contém itens com valores ao mesmo tempo acima e abaixo do preço de mercado, havendo uma compensação que faz com que o valor global fique abaixo do valor de mercado atendendo, no momento [da licitação], ao interesse público.

Num segundo momento, porém, essa proposta pode se tornar onerosa para a Administração Pública, caso haja modificações contratuais de quantitativos que aumentem os itens mais valorizados e diminuam os itens menos valorizados, fazendo com que o valor global da obra contratada passe a ter um valor global acima do mercado.¹⁷⁰

¹⁶⁶DIAS, Maria Tereza Fonseca. **Análise Econômica do Direito nas Contratações Públicas: estudo de casos da legislação e experiência brasileira**. Op. Cit., pp. 13-14.

¹⁶⁷ Assim, "... presentes assimetria informacional e problemas de incentivo, existe o risco de que uma parte termine por agir oportunisticamente, por exemplo, escondendo informações relevantes sobre o produto ou serviço contratado. A possibilidade de produção desse efeito, após a celebração do contrato, ficou conhecida na literatura econômica como o problema do "risco moral" (*"moral hazard"*). SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. ARAÚJO, Thiago Cardoso. Previsibilidade ou Resiliência? Notas sobre a repartição de riscos em contratos Administrativos. Op. Cit. p. 317.

¹⁶⁸ Ibidem, p. 18.

¹⁶⁹ Ibidem, p. 61.

¹⁷⁰ Ibidem, pp. 41-42.

Ou seja, a partir de um ilusionismo de contabilidade, por meio da manipulação de custos unitários das propostas, o licitante consegue vencer a licitação de maneira desleal e, ao mesmo tempo, recebe, no futuro, rendas ilegítimas a partir de aditivos contratuais. Duas são as causas principais do jogo de planilhas: (i) projetos básicos deficientes, como já apontado em tópico anterior; (ii) e informações privilegiadas do licitante e a assimetria de informação em relação à execução do serviço em seu favor.¹⁷¹⁻¹⁷²

Todas essas dificuldades informacionais relativas a contratos públicos acabam colocando a Administração em uma posição de desvantagem contratual, mesmo com as cláusulas exorbitantes, que inclusive são precificadas pelos contratados nas suas propostas. De tal maneira, muitas vezes, a Administração se vê presa em contratos desvantajosos, e refém do contratado, quando ocorre o problema de “*hold up*”.

2.3.4.2. Problema de Hold Up da Administração (ou Administração Refém)

Os problemas de assimetria de informação, e o consequente risco moral, acima mencionados, combinados com a dificuldade da Administração de fiscalizar seus contratos, acabam causando o problema de *hold up* da Administração, caracterizado pela opção do particular por “adotar estratégias não cooperativas, tornando a Administração Pública uma ‘refém’ do contratado”¹⁷³.

Ele pode surgir em consequência dos contratos administrativos envolverem “alocações específicas de ativos, com valores consideráveis, serviços essenciais, objetos completos e, podendo ainda ser de longa duração”¹⁷⁴, combinados com os problemas contratuais já mencionados, quais sejam a “incompletude contratual, assimetria de informações e ausência ou ineficiência da fiscalização”¹⁷⁵.

¹⁷¹ Ibidem, p. 42.

¹⁷² Problema menos frequente é “o *Jogo de Cronograma* que ocorre quando o licitante vencedor aplica um desconto em relação ao preço estimado pelo órgão organizador do certame, sendo sagrado o ganhador da licitação. Entretanto, o licitante vencedor pode, na primeira metade da obra, adotar preços dos serviços sem nenhum desconto. Isto pode indicar o risco da Empreiteira abandonar a obra após executar a parte que mais lhe interessa.” Ibidem, p. 43.

¹⁷³ DIAS, Maria Tereza Fonseca. **Análise Econômica do Direito nas Contratações Públicas: estudo de casos da legislação e experiência brasileira**. Op. Cit., p. 15.

¹⁷⁴ Idem.

¹⁷⁵ Idem.

Patrícia Sampaio e Thiago Araújo, a partir de Giuseppe Colangelo, explicam o *hold up* da seguinte maneira:

Essa exploração extorsiva do agente em situação de dependência econômica é conhecida como *hold up*, ocorrendo, conforme explana Colangelo, “*naquelas hipóteses em que, por causa da dificuldade de encontrar no mercado alternativas satisfatórias, a elasticidade da demanda ou da oferta da parte acusa uma pronta redução em seguida à estipulação do contrato, como efeito da condição de especificidade da relação econômica instaurada entre as partes*”. Para ilustrar a situação, o autor alude à figura do “*sujeito aprisionado no contrato*”, que se encontra “*exposto ao risco de extorsões por parte do outro contratante, o qual, ante a ameaça de por fim à relação tem oportunidade de obter uma modificação nos termos do acordo originário a seu favor.*”¹⁷⁶(Grifos dos autores).

Dessa maneira, Administração acaba ficando refém do contratado de baixa qualidade, dependente do particular para concluir, por exemplo, uma obra, cujo custo financeiro (e político), da não conclusão e dos atrasos será muito elevado, com consequências danosas para a população¹⁷⁷. Com isso, a Administração acaba sendo vítima de jogos de planilha e constantes renegociações contratuais, conforme explicado acima.¹⁷⁸

¹⁷⁶ COLANGELO, Giuseppe. **L’abuso di Dipendenza Economica tra disciplina dela Concorrenza e diritto dei contratti: Un’analisi economica e comparata**. Torino: G. Giappichelli Editore, 2004, p. 32. Apud SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro; ARAÚJO, Thiago Cardoso. Previsibilidade ou Resiliência? Notas sobre a repartição de riscos em contratos Administrativos. Op. Cit. p. 318.

¹⁷⁷ Nesse sentido: “Por outro lado, uma vez realizada a licitação e celebrado o contrato administrativo, a situação, em grande medida, inverte-se, pois o fracasso na execução de um contrato implica, para o poder público, um considerável prejuízo, não apenas em razão do serviço que deixa de ser ofertado à sociedade, mas também reputacional. Ocorre o famoso ‘prometeu, mas não entregou’, o que poderá ter consequências na carreira política do governante. Dessa forma, é esperado que o contratante tenha incentivos a preferir a renegociação ao encerramento do contrato, ainda que formalmente possua garantias que possam ser executadas ou multas que possam ser impostas. Ou seja, no momento pós-licitação, por vezes é o poder público quem se encontra em uma potencial situação de *hold up*, a menos que os incentivos corretos tenham sido adequadamente previstos no contrato.” SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro; ARAÚJO, Thiago Cardoso. Previsibilidade ou Resiliência? Notas sobre a repartição de riscos em contratos Administrativos. Op. Cit. pp. 319-320.

¹⁷⁸ Marcos José da Silva realizou estudo empírico nas obras realizadas na UFRGS e conclui pela ocorrência desse problema nos seguintes termos: “Além disso, Ângelo (2006) comenta que o problema da Apropriação (*The Hold up Problem*), deriva do problema da quase-renda quando uma empresa explora o seu parceiro de negócios tentando negociar os termos do contrato de uma maneira mais favorável somente para uma das partes. Segundo esta teoria, a troca de parceiros quase sempre acarreta lucros menores para quem investiu em ativos específicos em relacionamento, bem como os custos judiciais, os custos de oportunidade⁴ pelo atraso da obra ou reforma e a perda de eficiência no gerenciamento da obra pela troca do prestador do serviço. Uma empresa pode aumentar os seus lucros explorando seu parceiro de negócios quando os contratos são incompletos e quando a transação gera quaserendas para o seu parceiro (LAU, 2017). Este problema aumenta os custos de transação, como, por exemplo, no acréscimo da frequência da renegociação de contratos. Além disso, renegociações frequentes podem estar associadas a atrasos na entrega de produtos ou na prestação de serviços. A tabela 2 evidencia a relação entre o quantitativo das renegociações nos contratos da UFRGS com aditivos/apostilas e a sua relação com os dias de atraso para a conclusão das obras/reformas. Nesta

O problema se assemelha, em boa medida, ao que Ejan Mackaay chama de monopólio no tempo¹⁷⁹, o qual ocorre em contratos de performance não simultânea. No caso de um contrato administrativo, o Poder Público não tem espaço para “demitir” seu contratado, para extinguir o contrato, deve fazê-lo, de maneira geral, por processo administrativo, que pode manter o andamento da obra parado por muito tempo. Ademais, após a remoção do executor do contrato, a Administração deverá realizar novo processo para selecionar um particular para terminar a obra, consumindo mais tempo e recursos.¹⁸⁰ Um indicativo desse fato foi localizado por Marcos José da Silva na UFRGS, especialmente nas licitações com valores abaixo de U\$ 400.000,00, a partir da percepção da ocorrência de muitos termos aditivos nessa categoria de contratos.¹⁸¹

Nesse contexto, a Administração enfrenta o seguinte *trade off*: negociar ou não com as empreiteiras. Se escolher a não negociação, e consequentemente a não realização dos aditivos/apostas¹⁸², há o risco das demandas não resolvidas gerarem complicações, como paralisação das obras e abandono do serviço pelo particular, então, quanto mais aditivos, mais contratos serão concluídos. Todavia, o Poder Público acaba prejudicado na relação custo-benefício desses ajustes, embora atenda às necessidades de infraestrutura, acaba pagando elevado sobrepreço nos contratos.¹⁸³

Em síntese, o problema de *hold up* leva a Administração a se prender em contratos que não mais lhe fornecem muita vantagem. Ela paga por muitos aditivos,

análise consideraram-se somente os Processos finalizados em que ocorreram aditivos/apostas. Observa-se que esta relação indica a existência do problema de *Hold up* na UFRGS, em que as Empreiteiras (Agente) procuram extrair maiores lucros em renegociações com a UFRGS (Principal), com o consequente aumento nos custos de transação em acréscimos financeiros e atrasos na conclusão das obras e reformas.” SILVA, Marcos José da. **Economia das Licitações, a Contratação de Obras e Reformas em Prédios Públicos: O caso da UFRGS**. Op. Cit., p. 30.

¹⁷⁹ “A Monopoly in time arises in contracts with non-simultaneous performance, where one of the parties has performed his side of the deal and is now at the other’s mercy for what is owing to him. A variant of this scheme presents itself where one party has made significant investments in order to fulfill his obligations under the contract and those investments are worthless outside of that contract”. MACKAAY, Ejan. **Law and Economics for Civil Law Systems**. Op. Cit., p. 420.

¹⁸⁰ Isso se reflete em dados empíricos, nesse sentido: “No Tabela 19, constatamos que a média de atraso para as obras e reformas, na relação analisada (valores acima de U\$ 200,00.Mil), está em 348 dias, sendo que a média total de atraso de todos os anos analisados é de 175 dias. Além disso, esta tendência pode refletir um problema de oportunismo das empreiteiras (Hold up), em que as mesmas acreditam ter uma vantagem na negociação sobre a UFRGS, tendo em vista a dificuldade na troca por outro prestador de serviço, bem como o orçamento já empregado.” SILVA, Marcos José da. **Economia das Licitações, a Contratação de Obras e Reformas em Prédios Públicos: O caso da UFRGS**. Op. Cit., p. 71.

¹⁸¹ Ibidem, p. 71.

¹⁸² “... ajustes *ex posts* que representam soluções a demandas surgidas e que foram incluídas no contrato com a finalidade de evitar que o mesmo fosse interrompido e no caso da UFRGS, viesse a assumir os *sunk costs* que são os custos decorrentes da troca de empreiteira.” Ibidem, pp. 73-74.

¹⁸³ Idem.

não previstos no momento inicial da contratação, elevando os custos das obras sem acarretar em melhor qualidade do objeto entregue.

2.3.4.3. Problema de Agência

Uma ocorrência específica da assimetria de informações, *ex post* a celebração do contrato, é o problema de agência¹⁸⁴. Ele se dá quando, no bojo de alguma relação econômica, há um agente e um principal. O primeiro é aquele “que pratica um ato em nome de outra pessoa”¹⁸⁵, o principal, quem, por sua vez é “alguém em cujo nome outra pessoa, chamada agente, pratica algum ato”¹⁸⁶.

Ejan Mackaay, ao tratar sobre relações como o mandato, trata do problema de agência. Para o autor, o:

Oportunismo pode ocorrer em dois níveis. Com foco no mandato, na relação bilateral entre o agente e o principal, ou mandatário e mandante, nos termos da *civil law*, o mandatário pode tentar ludibriar o mandante a se envolver em compromissos indesejáveis do ponto de vista deste, mas lucrativos para o primeiro; inversamente, o principal pode tornar impossível para o agente cumprir sua tarefa com o intuito de privá-lo de suas comissões, enquanto extrai dele a informação que pode para seu – do principal – propósito.¹⁸⁷

O problema de agência deriva, de maneira geral, do fato de o agente se encontrar em posição na qual possui mais informações relevantes sobre o objeto do contrato, de forma que o principal não possui “condições de aferir o nível de esforço despendido pelo agente e este, conseqüentemente, pode procurar auferir alguma renda levando o contrato a um equilíbrio não ótimo”¹⁸⁸. Especialmente quando se pensa no âmbito da Administração Pública, que normalmente não conta com pessoal suficientemente especializado para fiscalizar a execução contratual.

¹⁸⁴ O problema de agência e o risco moral assemelham-se em diversos graus, não obstante, em se tratando de análise de teoria contratual, considera-se relevante apresentá-los de forma separada.

¹⁸⁵ MANKIW, N. Gregory. **Introdução à Economia**. Op. Cit. p. 442.

¹⁸⁶ Idem.

¹⁸⁷ Livrentemente traduzido de: “Opportunism may occur at two levels. To focus on mandate, in the bilateral relationship between agent and principal, or mandatary and mandatory in civil law parlance, the mandatary may trick the mandatory into commitments that are undesirable from the latter’s point of view but are profitable to the former; conversely, the principal may render it impossible for the agent to accomplish its task so as to deprive it of its commission, all the while extracting all the information it can for its own – the principal’s – purpose.” MACKAAY, Ejan. **Law and Economics for Civil Law Systems**. Op. Cit., p. 496.

¹⁸⁸ SILVA, Marcos José da. **Economia das Licitações, a Contratação de Obras e Reformas em Prédios Públicos: O caso da UFRGS**. Op. Cit., p. 19

No contexto das obras públicas, ao vencer um certame, o licitante (agente) passa a agir no interesse da Administração (principal), bastando cumprir o contrato com o mínimo possível de performance, para receber o preço ofertado. Dessa maneira, o principal sofre um prejuízo com o comportamento oportunista do agente.

Prática comum ligada ao problema de agência em obras públicas são as constantes solicitações de prorrogação. Até mesmo antes do início do serviço, o que indica a falta de preparo prévio do vencedor para atender perfeitamente à demanda do contrato, e durante o curso contratual, como forma de prolongar a relação e atingir o termo de mais um ajuste contratual.¹⁸⁹

A identificação da ocorrência desse tipo de problema demonstra que embora haja mecanismos para avaliar o desempenho dos contratados, aparentemente não são suficientes para coibir o seu comportamento oportunista contra a Administração Pública.

2.3.4.4. Maldição do Vencedor

Nem sempre apenas a Administração sai perdendo em cenários de falhas de mercado, eventualmente, o participante mais otimista com relação ao valor do objeto licitado poderá se deixar levar por esse otimismo e acabar numa situação em que ele sofra prejuízos¹⁹⁰. Com isso, sua oferta pode não apenas não gerar lucros para si, como pode até mesmo não cobrir seus custos operacionais, nesse caso, diz-se que ele foi vítima da maldição do vencedor¹⁹¹.

¹⁸⁹ Nesse sentido: “As solicitações de prorrogação antes do início do serviço geralmente ocorrem devido ao fato de as empresas ganhadoras do processo licitatório não estarem previamente preparadas para anteder a todos os itens do contrato. Somente após a assinatura do contrato e o início do serviço é que muitas Empreiteiras vão contratar o pessoal e o material necessários para a realização da obra ou reforma contratadas pela UFRGS (...) Além disso, as Empreiteiras (agente), valendo-se do oportunismo, buscam utilizar o que está previsto em contrato para interesse próprio, como por exemplo, no caso da UFRGS (principal), as Empreiteiras (agente) justificando o imprevisto, solicitam o aumento do prazo de execução dos serviços, porém este prolongamento no prazo do contrato poderá acarretar um reajuste automático anual do contrato, tal possibilidade consta em cláusulas contratuais, desta forma, este comportamento oportunista faz com que possa haver um aumento no prazo para justificar a possível obtenção de um reajuste de valores”. Ibidem, pp. 67-68.

¹⁹⁰ MENEZES, Flávio M. Uma Introdução à Teoria dos Leilões. **Revista de Econometria**. Rio de Janeiro, v. 14, nº. 2, Pp. 235-255, novembro 1994/março 1995, p. 248.

¹⁹¹ É possível explicá-la da seguinte maneira: “fenômeno onde os vencedores do leilão ignoravam as consequências da vitória, pois, segundo os mesmos, a vitória em um leilão só é confirmada se as expectativas do vencedor sobre os retornos que serão obtidos forem correspondidas. Ou seja, de nada adianta um participante apresentar a oferta vencedora se este não obtiver os retornos esperados a fim de recuperar o investimento de sua oferta: ainda que seja o vencedor do leilão, este participante não poderá ser considerado um vencedor, tendo em vista todo o ciclo.” MONTEIRO, Alexandre Almeida.

Nesse sentido,

Suponha que todos os participantes obtêm estimativas não viesadas do verdadeiro valor do objeto (que é evidentemente desconhecido pelos participantes) e que as estratégias de elaboração de lances sejam funções crescentes dessas estimativas. O participante com o maior lance será aquele mais otimista com relação ao valor verdadeiro do objeto. A menos que esse problema de seleção adversa seja incluído no processo de elaboração de lances, teremos uma situação na qual o ganhador poderá sofrer prejuízos (ou atingir um lucro inferior ao normal).

Tal fenômeno tem sido mencionado em leilões de jazidas de petróleo (...), em leilões de direitos de publicação de livros (...) e em disputas pelo controle acionário de empresas.”¹⁹²

É evidente que se trata de uma situação ruim para o particular, que projetou erroneamente sua capacidade de executar adequadamente e dentro de seu orçamento, o objeto do contrato.

Todavia, também há consequências negativas para o Poder Público, pois o particular certamente pleiteará renegociações, ampliando os custos de execução do contrato, ou, no pior cenário, pode simplesmente abandonar a obra. Ademais, há ainda o custo de oportunidade de ter perdido a possibilidade de contratar alguém capaz de adimplir o contrato.

Maldição do Vencedor” (*Winner’S Curse*)? Uma Análise das Ofertas nos Leilões da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Monografia de Bacharelado. Orientador: Prof. Ronaldo Fiani. Instituto de Economia. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Março, 2015. pp. 17-18.

¹⁹² MENEZES, Flávio M. Uma Introdução à Teoria dos Leilões. **Revista de Econometria**. Op. Cit., p. 249.

3. CAPÍTULO 2: Estudo sobre o Performance Bond

3.1. Conceito.

Ao discorrer sobre algum instituto jurídico o qual se pretende aplicar a uma situação concreta, especialmente quando se entende que ele pode ser a solução de algum problema fático relevante, deve-se, inicialmente, defini-lo adequadamente, bem como explicar o que ele é para o direito, ou seja, esclarecer a sua natureza jurídica. Decidiu-se tratar nessa ordem esses dois pontos, pois definir a natureza jurídica de algum instituto depende, essencialmente, de compreender adequadamente o seu conceito.

Na presente dissertação, discute-se o uso do seguro garantia, aqui entendido como garantia de execução (*performance bond*), uma vez ser possível encontrar uma série de aplicações particulares do seguro garantia¹⁹³.

De maneira preliminar, o *performance bond* pode ser entendido como um mecanismo de garantia no qual um terceiro, o segurador, se coloca como garante da execução da obrigação de seu tomador¹⁹⁴, naturalmente mediante contraprestação, em favor de um beneficiário¹⁹⁵, em razão de um contrato entre este e o tomador.

Neste tópico, serão apresentadas algumas definições encontradas na literatura especializada, realizando-se, ao final, uma síntese com o objetivo de esclarecer ao leitor qual o conceito precisamente utilizado nesta dissertação.

A primeira definição é de L. P. Thean, para quem:

Tal vínculo é uma garantia, cujos termos são muito simples e diretos. Essencialmente, tal vínculo impõe ao emissor, geralmente uma instituição financeira, um pagamento sob demanda (*on demand*) pelo beneficiário, e, em alguns casos, a partir da produção de qualquer tipo de evidência que o vínculo possa especificar. Na maior parte dos casos, todavia, tal evidência é de fato mínima, por exemplo, um certificado do beneficiário afirmando que a parte segurada cometeu uma quebra do contrato subjacente. Normalmente é emitido pelo

¹⁹³ Tais como: *Bid Bonds* (seguros de propostas); seguro garantia judicial; seguro garantia de funcionamento; seguro garantia aduaneiro; seguro garantia imobiliário; seguro garantia administrativo entre outros. Cf. BURANELLO, Renato Macedo. **Do Contrato de Seguro: O seguro garantia de obrigações contratuais**. Op. Cit. pp.189-200.

¹⁹⁴ Eventualmente chamado de segurado pela literatura especializada, embora não pareça a nomenclatura mais adequada a ser utilizada, pois pode gerar dificuldades na compreensão do papel de cada parte dentro da relação.

¹⁹⁵ Aqui, também, parte da literatura especializada chama de segurado, porém tal nomenclatura pode causar confusão com relação aos papéis das partes dentro da relação triangular.

banco, companhia de seguro ou outra instituição financeira por conta de seu cliente em favor de um beneficiário, com quem o cliente tem um contrato, para garantir a sua performance adequada.¹⁹⁶

De forma semelhante Azizan Supardi e Hamimah Adnan definem o instituto da seguinte maneira:

O performance bond é um vínculo assecuratório do adimplemento de um contrato cuja prestação é uma ação pela qual uma pessoa (o devedor) se compromete em favor de outra (o credor) a fazer ou deixar de fazer algo. Em contratos de construção, um ‘performance bond’ é uma garantia retirada pelo contratado, normalmente junto a um banco ou companhia de seguro (mediante o pagamento de um prêmio), em favor e a pedido do contratante, com a estipulação de um valor máximo de responsabilidade e exequível pelo contratante no caso de negligência, abandono ou insolvência do contratado.¹⁹⁷

Além disso, os autores descrevem a possibilidade de haver dois tipos de *performance bond*: o condicional (*conditional*) e o incondicional (*unconditional*). No primeiro caso, o garantidor fica solidariamente responsável pela performance das obrigações do contratado, todavia, este permanece como primariamente responsável, desprotegido pela garantia; no caso do incondicional, temos uma garantia “*on-demand*”, na qual o garantidor é convocado para indenizar o contratante, de acordo com os termos da garantia.¹⁹⁸

A grande diferença está nos requisitos para acionar a garantia. Na modalidade condicional, o beneficiário deve cumprir com algumas condições precedentes, enquanto no incondicional, por outro lado, a única condição necessária para acionar o

¹⁹⁶ Livrentemente traduzido de: “Such a bond is a guarantee, the terms of which are very simple and straightforward. Essentially such a bond calls for payment by the issuer, usually the bank, on demand by the beneficiary, and in some cases on the production of whatever evidence the bond may specify. In most cases, however, such evidence is really minimal, eg a certificate from the beneficiary stating that the party on whose account the bond was given has committed a breach of the underlying contract. It is normally issued by a bank, insurance company or other financial institution for the account of their costumer to a beneficiary, with whom the customer has entered into a contract, to secure the due performance of that contract by their costumer.” THEAN, L. P. The Enforcement of a Performance Bond: The perspective of the underlying contract. **19 Singapore Law Review**. 1998, pp. 389-421, p. 389.

¹⁹⁷ Traduzido livremente de: “A performance bond is a bond giving security for the carrying out of a contract, where a bond is a deed by which one of the person (the obligator) commits himself to another (the obligee) to do something or refrain from doing something (Martin, 2003). In construction contracts, a ‘performance bond’ is a bond taken out by the contractor, usually with a bank or insurance company (in return for payment of a premium), for the benefit of and at the request of the employer, in a stipulated maximum sum of liability and enforceable by the employer in the event of the contractor’s default, repudiation or insolvency (Robinson et al, 1996). ADNAN, Hamimah; SUPARDI, Azizan. Legal Analysis on Malasyan Construction Contract: Conditional versus Unconditional Performance Bond. Op. Cit. p. 25.

¹⁹⁸ Ibidem, p. 26.

segurador é uma notificação ao segurado.¹⁹⁹ Nesse passo, o modelo incondicional é mais ágil, dependendo apenas de um movimento do beneficiário em comunicar o garantidor, já a modalidade condicional, depende de procedimentos prévios entre o beneficiário e o contratado.²⁰⁰

Uma definição mais abrangente oferece uma escolha ao garantidor, além de indenizar o contratante, aquele pode assumir para si a obrigação de seu segurado, a adimplindo por suas próprias expensas, nesse sentido:

(...) um performance bond garante que se um contratado inadimplir, o garantidor irá assumir a obrigação de realizar a obra ou de pagar pela mão-de-obra e material incorporados ao projeto. Se, como geralmente é o caso, o contrato determine que o contratado realize sua obrigação de acordo com os projetos e especificações de forma diligente, o dever do segurador, sob o performance bond irá, provavelmente, se estender a corrigir defeitos ou trabalhos defeituosos.²⁰¹

Neste caso, o segurador é obrigado, em caso de inadimplemento do contratado, a concluir obra, ou bancar a sua conclusão, e, mesmo que o segurado execute a obra até o fim, o garantidor ainda fica responsável por problemas futuros decorrentes de eventual execução deficiente do segurado.

No Brasil, não há uma definição legal do instituto, de forma que cabe à normatização administrativa da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a qual regulamenta o seguro garantia por meio de sua Circular n.º 477 de 30 de Setembro de 2013. Em seus arts. 4º e 5º:

¹⁹⁹ Idem.

²⁰⁰ A discussão da condicionalidade ou incondicionalidade do *performance bond* em contratos de construção representa uma questão muito debatida na jurisprudência malaia: “*Thereore a performance bond is nothing more than a writen guarantee, and in order to interpret the obligations of the bank, one need only to look at the written bond itself to determine what are the terms and conditions agreed upon between the parties. A great deal, therefore depends on the wording of the bond itself.* However in Malaysia for the past 20 years and since the famous *Teknik Cekap Sdn Bhd v Public Bank Berhad* [1995] e MLJ 449 to the recent *Suharta Development Sdn Bhd V United Overseas Bank (M) Bhd & Anor* [2005] 2 MLJ 762, the question of whether the performance bond in a construction contract is a conditional or an unconditional guarantee is still one of the issues relating to performance bond that been discussed” Idem. (Grifos do autor).

²⁰¹ No original como: “... a surety performance bond ensures that if a contractor defaults, the surety is obligated to assume the duty to perform the construction work or to pay for labor and materials incorporated into the project. If, as is usually the case, the contact requires the contractor to perform his work in accordance with the plans and specifications in a good and workmanlike manner, a surety’s duty under a performance bond will likely extend to correcting defective or faulty workmanship.” BRIGLIA, S. J.; ETCHEVERRY, E. The construction defect hot potato: the interplay between the performance bond and CGL policy - a surety’s perspective. **Defense Counsel Journal**, [s. l.], n. 1, p. 30, 2010, p. 32.

Art. 4º Define-se Seguro Garantia: Segurado – Setor Público o seguro que objetiva garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões ou permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

Parágrafo único. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

Art. 5º Define-se Seguro Garantia: Segurado – Setor Privado, o seguro que objetiva garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado no contrato principal firmado em âmbito distinto do mencionado no art. 4º.

Portanto, seguindo as definições internacionais, a SUSEP trata o seguro garantia como um mecanismo em que a seguradora fica responsável pelo adimplemento da obrigação de seu tomador em favor de um terceiro, o verdadeiro beneficiário da relação, em razão de um contrato anterior. Com isso, a definição da SUSEP segue a mesma linha das anteriormente apresentadas.

O Tribunal de Contas da União define seguro-garantia da seguinte maneira:

Seguro-garantia – modalidade de garantia oferecida por licitantes ou contratados, por meio de empresa seguradora, para assegurar o fiel cumprimento de obrigações assumidas em procedimentos licitatórios e em contratos celebrados pela Administração Pública.²⁰²

Na literatura brasileira, poucos são os trabalhos que tratam especificamente da figura do seguro garantia. Gladimir Adriani Poletto, ao analisar algumas definições normalmente apresentadas na bibliografia jurídica nacional, sintetiza seu conceito da seguinte maneira:

Em busca da delimitação conceitual do instituto de Seguro Garantia, verifica-se, do cotejo das fontes acima assinaladas, que se pode dizer, frente ao sistema nacional de seguros, que “*pela contratação do Seguro Garantia, mediante o pagamento de um prêmio, o segurador garante o cumprimento das obrigações do tomador do seguro firmadas com o segurado ou beneficiário, exclusivamente*

²⁰² BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Licitações e contratos : orientações e jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União**. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília : TCU, Secretaria-Geral da Presidência : Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010. p. 892.

dentro dos limites convencionados na apólice, seja pelo pagamento dos prejuízos ocorridos ou pelo cumprimento efetivo da obrigação contemplada pela importância assegurada''²⁰³. (grifos do autor)

Nesta definição, igualmente, o autor abrange tanto a possibilidade de a seguradora ficar responsável, alternativamente, pelo pagamento de uma indenização ou pela conclusão do objeto contratual.

Finalmente, Renato Macedo Buranello, em seu trabalho sobre Seguro Garantia, ao conceituar o instituto, afirma:

Podemos dizer que o seguro garantia de obrigações contratuais é o instrumento pelo qual uma seguradora ou empresa garante (no exterior *surety companies*) se obriga, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à obrigação comercial de dar ou fazer assumida pelo tomador.

(...) No citado projeto de lei número 2851, o seguro-garantia é definido como o contrato pelo qual a seguradora garante ao segurado o fiel cumprimento de uma obrigação do tomador, decorrente de lei ou contrato, até o valor fixado na apólice.²⁰⁴

Nesses termos, o autor denomina aquele em favor de quem se realiza o seguro como segurado, tratando como tomador quem realiza o contrato com a empresa seguradora. Trata-se apenas de uma pequena modificação terminológica, porém a substância do instituto se mantém, uma vez que se objeto principal é a garantia da execução de uma obrigação assumida pelo tomador em favor do segurado.

Em síntese, é possível inferir que, uma vez observável em uma relação uma empresa seguradora como garante de uma obrigação de um tomador, seu cliente, em favor de um beneficiário, credor da obrigação em favor da qual se realiza o seguro, há um contrato de seguro garantia de execução de obrigação contratual. Embora seja possível encontrar algumas variações, como visto acima o *conditional* e *unconditional performance bond*, e o seguro garantia com beneficiário público ou privado, na essência, a estrutura da relação se mantém a mesma e, como será exposto abaixo, sua natureza jurídica mantém-se pouco clara.

3.2. Natureza Jurídica.

²⁰³ POLETTTO, Gladimir Adriani **O Seguro Garantia: em busca de sua natureza jurídica**. Série Cadernos de Seguros: teses, v. 8, n.º 17. Fundação Escola Nacional de Seguros (FUNENSEG), Rio de Janeiro, 2003. p. 43.

²⁰⁴ BURANELLO, Renato Macedo. **Do Contrato de Seguro: O seguro garantia de obrigações contratuais**. Op. Cit. pp.173-174.

A figura do seguro garantia encontra-se na interseção de duas categorias jurídicas mais amplas, o seguro e um contrato de fiança.²⁰⁵

Um contrato de seguro é “um instrumento jurídico para, convencionalmente, transferir risco para outra pessoa”²⁰⁶. Seu funcionamento depende do ato de pulverizar o risco²⁰⁷, a seguradora funciona como um elemento unificador entre as pessoas submetidas a um risco, transferindo para ela, mediante uma contraprestação, o prêmio, os efeitos patrimoniais (e eventualmente até extrapatrimoniais, como no caso do seguro de vida), da ocorrência do fato.

É possível ilustrar seu funcionamento a partir do seguinte exemplo. Suponha-se que em um universo de cem casas, em um ano a chance de ocorrer um incêndio é de 1%, e os danos, para o dono do imóvel atingido, seria de R\$ 50.000,00, um valor alto para ser desembolsado de uma vez pelo proprietário. Idealmente, considera-se que todas as casas, hipoteticamente com a mesma chance de sofrerem o sinistro²⁰⁸, tenham feito um seguro contra a ocorrência de incêndios, com o mesmo segurador, cada um irá pagar, descontado eventual taxa que garanta o lucro da seguradora, exatamente o risco esperado, qual seja a probabilidade do evento danoso (1%) multiplicado pelo dano (R\$50.000,00), isto é, R\$ 500,00 por ano.

Dito isso, fica claro como:

A operação de seguros é uma atividade complexa, de natureza econômica, que se fundamentou na dispersão ou pulverização de riscos e na mutualidade ou comunidade de riscos. (...) A ideia fundamental que justifica a operação de seguros é a da prevenção do risco, aqui entendido como a probabilidade de que acontecimento ocasione prejuízo no sentido de ônus econômico para o segurado. O risco é afastado pela compensação econômica do dano (ônus econômico), derivado da ocorrência do fato cujas consequências se

²⁰⁵ Tanto há uma controvérsia que diferentes ordenamentos jurídicos acabam indicando diferentes naturezas jurídicas para o mesmo instituto, nesse sentido: “À exceção dos EUA e do México, onde a natureza jurídica do Seguro Garantia está perfeitamente delimitada, ou seja, o *surety bond* somente é emitido pelas *sureties*, companhias afiançadoras autônomas, que somente trabalham no ramo de garantia e crédito; e as *afiançadoras* do México, que só emitem fianças; os outros países analisados apresentam divergências quanto à natureza jurídica do seguro garantia, inclusive o Brasil. (grifos do autor). POLETO, Gladimir Adriani **O Seguro Garantia: em busca de sua natureza jurídica**. Op. Cit. p. 73.

²⁰⁶ MACKAAY, Ejan. **Law and Economics for Civil Law Systems**. Op. Cit., p. 64.

²⁰⁷ Nesse sentido: “The key stone of insurance is diversification (*risk spreading*). Diversification means bringing together independent risks, that is risks that do not go up and down at the same time. This is also for setting up one’s investment portfolio in the stock market”; Ibidem, p. 58.

²⁰⁸ Evento danoso que se busca compensar os efeitos patrimoniais mediante o seguro.

quis evitar ou diminuir. Essa compensação tem natureza econômica no seguro, e isso independe de sua forma.²⁰⁹

Porém, encontra-se no seguro garantia peculiaridades que o afastam de características centrais dos seguros, especialmente o fato da sua instrumentalização não ocorrer por meio de contrato de adesão, como acontece com a maior parte dos seguros disponíveis no mercado, pelo seu risco não estar diretamente atrelado à atuária e por se distanciar do mutualismo típico dos seguros.²¹⁰ As suas apólices não são desenhadas com base em um risco genérico (incêndio, furto, roubo, danos)²¹¹, mas sim de acordo com a avaliação da obrigação assumida e da capacidade do tomador de fazer frente a ela, é possível afirmar até mesmo uma natureza personalíssima da sua contratação.²¹²

Ao realizar a contratação, e a subscrição do risco, a seguradora confere mais peso a três ordens de análise: (i) capacidade, ligada à saúde econômico-financeira do tomador; (ii) competência, entendida como sua aptidão técnica de adequadamente cumprir a obrigação assumida a qual se pretende segurar, e; (iii) caráter, isto é, sua idoneidade, frequentemente analisada como elemento relevante pelo estudo de risco.²¹³

Há, ainda, quem o considere como uma espécie de título de crédito, mais especificamente uma *letter of credit*²¹⁴, ou assemelhada à nota promissória²¹⁵. Todavia,

²⁰⁹ BURANELLO, Renato Macedo. **Do Contrato de Seguro: O seguro garantia de obrigações contratuais**. Op. Cit. pp. 124-125.

²¹⁰ Ibidem, p. 174.

²¹¹ Embora características pessoais dos tomadores sejam levadas em conta nos seguros gerais, estas são feitas com base em atuária, isto é, probabilidades genéricas, não diretamente especificadas para cada segurado. Por exemplo, pode ser que um dado homem jovem seja muito mais prudente ao dirigir, em comparação com uma mulher de meia idade específica, mas levando em conta características gerais das categorias nas quais estão incluídos, o prêmio do primeiro será consideravelmente mais caro que o da segunda, pois aquele pertence a categoria de risco considerado muito maior.

²¹² Nesse sentido: “Essa espécie de seguro se afasta dos fundamentos principais do contrato típico de seguro, não está adstrito à mutualidade e a atuária. Assim se conclui, uma vez que as apólices são desenhadas de acordo com a obrigação principal que vai garantir e, em regra, de acordo com as garantias que o empresário tomador irá oferecer para emissão da apólice, respeitadas as condições gerais do seguro conforme, circulares da Superintendência de Seguros Privados e de acordo com cada modalidade de cobertura. No mesmo sentido, o seguro garantia tem um perfil muito diferente do risco de outras carteiras. Nos ramos mais comuns a atuária é instrumento fundamental da atividade, trazendo-nos as informações estatísticas dos índices de sinistralidade e das tacas que devemos aplicar. Com o seguro garantia é muito diferente, pois nele é analisada cada operação no aspecto econômico-financeiro e operacional, ressaltando-se a capacidade de *performance* do tomador. Nesse ramo a contratação pode mesmo trazer um caráter *intuitu personae*.” (grifos do autor). Ibidem, pp. 174-175.

²¹³ Ibidem, p. 175.

²¹⁴ Nesse sentido: “Kerr J clearly treated the performance bond as a letter of credit and considered the cases on letters of credit as applicable”. THEAN, L. P. The Enforcement of a Performance Bond: The perspective of the underlying contract. Op. Cit. p. 395.

²¹⁵ Nessa lógica: “... a performance bond is in the nature of being a promissory note, but not quite! And ergo, the first issue one must customarily deal with it, and it has been addressed by many authors,

não se trata de posição muito adotada pela literatura especializada, a qual destaca a diferença de propósito e efeitos da execução entre os institutos (o *performance bond* e os títulos de créditos)²¹⁶.

Porém, discussão mais relevante ocorre quando se pensa nas similaridades do seguro garantia com a fiança. O conceito legal desta está no artigo 818 do Código Civil de 2002:

Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

Ela é descrita a partir de seus efeitos, a partir da inserção de um terceiro como garante da obrigação de um devedor em contrato principal. Na literatura, não há muitas discussões acerca de seus caracteres, sendo definida por Caio Mário da Silva Pereira de maneira muito próxima à legal:

Como garantia pessoal (*fideiussio*, *cautionnement*, *fideiussione*), ora resulta do acordo livremente ajustado (fiança *convencional*), ora emana do comando da lei (*fiança legal*), ora provém de imposição do juiz (*fiança judicial*). A estas últimas não nos referiremos, mas à primeira, que definiremos como o contrato por via do qual uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (Código Civil, art. 818). (grifos do autor)²¹⁷

Não há uma delimitação do tipo de obrigação a ser assumida pelo fiador, a qual pode ser um dar, um fazer e até mesmo um não fazer.

Na realidade, é fácil de perceber semelhanças entre os institutos. Nos dois casos, há a assunção de responsabilidade por um terceiro, fiador ou segurador, alheio a relação contratual entre o devedor e o credor original. Nas duas hipóteses pode haver a delimitação do objeto garantido, no caso do seguro pelos termos da apólice e da fiança pelas disposições contratuais. Seja no caso do seguro garantia quanto da fiança, a validade do contrato principal, objeto da garantia, afeta o contrato acessório. Por fim, em ambas as realidades o terceiro responsável, caso acionado pelo credor, irá se sub-

commenters, judges and no doubt advisers to their clients, is: when is a performance bond a performance bond (...) In principal, a true performance bond will always be regarded as a documentary credit". DALBY, Joseph. A Performance Bond, Deconstructed. **Business Law International**. Vol, 11, n.º 2, May, 2010. pp. 105; 107.

²¹⁶ Cf. THEAN, L. P. The Enforcement of a Performance Bond: The perspective of the underlying contract. Op. Cit. pp. 400-415,

²¹⁷ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil: Volume III: Contratos** Revisão e Atualização: Caitlin Mulholland. 23ª edição. Rio de Janeiro. Editora Forense, 2019. p. 469.

rogar nos direitos deste e cobrar do devedor principal o montante pago a título de sinistro ou fiança. Isto é, são dois caminhos para se chegar aos mesmos fins.²¹⁸

Compreendendo essas semelhanças, mas atendo às peculiaridades do seguro garantia²¹⁹, os dois principais trabalhos da literatura jurídica nacional dedicados exclusivamente à discussão acerca da natureza jurídica do seguro garantia consideram o instituto como peculiar, mesclando características da fiança e do seguro.

Seguindo essa linha, afirma Gladimir Adriani Poletto:

²¹⁸ Nesse sentido: “Em qualquer hipótese, ocorre assunção da responsabilidade por uma das partes, seja fiador ou segurador, quanto aos riscos que recaem sobre o objeto de interesse da outra parte. A relação de seguro ou de fiança é uma relação obrigacional e, como tal, está assim composta: a primeira, de crédito e débito; a segunda, de garantia e responsabilidade. No primeiro plano, resta determinado o que deve ser prestado, em que tempo, e de quem para quem. No segundo, define-se a consequência do inadimplemento. Quanto à delimitação do objeto a ser garantido, a situação é a mesma, pois, tanto sob a análise do seguro “limites de cobertura da apólice” quanto da fiança, o fiador pode restringir a responsabilidade de sua obrigação. No Seguro Garantia como no da fiança, a validade da obrigação principal afeta o acessório, que é a relação fidejussória, cujas partes poderão não reconhecer o direito do credor e opor exceções que competem ao devedor originário. A recíproca não é verdadeira, conquanto a relação fidejussória não afeta a principal. Na fiança, o fiador se sub-roga de pleno direito, ou seja, no direito e na ação do credor pago contra o afiançado, inclusive, podendo demandar por perdas e danos decorrentes. No Seguro Garantia, a seguradora se sub-roga no direito do segurado ou beneficiário para cobrar do tomador a importância paga a título de sinistro; contudo, tal sub-rogação, como já se assinalou, poderá ser legal ou convencional, uma vez que a operação de Seguro Garantia está assim lastreada. Ainda que em caminhos distintos, o fim parece ser o exatamente o mesmo. POLETTI, Gladimir Adriani **O Seguro Garantia: em busca de sua natureza jurídica**. Op. Cit. pp. 73-74.

²¹⁹ Nesse sentido: “Na nova perspectiva do contrato de seguro, ou seja, na operação do Seguro Garantia, os elementos que caracterizariam a essência do instituto poderiam ser elencados na seguinte forma: na contratação do seguro, a companhia de seguros cobra um prêmio pelo serviço prestado; o interesse segurável está contemplado no objeto da apólice, ou seja, no valor econômico derivado da garantia de cumprimento, pois há interesse segurável; o risco do contrato está na impossibilidade de cumprimento. Não haveria sentido imaginar que o sinistro se daria por ato voluntário do tomador, pois o mesmo seria responsável pelo próprio ato e responderia por ele. Assim, os elementos essenciais do contrato de seguro estão presentes, ou seja: risco, prêmio e interesse segurável. Observa-se, aqui, que a nova perspectiva do contrato de seguro fere o princípio da assunção do risco, isto é, a compra do risco pelo pagamento do prêmio não autoriza o segurador a se sub-rogar dos direitos do segurado para obter, dele mesmo, o ressarcimento de valor pago a título de sinistro. Dessa forma, estar-se-ia alterando a identidade do contrato de seguro, portanto, não parece aceitável que o Seguro Garantia tenha essência de seguro, pelo fato de estarem presentes em sua relação elementos do contrato de seguro, uma vez que a sua identidade é outra. De outra sorte, está o instituto da fiança, cuja finalidade é a garantia, inclusive, a norma especial que confere ao Seguro Garantia legitimidade expressa: “*o segurador assumirá a condução de fiador das obrigações do tomador perante o segurado*”, e, por esse prisma, o Seguro Garantia harmoniza-se com a fiança. Contudo, o meio pelo qual está caracterizado, isto é, a apólice e o cumprimento das regras de seguros pertinentes, não autorizam a consonância entre os institutos. Assim, entende-se que não se trata de fiança pura ou indireta, uma vez que a identidade do Seguro Garantia é distinta da fiança. Pela contextualização vista, embora combatida item a item, verifica-se que o Seguro Garantia apresenta semelhança com o instituto da fiança, principalmente quanto ao objetivo da garantia e à própria sistemática de responsabilidade pelo pagamento securitário e a sub-rogação consequente; contudo, a diferença consiste na causa primeira, que é o contrato de emissão da apólice, e esta, como meio para concretização da relação jurídica. Portanto, o fato jurídico atinge o mesmo objetivo da fiança, por um meio não típico ao contrato de fiança, que é o contrato de emissão e a apólice propriamente ditos.” Ibidem, p. 81.

Dessa forma, outro caminho não existe, senão a de concluir que a natureza jurídica do Seguro Garantia é própria do instituto que é, ou seja, não possui o caráter de seguro e também o de fiança, uma vez que os elementos que o compõem são únicos ao instituto, muito embora alguns façam parte ou se assemelhem ao seguro e, também, à fiança. (...) No seguro, temos os elementos fundamentais presentes como o prêmio o risco, a apólice e, na fiança, temos a garantia. As características da relação jurídica do Seguro Garantia consubstanciadas pelo caráter plurilateral, oneroso, nominado, solene, formal, acessório e aleatório. A pluralidade da relação jurídica está descrita pela forma triangular acima, onde tomador, segurado e segurador estão formalmente vinculados, onde cada qual se posiciona em um vértice da relação, com responsabilidades variadas a fim de atingir um objetivo comum; a emissão do Seguro Garantia é uma atividade onerosa, uma vez que as partes convencionam vantagens de caráter patrimonial recíproco; a relação jurídica é nominada, haja vista que se encontra regulada por legislação especial; é solene, uma vez que somente se aperfeiçoa com a aceitação da apólice pelo segurado; é formal, pois a prova do contrato é a apólice de seguro e esta deverá estar em conformidade com as regras impostas pela instituição seguro; é acessório, pois a garantia securitária serve para garantir as obrigações pactuadas no contrato principal; e aleatório, já que o Seguro Garantia assegura a possibilidade da ocorrência do evento futuro e incerto que não permita o cumprimento das obrigações contratuais pelo tomador. Assim, em detrimento da análise das fontes do direito, sejam nacionais ou estrangeiras, entende-se que a relação jurídica do Seguro Garantia visa externar uma garantia, possui forma de operação de seguro, uma vez que estão presentes alguns dos elementos comuns à instituição, mas a sua natureza jurídica é peculiar a si própria, pois não está presente em qualquer outra forma de garantia.²²⁰

Na passagem acima, embora reconheça que o instituto mescla características essenciais do seguro e da fiança, o autor afirma a natureza própria, *sui generis*, do seguro garantia, e conseqüentemente para as suas subespécies e variações. Assim, a combinação de características de institutos diferentes criaria um diferente de ambos, com natureza própria.

De forma semelhante, Renato Buranello também reconhece a mescla de traços do seguro e da fiança no seguro garantia. Todavia, este autor acaba optando por considerar a natureza do instituto em estudo como mista, no lugar de *sui generis*. Nesse passo, afirma:

... o seguro garantia tem natureza representada pela união de contratos, (...) está ligado ao seguro e à fiança, mas dentro de funções específicas e distintas. A finalidade é garantia no gênero

²²⁰ Ibidem, pp. 82-83.

caução, e em nosso Direito está mais bem tipificada pela fiança e exteriorizado através do instrumento representado pela apólice de seguro. Assim é que a melhor doutrina estrangeira e algumas decisões de tribunais superiores internacionais colocam o seguro garantia como ‘uma fiança prestada por uma companhia de seguros, mediante o pagamento de uma comissão a que se dá o nome de prêmio’. Ainda citam que o seguro caução *inter partes* é um contrato de seguro, mas entre a parte que o presta e a parte que o exige, funciona como garantia.

Realmente, o seguro garantia gera uma verdadeira obrigação de fiança, na medida em que o segurador se obriga a garantir o segurado também do pagamento de uma importância, no caso de descumprimento de um direito de crédito relacionado a uma obrigação de fazer ou de dar, de que seja titular. O segurador, em definitivo, está garantindo o cumprimento da obrigação junto ao seu credor, colocando-se assim no mesmo plano de responsabilidade que o tomador. Além disso, a obrigação do segurador reúne as características da acessoriedade, subsidiariedade e unilateralidade que distinguem a obrigação de fiança. Sustenta-se, entretanto, que o seguro garantia não equivale simplesmente a uma fiança. Diz-se, nesse sentido, que uma coisa é a obrigação de fiança e outra distinta, o contrato de mesmo nome.²²¹

Para a presente dissertação, considera-se relevante entender a natureza jurídica do instituto na medida em que a ausência de uma legislação específica sobre o tema, hoje regulado praticamente apenas por normas administrativas, nos obriga a buscar em outras categorias jurídicas elementos para compreender seu funcionamento e tornar o seguro garantia operacionalizável na prática.²²²

Assim sendo, enquanto os seguros tradicionais possuem uma avaliação essencialmente *ex ante* de eventos, o *performance bond* possui uma dimensão de

²²¹ BURANELLO, Renato Macedo. **Do Contrato de Seguro: O seguro garantia de obrigações contratuais**. Op. Cit. pp. 184-185.

²²²Reforçando, mais uma vez, sua natureza mista: “O seguro garantia de obrigações contratuais equipara-se a uma operação eminentemente creditícia; exerce a função de crédito, uma vez que o negócio de base é feito unicamente porque se supõe que o risco econômico representado pelo devedor foi avaliado e aceito por uma companhia de seguros. Daí que, antes de obter o seguro, o garantido será cadastrado, e para cada caso específico, terá sua capacidade técnica avaliada pelo IRB-Brasil Re, tendo em vista a facete que se propõe executar. Essa avaliação creditícia do tomador do seguro garantia leva a sua maior aproximação das características típicas da fiança bancária. Não há, em conclusão, a nosso ver, senão admitir a natureza fidejussória da obrigação assumida pelo segurador. Contudo, é de esclarecer que se articula a inclusão de uma obrigação de garantia no meio ou instrumento de uma apólice de seguro. Isso equivale a dizer, até certo ponto, a disciplina a que se sujeita o *contrato*, está atrelada ao regimento jurídico da *atividade securitária*. Estará, assim, respeitado o objeto do contrato de seguro garantia, seus pressupostos técnicos, sociais e econômicos, bem como sua utilidade em adequação ao ordenamento jurídico, como, por fim, ao interesse público de sustentabilidade do sistema, traduzido na capacidade de subscrição, que só se permite ao resseguro e em grande parte a esta formal e dissinta modalidade de seguro. Sem embargo, é inegável dizer que sua essência – é dizer, sua causa – leva a uma autêntica garantia pessoal. Negar ao seguro garantia, seguro caução ou, ainda, pelo próprio apego ao nome, seguro fidejussório, a autêntica natureza de fiança, seria encobrir sua verdadeira causa. Ibidem, pp. 187-188.

análise *ex post* relevante, a partir da verificação e atualização constante da capacidade de determinado agente econômico cumprir adequadamente suas obrigações.

Na prática, se um tomador de serviços desempenha de forma insatisfatória um contrato e causa um sinistro, essa condição será considerada um aumento do risco daquele agente específico, o que será precificado nas futuras apólices e trará reflexos para a sua competitividade nos certames em que se envolver. Com essa informação, a seguradora “olha para frente” recalculando a capacidade de executar contratos do tomador em questão, mais focado em suas condições pessoais. O seguro tradicional se baseia, essencialmente, em atuária, olhando “para trás” com base em dados pretéritos, mais genéricos (como índices de furto, por exemplo), os quais nem sempre são capazes de averiguar precisamente a capacidade do tomador evitar a ocorrência de um sinistro.

Com isso, a partir da análise do exposto neste tópico, conclui-se pela natureza de seguro do *performance bond*. Embora, de fato, ressalvas devam ser feitas, como as suas proximidades com a fiança, todo o arcabouço regulatório o normatiza, precipuamente, partindo de categoriais de seguro²²³. Tanto é que o acompanhamento do mercado e sua regulação cabem à SUSEP.

As semelhanças com a fiança, especialmente a bancária, não são suficientes para descaracterizar sua natureza securitária, pois, na essência, o seguro garantia tem o objetivo de afastar os efeitos de um risco, qual seja, o inadimplemento do contratado. A fiança, por sua vez, serve, apenas, para indenizar o credor em caso de inadimplemento do devedor principal, o fiador não pode, no lugar do afiançado, assumir a execução do contrato.

Ademais, na fiança importa, essencialmente, a capacidade financeira do afiançado, enquanto no seguro garantia existem outros fatores, destacados acima, que são levados em conta, especialmente a capacidade técnica e idoneidade do devedor principal, o que não ocorre na fiança, inclusive a bancária.

Por fim, a fiança bancária, conforme resolução 2.099/1994 do Conselho Monetário Nacional acabou restringindo a emissão de cartas fianças²²⁴, uma vez que

²²³ Como será exposto em tópicos abaixo, nos EUA, as responsáveis pela emissão de apólices de *performance bond* são as *Surety Companies*, que se assemelham muito mais as seguradoras no direito brasileiro, sendo esse mais um argumento a favor da sua natureza securitária.

²²⁴ Cf. “O seguro garantia somente ganhou espaço no cenário nacional após a Resolução n.º 2.099/1994 do Conselho Monetário Internacional que incluía o Brasil no acordo de Basileia, onde fora restringida a emissão de cartas fianças por tomar limite operacional dos bancos, colocando o seguro em evidência.”

elas passaram a tomar o limite operacional dos bancos, o que não ocorre com o seguro garantia. Destaca-se, portanto, mais uma diferença entre os institutos e que corrobora a natureza securitária do *performance bond*.

3.3. Finalidade e Funcionamento.

Entendido seu conceito e esclarecida a sua natureza jurídica, pode-se passar ao estudo de como o seguro garantia pode ser operador na prática.

Para tanto, é necessário compreender a sua dimensão objetiva, isto é, seu objeto, pois é a partir dele que o instrumento jurídico irá tomar forma. Como se viu, o seguro garantia não deixa de ser, ao menos parcialmente, um seguro, portanto, sua função está intrinsecamente ligada à assunção de um risco, isto é, “a assunção de um ônus econômico que é determinado em consequência de um evento futuro e incerto”²²⁵, mais especificamente, no caso do seguro garantia, é a não execução, pelo devedor na relação originária subjacente ao seguro, de sua obrigação. Com isso, deve o segurador eliminar tal risco, ou “reparar as consequências da sua realização”²²⁶, muito embora a mera assunção do risco pelo segurador já representa o adimplemento de sua prestação.

No caso do seguro, “o risco a que se acha exposto o patrimônio ou a pessoa do segurado constitui a causa do contrato”²²⁷. Especificamente no seguro garantia o risco é o inadimplemento contratual do devedor²²⁸. Portanto, o objeto da cobertura, no caso, é “uma obrigação positiva de fazer ou de dar em contrato firmado entre o tomador e o segurado”²²⁹⁻²³⁰, cujo inadimplemento pelo devedor tomador do seguro representa o risco do beneficiário.

DORIA, Thaila Renata Teixeira Doria. **Seguro Garantia como Alternativa às Obras Públicas Paralisadas no Brasil**. Dissertação apresentada ao curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento Econômico. Orientador: Prof. Dr. José Guilherme Silva Vieira. Curitiba, 2019. p. 42.

²²⁵ BURANELLO, Renato Macedo. **Do Contrato de Seguro: O seguro garantia de obrigações contratuais**. Op. Cit. p. 106.

²²⁶ Ibidem, p. 114.

²²⁷ Ibidem, p. 117.

²²⁸ Nesse sentido: “O risco no seguro garantia é a possibilidade do inadimplemento do tomador no contrato garantido. A finalidade no seguro garantia é prestar garantia para o ressarcimento do segurado pelos danos que sofra em virtude da realização do risco. Tanto a fiança quanto os chamados seguros fidejussórios são contratos de garantia, como iremos ver.” Ibidem, p. 141.

²²⁹ Ibidem, p. 131.

Como já se destacou, trata-se de modalidade de garantia muito utilizada em contratos de construção civil, sob a modalidade de *performance bond*²³¹. Porquanto a presente a dissertação se destina a analisar o uso de tal modalidade de garantia em contratos públicos, entende-se relevante destacar a sua aplicação típica nos contratos de construção, conforme descrito pela jurisprudência malaia:

Rekhraj J no caso *Lotterworld Engineering & Construction Sdn Bhd v Castle Inn Sdn Bhd & Anor* [1998] 7 MLJ 105 afirmou da seguinte maneira o propósito do *performance bond*:

Entende-se que o propósito do performance bond na indústria da construção civil é de desempenha o papel de uma salvaguarda efetiva contra o inadimplemento e adimplemento defeituoso ou atrasado e sua produção provê uma garantia prontamente disponível para ser executada, quando o sinistro ocorre, vis a vis simplesmente com a falha de completar o trabalho contratado.

O propósito de uma garantia é, portanto prover ao contratante alguma segurança financeira em forma de numerário pagável pelo banco ao pelo inadimplemento do contratado de sua obrigação sob um contrato de obra. (grifos do autor)²³²

Portanto, para a presente dissertação, entende-se o seguro garantia como um instrumento securitário cujo risco coberto, para o beneficiário, no caso de um contrato administrativo, o Poder Público, é o inadimplemento do contratado no âmbito de um contrato cujo objeto é a realização de uma obra.

A prestação da seguradora é, portanto, assumir o risco acima descrito. Por sua vez, o tomador do serviço, aquele com quem o emissor da apólice contrata, deve pagar uma contraprestação, qual seja, o prêmio do seguro.

Neste ponto reside uma das peculiaridades do seguro garantia em comparação com as demais modalidades de seguro. Enquanto nestes o cálculo do prêmio depende, essencialmente, de um cálculo atuarial a partir da combinação de uma série de fatores de riscos que podem ser maiores ou menores. Dependendo do tipo de seguro, os fatores poderão variar, por exemplo, para um seguro de automóvel importa saber a marca e o modelo do veículo, se na região onde o segurado reside ocorrem muitos

²³⁰ O instituto apresenta um amplo espectro de aplicação, assim “O seguro garantia de obrigações contratuais é largamente utilizado nas obrigações de empresas de prestação de serviços, de construção, de fornecimento de produtos, na garantia de manutenção de oferta, em caso de concorrência, de fiel cumprimento de obrigações tributárias etc.” Idem.

²³¹ Chama-se *performance bond* quando a obrigação garantida é a execução de algum tipo de prestação, diferente do *bid bond*, por exemplo, o qual garante a assinatura de um contrato. Por isso que na presente dissertação trata-se como sinônimos as expressões “seguro garantia” e “*performance bond*”.

²³² ADNAN, Hamimah; SUPARDI, Azizan. *Legal Analysis on Malaysian Construction Contract: Conditional versus Unconditional Performance Bond*. Op. Cit. p. 28.

furtos, se ele possui uma garagem para guardar o carro, a intensidade do uso, além de características próprias do segurado, como idade, estado civil, gênero etc. Com base nessas informações, busca-se estabelecer, a partir de análises estatísticas e cruzamento de dados, a possibilidade de ocorrer um dano ao bem segurado (sinistro). Confrontando-se tal probabilidade com o valor do dano, adicionando-se um valor a título de lucro para a seguradora, há a fórmula de cálculo do prêmio em um seguro comum.

Já no seguro garantia, o cálculo do prêmio a ser pago pelo tomador é feito com método totalmente diverso. “A composição de seu valor é baseada na situação econômico-financeira do tomador e não nos cálculos atuariais de risco, comuns às outras modalidades de seguro.”²³³

Tal afirmação é corroborada por Gladimir Poletto, para quem:

Enquanto o prêmio, pela teoria geral dos seguros, significa a importância paga pelo segurado à seguradora, em função da transferência do risco, no Seguro Garantia, quem paga o prêmio do seguro é o tomador garantido.

Outro ponto de distinção entre o prêmio no Seguro Garantia e nos seguros tradicionais consiste na composição de seu valor. Nos Seguros tradicionais, a taxa do prêmio é resultante da análise atuarial, a qual é composta pela importância do prêmio puro e da taxa de carregamento. No Seguro Garantia, o valor do prêmio não está baseado em cálculos atuariais do risco, mas, como já citado, na análise econômico-financeira do tomador, com a consequente classificação deste pela companhia seguradora e órgão ressegurador, aliado, ainda à análise técnica quanto ao objeto do seguro, ou seja, à subscrição efetiva da garantia prestada.

(...) Nesse sentido, vale considerar que a companhia seguradora, ao receber a proposta de seguro para emissão de apólice, analisa o negócio jurídico a ser garantido, principalmente quanto à possibilidade do tomador do seguro cumprir o que se propõe no contrato. (...) ²³⁴

O prêmio, no seguro garantia, consiste, portanto, na contraprestação do tomador do seguro em favor da seguradora em razão do risco assumido por esta, conforme ocorre em qualquer contrato de seguro. O seu cálculo, todavia, não é feito em bases atuariais, mas sim a partir da análise de crédito do tomador e de sua

²³³ BURANELLO, Renato Macedo. **Do Contrato de Seguro: O seguro garantia de obrigações contratuais**. Op. Cit. p. 122.

²³⁴ POLETO, Gladimir Adriani **O Seguro Garantia: em busca de sua natureza jurídica**. Op. Cit. pp. 49-50.

capacidade técnica para fazer frente à obrigação assumida, conforme mencionado em tópico anterior.²³⁵

Outra peculiaridade relativa ao prêmio no seguro garantia, é o efeito do seu não pagamento. Normalmente, ao não pagar sua prestação, o tomador do serviço perde a cobertura. No entanto, no caso do objeto de estudo, quando o tomador deixa de pagar o prêmio, o beneficiário, credor da obrigação do tomador não perde sua cobertura, cabendo à seguradora cobrá-lo junto ao tomador.²³⁶

Mais uma marca distintiva do seguro garantia é a sua própria estrutura tripartite (ou trilateral). Ordinariamente, um contrato de seguro é composto apenas pela seguradora e o segurado, com a primeira assumindo o risco por evento danoso futuro e incerto sobre o segundo, há, portanto, apenas uma relação bilateral, por outro lado:

Distintamente do seguro tradicional, o contrato de seguro garantia de obrigações contratuais envolve uma relação tripartite: o *tomador* é o responsável pelo cumprimento das obrigações assumidas perante o *segurado/beneficiário*, e a *seguradora* indenizará o beneficiário, até o limite especificado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do descumprimento de tais obrigações. (grifos do autor)²³⁷

Assim, há uma relação cuja estrutura não é linear entre duas partes, mas triangular. São três agentes envolvidos em dois contratos: o principal, cujo conteúdo é a prestação de um devedor em favor de um credor; e o acessório, o qual garante a prestação do principal, graficamente, é possível fazer a seguinte representação ao no contexto de um contrato de obra pública:

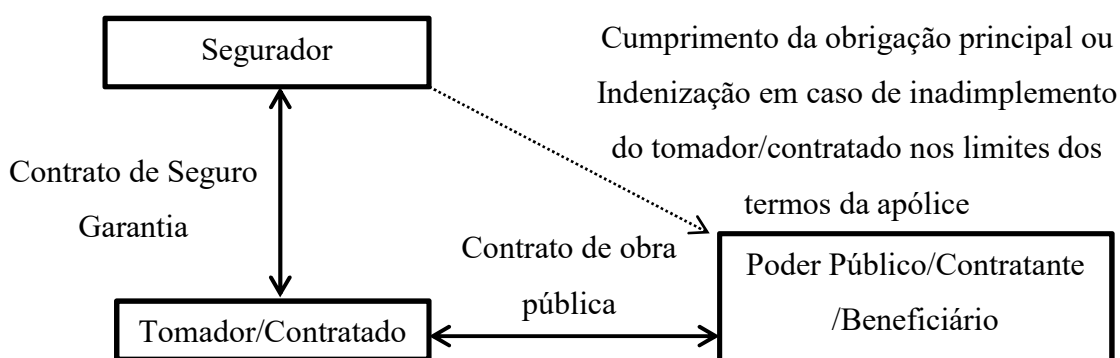


Figura 1 - Dinâmica da relação. Fonte: elaboração própria do autor

²³⁵ Ibidem, p. 50.

²³⁶ Idem.

²³⁷ BURANELLO, Renato Macedo. **Do Contrato de Seguro: O seguro garantia de obrigações contratuais**. Op. Cit. p. 130.

É interessante notar que relação entre a Administração Pública contratante, o beneficiário da garantia, e o segurador ocorre de forma indireta, apenas no caso de inadimplemento da obrigação principal pelo tomador/contratado, oriunda do contrato de obra pública, no qual o garantidor deverá ou cumprir a obrigação principal e realizar, por seus esforços, a obra, ou indenizar o contratante, nos limites dos termos da apólice emitida.²³⁸

Tal estrutura demonstra de forma curiosa como os elementos da fiança e do seguro se combinam no seguro garantia. Na relação entre o segurador, garantidor, e o terceiro credor, pode-se ver a manifestação dos princípios da fiança, enquanto na relação entre o segurador e o tomador de seu serviço sobressai a natureza, e a disciplina normativa, securitária do instituto. Essas duas ordens de relação são empregadas “para admitir ao negócio o exercício de sua função econômico-social de adimplemento pelo segurador, da obrigação do tomador”²³⁹. Justamente por isso, é possível afirmar que o seguro garantia “contempla elementos de maior amplitude, que são integrantes da expressão segurança, no cumprimento de uma obrigação, ou seja, o efetivo *prestar*”²⁴⁰ vai além do pagamento de mera importância pecuniária em caso de sinistro, como no caso do *performance bond*, e pode se consubstanciar na própria

²³⁸ Nesse sentido: “O contrato de seguro garantia é firmado entre o tomador e o segurador; o segurado não faz parte dessa relação. Estabelece-se uma relação triangular, *sob três relações jurídicas diferentes que englobam três contratos conexos*. A primeira é a relação que existe entre o tomador e o segurado, o contrato principal no qual as partes convencionam obrigações de dar ou fazer e deveres recíprocos. A segunda é a relação entre a companhia seguradora e o tomador, que objetiva a emissão de uma apólice de seguro garantia que descreva o cumprimento das obrigações do tomador no contrato principal. A terceira e última relação é aquela que estabelece o vínculo entre seguradora e segurado, que, em caso de não-pagamento do tomador garantido, obrigará o pagamento dos prejuízos ocorridos, cobertos pela apólice de seguro.” (grifos nossos). Ibidem, pp. 177-178. Seguindo a mesma lógica: “Evidenciam-se três relações jurídicas diferentes, formadas por três contratos conexos. A primeira é a relação do tomador com o segurado, que é o contrato onde as partes convencionam obrigações e deveres recíprocos, inclusive, o compromisso de apresentação de garantia; a segunda é a relação contratual entre a companhia seguradora e o tomador, que objetiva a emissão de uma apólice de seguro garantia, onde seja atestado o cumprimento das obrigações do tomador no contrato principal. Este contrato é autônomo e não interfere na relação jurídica com o segurado, inclusive, este sequer tem conhecimento das bases acordadas. Em terceiro plano está a relação contratual da seguradora para com o segurado que, em caso de inadimplemento do tomador garantido, ensejará a obrigação de cumprir com o objeto da apólice, ou seja, pagamento do valor dos prejuízos ocorridos, cobertos pela apólice de Seguro Garantia, ou contratar, terceira empresa, para fazer, fornecer, executar a obrigação como se fosse o tomador do seguro. POLETO, Gladimir Adriani **O Seguro Garantia: em busca de sua natureza jurídica**. Op. Cit. pp. 56-57.

²³⁹ BURANELLO, Renato Macedo. **Do Contrato de Seguro: O seguro garantia de obrigações contratuais**. Op. Cit. p. 187.

²⁴⁰ POLETO, Gladimir Adriani **O Seguro Garantia: em busca de sua natureza jurídica**. Op. Cit. p. 57.

execução da obrigação original pelo segurador²⁴¹, e essa possibilidade de *step-in* da seguradora é uma das marcas distintivas entre o instituto em comento e a fiança.

Pode-se destacar dois benefícios do instituto, um, mais evidente para o segurado/beneficiário, outro, menos claro, para o tomador do seguro. Para o primeiro, visivelmente, há a proteção de seu interesse como contratante, credor, na obrigação originária, a qual passa a contar com um reforço na sua execução, até porque o segurador realiza uma análise relativa à capacidade do tomador de fazer frente à obrigação assumida previamente à emissão da apólice, já para o contratado, este passa a contar com maior flexibilidade, uma vez que não precisa mobilizar parte de seu ativo como forma de garantia, para obter financiamento, quando necessário, para o bom desempenho de sua obrigação no contrato original.²⁴² Cria-se ainda, um incentivo a maior cooperação entre as partes, por um lado o tomador sabe que a sua inadimplência poderá gerar efeitos futuros quando precisar de novos seguros para novos projetos, por outro, o beneficiário possui obrigações, por força da apólice, de cooperar com a seguradora e não embarçar a atuação do tomador, sob pena, inclusive de perder a cobertura securitária.²⁴³ Cria-se, com isso, um ambiente no qual a finalização do projeto se torna o objetivo central de todas as partes envolvidas, dessa maneira:

A concepção dessa relação jurídica é a ajuda recíproca, pois o que as partes pretendem é, de forma objetiva, a finalização do projeto iniciado. A inadimplência de qualquer dos envolvidos paralisa e prolonga os efeitos do projeto concluído, por isso, é fato comum a seguradora se fazer presente em determinados casos, como figura de mediador-cooperador, em busca do objetivo fim, qual seja, a conclusão do projeto, sem que ocorra ônus extraordinário para qualquer das partes. Qualquer forma de inadimplência, seja do tomador ou do segurado, acaba por comprometer o todo, não só no que tange nos aspectos econômicos do projeto, como, também, no que se refere aos prejuízos sociais decorrentes do efeito da inadimplência.²⁴⁴

²⁴¹ Idem.

²⁴² BURANELLO, Renato Macedo. **Do Contrato de Seguro: O seguro garantia de obrigações contratuais**. Op. Cit., pp. 143-144.

²⁴³ Nesse sentido: “No instrumento em análise, há uma releitura essencial sobre a relação contratual, pois, como constatou-se, a relação jurídica envolve três partes, o segurador, o tomador e o beneficiário, os quais estão vinculados por instrumentos distintos, sendo credores e devedores recíprocos. Assim, cada qual possui inúmeras obrigações e deveres constituídos na forma de direitos subjetivos, potestativos, faculdades, obrigações, ônus, sujeições, dever de garantia, solidariedade, cooperação mútua, entre outras.” POLETTI, Gladimir Adriani **O Seguro Garantia: em busca de sua natureza jurídica**. Op. Cit. p. 57.

²⁴⁴ Idem.

Tem-se, portanto, uma relação jurídica cuja finalidade reside, essencialmente, na realização de um projeto. Na realidade, quando se adquire um seguro, a ideia é sempre não usá-lo, e não é diferente com o seguro garantia, mesmo para o beneficiário, a realização da obrigação principal sem qualquer embaraço é o cenário ideal, pois garante a entrega da sua prestação no tempo esperado. Precisamente por ter um potencial integrativo entre as partes que se entende a relação do *performance bond* como uma forma diferenciada de garantia.

3.4. Como é regulado no Brasil.

Esclarecidos os principais caracteres do seguro garantia, seu conceito, natureza jurídica e dinâmica de funcionamento, deve-se passar ao estudo de sua regulação no Brasil.

Inicialmente, como já adiantado em tópico acima, não há uma lei específica sobre o seguro garantia e/ou suas espécies²⁴⁵. Há apenas menções em alguns dispositivos legais sobre a sua aceitabilidade como instrumento de garantia em determinada relação jurídica, como ocorre no art. 56, §1º, II da Lei n.º 8.666/93, no caso de licitações e contratos administrativos e no art. 9º, II da Lei n.º 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), para as execuções fiscais.

Coube, portanto, à normatização administrativa, nesta situação efetuada pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, regulamentar o instituto. Atualmente, o dispositivo normativo responsável pela matéria é a Circular SUSEP n.º 477 de 30 de setembro de 2013.²⁴⁶

Além de prever, em seus 25 artigos, todas as regras básicas para a operacionalização do Seguro Garantia, em qualquer das suas modalidades, a referida circular, em seus anexos I e II apresenta cláusulas padrão dos contratos, respectivamente para as hipóteses de segurados públicos e privados. Ademais, há previsão de cláusulas gerais, comuns a quaisquer espécies de seguro garantia, e outras específicas para categorias especiais.

²⁴⁵ O Projeto de Lei destinado a regular a matéria (PL 2.851/2003), até a presente data encontra-se parado desde 30 de abril de 2015, conforme; <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=150324> Acesso em 03 de novembro de 2019.

²⁴⁶ Destaca-se que são aplicáveis ao seguro garantia as normas comuns a quaisquer modalidades de seguro, especialmente normas de natureza técnica de contabilidade, como as referentes à Nota Técnica Atuarial.

Nesse sentido, o art. 2º da circular apresenta o objetivo do seguro garantia, qual seja, “garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado”. Tal objetivo é, ainda, reproduzido nas cláusulas padrões contratuais dos anexos I e II, com as devidas adaptações.²⁴⁷ Especificamente em relação ao setor público, o art. 4º²⁴⁸, como já mencionado acima, traz a definição do instituto quando o segurado é ente ou entidade da Administração Pública.²⁴⁹

Para evitar redundâncias desnecessárias com o que já foi exposto nos tópicos anteriores, além da descrição do objeto, será apresentada a normativa referente às contragarantias, ocorrência de sinistro, direito de sub-rogação do segurador e às hipóteses de perda de direitos do segurado/beneficiário, pois estes são os temas menos abordados acima, bem como os que acabam envolvendo maiores controvérsias.

²⁴⁷ A função do “contrato designado de ‘condições gerais contratuais’ caracteriza-se por dois objetos distintos: o primeiro é a regulação dos direitos e das obrigações do tomador e da seguradora, quanto à emissão de uma apólice ou de várias apólices para uma terceira parte que não tem qualquer ingerência sobre esse contrato; e o segundo é a constituição de garantias para preservar a seguradora num eventual inadimplemento.” POLETTI, Gladimir Adriani **O Seguro Garantia: em busca de sua natureza jurídica**. Op. Cit. p. 58.

²⁴⁸ Para poupar o trabalho ao leitor de retornar à seção, novamente se reproduz o dispositivo: “Art. 4º Define-se Seguro Garantia: Segurado –Setor Público o seguro que objetiva garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões ou permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou ainda as obrigações assumidas em função de: I –processos administrativos; II –processos judiciais, inclusive execuções fiscais; III –parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não em dívida ativa; IV –regulamentos administrativos. **Parágrafo único.** Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso. (grifos nossos).

²⁴⁹ Tendo em vista o fato de a presente dissertação ser voltada ao tema das obras públicas, apenas os dispositivos das condições do seguro para o setor público (anexo I) serão reproduzidos. Nesse sentido, o objeto é descrito na cláusula 1ª, com o seguinte teor: 1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de: I – processos administrativos; II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais; III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa; IV – regulamentos administrativos. 1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso. Especificamente em relação ao seguro garantia para serviços de construção (obras públicas), encontra-se a seguinte redação: 1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços. 1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93. 1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.

Inicialmente, a própria seguradora precisa se proteger para o caso de inadimplemento do tomador, para isso, há a previsão de um terceiro contrato, o de contragarantia. Nesse caso, há um acordo menos regulado, no qual a liberdade da parte é mais ampla, tanto é que, conforme previsão do art. 21, p. único da Circular SUSEP n.º 477/2013, tal contrato será pactuado de forma livre, bastando não atingir o direito do segurado, e, ainda, não será regulado pela SUSEP. Veja-se a disposição normativa:

Art. 21 O contrato de contragarantia, que rege as relações entre a sociedade seguradora e o tomador, será livremente pactuado, não podendo interferir no direito do segurado.

Parágrafo único. O contrato de contragarantia de que trata o caput não será submetido à análise da Susep.

Tanto há maior liberdade das partes para negociar os termos das contragarantias que as condições dos contratos, anexos à circular em estudo, não trazem previsões regulamentando sua constituição e eventual execução, se limitando a permitir o recurso a elas no caso de não pagamento do prêmio pelo tomador.

Em relação à ocorrência de sinistro²⁵⁰, esta deve ser feita nos termos do art. 12 da Circular SUSEP n.º 477²⁵¹ e da Cláusula 7ª das condições gerais²⁵² estabelecidas pelo órgão regulador.

A notificação do sinistro deve ser instruída com a notificação prévia do segurado para o tomador, informando a inadimplência, da descrição do fato e a

²⁵⁰ Como já destacado, no caso em estudo, o sinistro é configurado a partir do inadimplemento do tomador de sua obrigação originalmente assumida. Nesse sentido: “Para que o segurado seja admitido a reclamar o pagamento da indenização de seguro garantia como estudado anteriormente, não é necessário como requisito a configuração do sinistro provar que o devedor contratual se encontrava em situação patrimonial deficitária ou em estado de iliquidez. Basta provar que deixou de cumprir, sem relevante razão de direito, as obrigações que assumiu pelo contrato, de modo a afetar o interesse segurável.” BURANELLO, Renato Macedo. **Do Contrato de Seguro: O seguro garantia de obrigações contratuais**. Op. Cit., p. 202.

²⁵¹ Art. 12 A seguradora deverá deixar claro nas Condições Contratuais, para cada modalidade, os procedimentos a serem adotados com a finalidade de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro e oficializar a Reclamação de Sinistro, além dos critérios a serem satisfeitos para a Caracterização do Sinistro. §1º A Expectativa de Sinistro deverá descrever o fato que possa gerar prejuízo ao segurado, sendo que o sinistro restará caracterizado quando comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice. §2º Deverão ser especificados e definidos os procedimentos a serem adotados pelo segurado, assim como os documentos que deverão ser apresentados.

²⁵² 7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem; 7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro; 7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar; 7.3. 7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais; (Alterado pela Circular SUSEP n.º 577/2018) 7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

respectiva documentação comprovatória do fato ensejador da inadimplência e da apólice do contrato e eventualmente seus aditivos.²⁵³⁻²⁵⁴

A descrição do sinistro deverá ser realizada de forma objetiva e clara, e, a seguir, protocolada na companhia seguradora que, imediatamente, registrará o reclamo no livro de registro auxiliar obrigatório de sinistros avisados. Os documentos citados, que acompanham a reclamação deverão comprovar efetivamente a ocorrência do sinistro; que aquela inadimplência do tomador está coberta pela apólice, ou seja, dentro da vigência do seguro; que a realização do acontecimento gerou prejuízos no importe de X.²⁵⁵

A princípio, por conta da própria redação do art. 12, §1º da Circular SUSEP n.º 477/2013, entende-se que não é possível a emissão de apólices a primeiro requerimento, isto é, sem que seja feita alguma avaliação da ocorrência do sinistro pela seguradora, motivo pelo qual a comunicação do sinistro bem como a sua adequada instrução merecem atenção por parte do segurado.²⁵⁶⁻²⁵⁷

²⁵³ POLETO, Gladimir Adriani **O Seguro Garantia: em busca de sua natureza jurídica**. Op. Cit. p. 60.

²⁵⁴ Especificamente para os contratos envolvendo obras públicas, tem-se as seguintes disposições no Anexo I da Circular SUSEP n.º 477/2013: 4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro. 4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro. 4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais: a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador; b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador; c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador; d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos; e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos; 4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro; 4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

²⁵⁵ POLETO, Gladimir Adriani **O Seguro Garantia: em busca de sua natureza jurídica**. Op. Cit. p. 60. .

²⁵⁶ No mesmo sentido: “Por outro lado, a reclamação de sinistro pode ser feita por intermédio de uma simples solicitação de pagamento; contudo, tal procedimento é exceção à regra do seguro, embora ocorra nas chamadas ‘garantias a primeiro requerimento ou à primeira demanda’, as quais não permitem ao segurador promover a averiguação e configuração do sinistro, pois, como o próprio nome diz, são pagas mediante o simples requerimento do segurado. No Brasil, tais garantias são inexistentes ou de raríssima utilização, ainda que seja desejada pelos segurados. Porém, trata-se de um instrumento perigoso, uma vez que o tomador estará sempre suscetível a um ato de vontade do segurado. (...) a incondicionalidade deste instrumento de garantia, ou seja, havendo ou não sinistro, a companhia de seguros deverá promover o pagamento da importância segurada mediante a simples solicitação do segurado, o que leva o tomador a sofrer constante pressão do segurado, no sentido de atender a todas Às

Constatado o sinistro, a seguradora tem duas opções: (i) indenizar o segurado no limite máximo estabelecido pela apólice; (ii) assumir para si a prestação e a realizando por meio da contratação de terceiros.²⁵⁸⁻²⁵⁹

Realizada a obrigação ou paga a indenização, ocorrerá a “sub-rogação do segurado para a seguradora que pagou pela inadimplência do tomador e que possa recuperar deste – devedor originário – pelo prejuízo causado”²⁶⁰⁻²⁶¹, naturalmente, a sub-rogação se dará apenas nos limites pagos pela própria seguradora, nos termos constantes da apólice.²⁶²

solicitações deste, sob pena de ser considerado inadimplente pela simples declaração do segurado. Pelo atual sistema normativo, o Seguro Garantia não permite apólices a primeiro requerimento, portanto, é inexistente no Brasil.” Ibidem, pp. 60-61.

²⁵⁷ Corroborando essa informação, próprio STJ considera que o Performance Bond não constitui título executivo extrajudicial. RESP 476450 / RJ, Relator Min. Luiz Fux.

²⁵⁸ Nos termos do art. 13 da Circular SUSEP 477/2013 e da cláusula 8ª das condições gerais do Seguro Garantia para segurado do setor público: 8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes: I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice. 8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro. 8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências. 8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão. 8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. 8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

²⁵⁹ Nesse sentido: “Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até o limite máximo da garantia e segundo uma das formas abaixo, conforme for definido entre as partes nas condições gerais do seguro: realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob sua integral responsabilidade; ou pagando financeiramente os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.” BURANELLO, Renato Macedo. **Do Contrato de Seguro: O seguro garantia de obrigações contratuais**. Op. Cit., p. 206.

²⁶⁰ POLETO, Gladimir Adriani **O Seguro Garantia: em busca de sua natureza jurídica**. Op. Cit. p. 62

²⁶¹ De igual maneira: “Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e ações do segurado contra o tomador ou terceiros, cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. Essa sub-rogação inclui o direito à execução das contragarantias prestadas pelo tomador dentre as condições da aceitação do risco pela seguradora e formalizadas no momento da contratação do seguro.” BURANELLO, Renato Macedo. **Do Contrato de Seguro: O seguro garantia de obrigações contratuais**. Op. Cit., p. 207.

²⁶² Nesse sentido, tem-se a cláusula 10 das condições gerais do contrato de seguro garantia referentes a segurado do setor público: 10. Sub-Rogação: 10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. 10.2.

Todavia, é importante ressaltar que as condições gerais do seguro garantia para segurado do setor público (anexo I da Circular SUSEP n.º 477/2013) contemplam a possibilidade de perda do direito à cobertura pelo segurado, nos termos da cláusula 11, abaixo transcrita:

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

Com exceção do inciso I (quando da ocorrência de caso fortuito e força maior), todas as hipóteses aventadas pela cláusula dizem respeito a condutas do segurado capazes de agravar o risco de inadimplemento pelo tomador, isto é, o risco coberto pelo seguro garantia.

Tal cláusula pode funcionar como um mecanismo de proteção tanto do tomador quanto da seguradora contra eventual risco moral do próprio beneficiário, na esteira do que viu-se no capítulo anterior sobre tema. Nesse sentido, uma vez se sentindo protegido pelo *performance bond*, o beneficiário poderia simplesmente não se empenhar adequadamente em realizar a sua parte da avença, não se preocupando em agir verdadeiramente como parceiro contratual de seu contratado. Para evitar isso, a SUSEP incluiu nas disposições gerais do seguro garantia situações nas quais a má atuação do contratante pode levá-lo à perda de sua cobertura contratual, incentivando a sua cooperação na realização do projeto de engenharia.

É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

Tem-se, ainda, a normatização do fim da cobertura da apólice. A Circular SUSPER n.º 477/2013, em seu art. 16, previu as condições para se considerar finalizada a cobertura contratual, nesse sentido:

Art. 16 A garantia do Seguro Garantia extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme §4º do art. 12:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Contratuais do seguro.

Parágrafo único. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas neste artigo, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/1993.

Tais previsões são reforçadas pelas condições gerais (anexo I da Circular SUSEP n.º 477/2013) cláusula 14²⁶³, e especificamente para seguros garantia para construção, fornecimento ou prestação de serviços, mais relevantes para presente dissertação, conforme cláusula 3ª das disposições especiais para modalidade²⁶⁴.

²⁶³ 14. Extinção da Garantia: 14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais: I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice; II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice; IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais. 14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93. (Alterado pela Circular SUSEP nº 577/2018)

²⁶⁴ 3. Vigência: 3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras: I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras; II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público. 3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

Não obstante todas as disposições apresentadas, identifica-se duas omissões relevantes na norma administrativa. A primeira delas se refere à ausência de regramento sobre a forma de atuação da seguradora como fiscalizadora do tomador de serviços. Na medida em que eventual deficiência na prestação do serviço pelo tomador, é indiscutível o interesse do segurador acompanhar a execução da obrigação. Embora, para emitir a apólice, tenha feito a avaliação da capacidade do contratado, a possibilidade de fiscalizar a efetiva execução do contrato permite à seguradora atualizar constantemente o risco de inadimplemento do contratado, bem como de, a fim de evitar a ocorrência do sinistro, apontar quaisquer fontes de possíveis inadimplementos no futuro.

Todavia, para atuar de forma adequada como fiscalizador, o segurador precisa de acesso não apenas ao sítio das obras, como também a documentos e contratos relacionados àquele objeto especificamente. Com isso, não parece o ideal mantê-lo sob a dependência da necessidade de realizar acordos com o tomador de serviço para obter tais acessos, devendo esse direito ser garantido a partir de norma cogente.

Outra omissão relevante se dá quanto às regras de *step-in*, ou seja, não há uma normatização, sequer nos anexos da Circular SUSEP n.º 477/2013, relativa ao procedimento de assunção e execução pelo segurador da obrigação inadimplida pelo tomador. Portanto, a procedimentalização da entrada da seguradora no cumprimento do objeto do contrato deverá ser realizada, necessariamente, mediante normas contratuais estabelecidas pelas partes, seja no momento da emissão da apólice, seja no momento da confirmação do sinistro e escolha da seguradora por completar a execução.

A falta dessa regulamentação pode gerar insegurança para os seguradores, desincentivando a sua entrada como executor da obra, e incentivando que resolvam a demanda do segurado a partir da indenização. Não parece ser este o melhor uso do seguro garantia, uma vez que o pagamento da indenização, apesar, de ser reconhecida como meio eficaz para a compensação do erário, não ser, a longo prazo, a melhor forma de solucionar a não completude do projeto. Isso porque a Administração deverá, novamente, selecionar o parceiro e firmar novo contrato, o que consome tempo, enquanto as estruturas já incorporadas pelo inadimplente vão se deteriorando e aumentado ainda mais o custo para sua recuperação e, conseqüentemente, para conclusão da obra.

Em síntese, é possível resumir da seguinte maneira as etapas do seguro garantia, da sua contratação até eventual execução pela seguradora da obrigação inadimplida: (i) Envio de documentação cadastral para a análise da proposta pelo segurador; (ii) análise econômico-financeira, de caráter e de competência pelo segurador; (iii) efetivação do cadastro determinando limites e taxas; (iv) assinatura do contrato de contragarantia; (v) subscrição do risco a partir da análise do contrato principal a ser garantido; (vi) emissão da apólice. Em caso de sinistro, nos contratos para garantia de construção, fornecimento e prestação de serviços para segurado do setor público, haverá: (vii) notificação de Expectativa de Sinistro pelo beneficiário para o tomador; (viii) Conversão da Expectativa de Sinistro em Reclamação de Sinistro, mediante comunicação do segurado à seguradora; (ix) Caracterização do Sinistro pela seguradora; (x) escolha, pela seguradora, entre indenizar o segurado ou adimplir a obrigação principal; (xi) sub-rogação da seguradora em face do tomador.²⁶⁵

3.5. Mercado Brasileiro de Seguro Garantia.

Por fim, é importante avaliar a recente evolução do mercado de seguro garantia no Brasil. Para tanto, utilizou-se a evolução dos prêmios pagos neste produto a partir de 2000. A escolha de tal data se justifica, primeiro pela disponibilidade dos dados no portal pesquisado e em razão do período de vinte anos ser suficiente para se compreender o crescimento de um instituto que apenas se desenvolveu efetivamente desde 2011.

Para elaboração da tabela apresentada, realizou-se busca no Sistema de Estatísticas da SUSEP (SES)²⁶⁶. Tal banco de dados separa as estatísticas por operações, escolheu-se a operação de seguros, e dentro dos ramos desta, a subopção de “Garantia – Segurado Setor Público”.

Tabela 2: Evolução Histórica do total de Prêmios em Seguro Garantia – Setor Público.

Ano	Total de Prêmios
2000	R\$ 30.184.012,00

²⁶⁵ Parte dessa ordem é destacada em SOUZA, Sergio Ricardo de Magalhães. **Seguro Garantia**. 7ª Edição. Escola Nacional de Seguros, Diretoria de Ensino Técnico. Rio de Janeiro, 2016, p. 20.

²⁶⁶ Sítio do sistema: <http://www2.susep.gov.br/menuestatistica/SES/principal.aspx>

2001	R\$ 98.641.623,00
2002	R\$ 161.988.320,00
2003	R\$ 24.179.269,00
2004	R\$ 17.369.333,00
2005	R\$ 202.514,00
2006	Sem emissão
2007	Sem emissão
2008	Sem emissão
2009	Sem emissão
2010	Sem emissão
2011	R\$ 429.320.619,00
2012	R\$ 554.162.811,00
2013	R\$ 779.529.519,00
2014	R\$ 961.495.471,00
2015	R\$ 1.467.013.836,00
2016	R\$ 1.900.602.985,00
2017	R\$ 2.462.205.257,00
2018	R\$ 2.441.707.124,00
2019 ²⁶⁷	R\$ 2.238.022.945,00

Fonte: Banco de Dados da SUSEP

É possível observar, a partir da evolução dos valores acima, que a consolidação do mercado ocorreu apenas a partir do ano de 2011. Apenas com o inícios dos projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e com os grandes eventos esportivos no Brasil (Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016) que o mercado ganhou alguma força.²⁶⁸ Todavia, ainda não desenvolveu todas as suas potencialidades, e pode ser considerado “novo e pequeno no Brasil, em comparação aos demais tipos de seguro comercializados”²⁶⁹

²⁶⁷ Até outubro de 2019.

²⁶⁸ Nesse sentido: “... o mercado somente se consolidou a partir de 2011, onde grandes obras estruturais foram realizadas no Brasil, como o PAC 2, com investimentos que somam R\$ 955 bilhões de 2011 a 2014 e os grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, que ajudaram na crescente do ramo foram os eventos de grande porte no país”. DORIA, Thaila Renata Teixeira Doria. **Seguro Garantia como Alternativa às Obras Públicas Paralisadas no Brasil**. Op. Cit., p. 42.

²⁶⁹ Ibidem, p. 52.

Credita-se o tamanho reduzido do mercado de seguro garantia à possibilidade do licitante escolher qual o tipo de garantia ele poderá oferecer, e não a Administração Pública ter esse direito. Ademais, como se trata de um percentual baixo (5 a 10%) do contrato, o volume garantido, e por consequência os prêmios cobrados, acabam ficando em valores menores.²⁷⁰

Embora o mercado ainda, de fato, seja pequeno, pela avaliação da tabela acima, é possível observar sua capacidade de crescer de forma constante se o cenário econômico e institucional se mostrar adequado. Portanto, a sua ampliação pode, com o tempo, ser absorvida pelo crescimento do mercado.

²⁷⁰ Cf. *Ibidem*, p. 42.

4. CAPÍTULO 3: Análise do uso de Performance Bond nos contratos públicos

4.1. A Utilização do Seguro Garantia de Execução (*Performance Bond*) em obras públicas no Direito Estrangeiro.

Olhar para outros sistemas jurídicos com algumas semelhanças ao seu é uma forma tradicional na teoria jurídica de se buscar novas alternativas para problemas antigos. Não apenas se busca novas possibilidades em outras ordens, mas muitas vezes se observa o direito estrangeiro como forma de se legitimar escolhas normativas a partir de um argumento de fundo experimentalista, isto é, olha-se para um instituto jurídico e se pensa: “se deu certo em outro lugar, pode ser que funcione aqui”.²⁷¹

Ao analisar legislações mundo afora, pode-se “identificar a *repetição de problemas semelhantes ao longo de ordens jurídicas distintas*”²⁷², tais problemas encontram-se “ligados ao *âmbito interna* de cada centro decisório”²⁷³, e se replicam no âmbito de outros ordenamentos.

Quando se pensa no direito administrativo, como o caso da presente dissertação, não há porque abandonar essa possibilidade de observar como a Administração Pública estrangeira enfrentou uma questão atualmente relevante para a Administração Nacional²⁷⁴. Nesse sentido, a literatura especializada destaca o

²⁷¹ Concorde-se com a ideia de que o diálogo entre diferentes sistemas jurídicos é capaz de proporcionar o auxílio mútuo na busca de soluções e aperfeiçoamento institucional para problemas encontrados em diferentes ordens jurídicas. Tal raciocínio tem como fundamento a ideia de “...*racionalidade transversal*, consubstanciada no aprendizado recíproco e no intercâmbio criativo entre diferentes ordens jurídicas. A racionalidade transversal, portanto, relaciona-se com a diversidade na externalização e internalização de informações entre sociedades, que também se manifesta na produção de normas diferentes”. FERRARI, Isabela. **Transadministrativismo: Uma teoria dos transplantes jurídicos aplicada ao direito administrativo**. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2018. pp. 20-21.

²⁷² Ibidem, p. 11, grifos da autora.

²⁷³ Idem, grifos da autora.

²⁷⁴ Nesse sentido: “O direito administrativo corresponde a um campo especialmente adequado aos transplantes jurídicos em decorrência de três fatores, inter-relacionados: a crescente acolhida que a noção de governança experimentalista vem encontrando nessa seara; a possibilidade de limitação da experiência administrativa ao âmbito local; e os mecanismos pouco formais que o direito administrativo costuma exigir para a adoção dessas experiências localizadas”. Ibidem, p. 168.

Transadministrativismo²⁷⁵ como um instrumento possível para abordar os problemas ubíquos no direito administrativo.²⁷⁶

O transadministrativismo ou *direito transadministrativo* corresponde a um modelo comportamental de busca de soluções para problemas identificados na seara administrativa que pode ser concebido em etapas. Primeiro, resolver problemas a partir de um enfoque transadministrativista corresponde a perceber que as diversas práticas dos Estados-nacionais e de órgãos administrativos associados a instâncias internacionais e extraestatais apresentam padrões de semelhança e de conexão suficientemente profundos a ponto de possibilitar que soluções teóricas ou boas práticas associadas a um sistema possam encontrar campo profícuo de aplicação em sistema diverso. Segundo, o direito transadministrativo pressupõe a adoção de um padrão de atuação que favoreça o diálogo efetivo com as demais ordens jurídicas. Essa postura, aberta a influxos externos, pode ser entendida como o comportamento de (i) perceber que o sistema em que se insere o agente é limitado por dogmas e idiossincrasias, estando sujeito, assim a um “limite de observação” (Neves); (ii) entender que os sistemas observados também estão limitados por dogmas e idiossincrasias próprios; (iii) examinar criticamente o sistema que aparenta oferecer a melhor resposta para o problema que se apresenta e verificar em que medida a referida solução poderia ser aplicada e adaptada ao sistema do observador tendo em conta suas próprias características. O que se denomina direito transadministrativo representa, portanto, um recorte específico do direito administrativo comparado.²⁷⁷ (destaque da autora)

Com isso, os agentes responsáveis pela produção normativa de um país passam a entender que, em primeiro lugar, eles possuem limitações intrínsecas às condições em que estão inseridos, o que constitui seu “limite de observação”, os quais podem ser superados pela análise de outras ordens jurídicas, não adstritas aos mesmos limites. Todavia, não se deve esquecer que diferentes ordens estarão submetidas a outros “limites de observação”, implicando na observação crítica dos institutos em análise.

²⁷⁵ Adota-se, aqui, o mesmo conceito de Isabela Ferrari: “Um mecanismo que se destaca corresponde à postura de sistematicamente buscar em outras ordens jurídicas (estatais e extraestatais, de diferentes níveis) soluções pré-prontas para lidar com os desafios que o direito administrativo contemporâneo enfrenta. A essa postura sistemática damos o nome de *transadministrativismo*”. (grifos da autora), *ibidem*, p. 166.

²⁷⁶ É possível indicar que a matriz intelectual do Transadministrativismo é a teoria dos *legals transplants*, cuja tese central “... é a rejeição do postulado de que o direito tem uma relação inerente e extremamente próxima à sociedade na qual ele opera. É justamente esse descolamento entre o direito e a realidade social subjacente que torna possível a transferência de direito de um local para o outro. Watson parte do princípio que não há correlação exata e completa entre os campos sociais, econômicos, políticos e o direito, e para isso se baseia em exemplos da história legal da Europa, principalmente o direito romano e o direito inglês.” ARAÚJO, Thiago Cardoso. **Análise Econômica do Direito no Brasil. Uma leitura à luz da teoria dos sistemas**. Op. Cit., p. 252.

²⁷⁷ FERRARI, Isabela. **Transadministrativismo: Uma teoria dos transplantes jurídicos aplicada ao direito administrativo**. Op. Cit., pp. 166-167.

A vantagem das importações reside na maior dificuldade de se criar, do vácuo, uma nova solução institucional em comparação com a busca, em outros sistemas, de remédios utilizados para uma patologia semelhante²⁷⁸. Mais um benefício em potencial é a possibilidade de antecipação de efeitos colaterais observados no sistema original e que podem ser repetir na ordem importadora.

Naturalmente, algumas precauções são necessárias, todo ordenamento possui seus particularismos, e isso vale para os dois sentidos, tanto para a ordem importadora quanto para que serve de modelo²⁷⁹. Dessa maneira, quando um instituto jurídico depende, para seu funcionamento adequado, de condições muito particulares observados na ordem jurídica original, a sua importação não parece recomendável. Ou então se a ordem importadora possui características muito peculiares em determinada seara, importar algo que vá contra tais peculiaridades também é um convite para uma rejeição.

Sobre a rejeição, Isabela Ferrari afirma que são duas hipóteses em que se pode considerar que ela ocorreu, “hipótese (i) em que a transferência não se completa, ou (ii) em que o núcleo essencial da ideia jurídica é afetado no processo de importação, desnaturando-a”²⁸⁰. Isto é, a importação não ocorre de forma adequada quando a

²⁷⁸ Nesse sentido: “As interações entre ordens jurídicas distintas permitem identificar dois tipos de problema: a reprodução de problemas semelhantes e os problemas transcendentais. No primeiro caso, os problemas se relacionam ao âmbito interno de cada centro decisório e se replicam no âmbito interno de outras ordens jurídicas. (...) Em um momento no qual a globalização acelera a interação entre pessoas físicas e jurídicas, além de ampliar a desigualdade (social, econômica, informacional etc), os estudos comparativos passam a ser sistematicamente empreendidos para lidar com problemas que surgem e se intensificam, ou com novas situações que demandam uma pronta resposta da ciência do direito. Ao invés de elaborar um panorama normativo *ab nihilo*, criar instituições próprias ou sugerir novas práticas, legisladores, *framers*, doutrinadores, agentes políticos, movimentos sociais e outros formadores de opinião passaram a estudar outras ordens jurídicas estatais ou extraestatais (supranacionais, internacionais, transestatais, ou internas não estatais), em busca de soluções pré-prontas que, após algumas adaptações, pudessem ser sugeridas ao ambiente em que situam. Importar soluções jurídicas pode ser uma estratégia interessante para lidar com o problema da aceleração da vida, pois representa um *atalho mental* que permite economizar tempo e energia em um mundo excessivamente dinâmico. Da mesma forma, em uma realidade em que atingir consensos torna-se mais difícil em razão do pluralismo e do multiculturalismo que permeiam a sociedade contemporânea, uma solução jurídica transplantada de forma adequada parece trazer, em alguma medida, uma pretensão, (ainda que fraca) de legitimidade, por representar uma solução bem-sucedida em ordem alienígena.” Ibidem, pp. 155-156,

²⁷⁹ Sobre os particularismos: “Ainda, com relação à temática de transplantabilidade de ideias, torna-se imprescindível atentar para os *particularismos*, denominados *odd details*, por Frankenberg. Os particularismos correspondem a leis, doutrinas, entendimentos, argumentos, práticas, instituições – ou, em uma palavra, *ideias* –, que são reconhecidos como *insuscetíveis de migração*. Essa insuscetibilidade decorre da dificuldade de descontextualizar esses itens da realidade à qual se aplicam. Como os particularismos se relacionam intimamente com características específicas do ordenamento exportador, dificilmente replicáveis em qualquer outra ordem, eles aumentam – em muito – o risco de rejeições.” Ibidem, p. 77.

²⁸⁰ Ibidem, p. 75.

transferência não se concretiza, sendo abandonada no meio do processo, ou quando ela se concretiza, mas acaba sendo desnaturada em seu curso, representando uma nova instituição, diferente da que se propôs a transplantar originalmente.²⁸¹

Como exemplos de transplantes operados no Brasil é possível citar: Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000); Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013) e a Lei instituidora do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) (Lei n.º 13.334/2016).²⁸²

Curiosamente, um dos exemplos utilizados por Isabela Ferrari sobre as possibilidades de solução de problemas a partir de transplantes jurídicos é justamente o tema da presente dissertação, o uso de *performance bonds*, nesse sentido, a autora afirma:

... observar o sucesso da adoção dos *performance bonds* americanos para lidar com problemas relacionados às licitações pode abrir nossos olhos para opções que não imaginávamos em razão da tendência ainda dominante de buscar na criação de exceções e fórmulas publicísticas (como as cláusulas exorbitantes) a solução para os problemas que surgem.²⁸³

²⁸¹ Thiago Cardoso Araújo faz um contraponto e complementação interessante sobre o tema ao utilizar o exemplo das Agências Reguladoras Americanas que teriam sido importados para o Brasil. Para o autor: “(...) Mota Prado compara as diferenças nos efeitos de reformas legais no país receptor com o que ocorre no país de origem, indicando que, diversas vezes, o que é transplantado funciona de maneira diferente do esperado. No caso das agências reguladoras verifica-se que, enquanto nos EUA, esta espécie de ente se sujeita ao poder Legislativo, sendo controlada por ele (teoria do domínio congressional), no Brasil, este conjunto de agências submete-se precipuamente à Presidência da República. E por uma série de características de nosso sistema político, após o Congresso Nacional ultrapassar o momento da confirmação e indicação de seus dirigentes, tem ele pouca influência sobre agir e agenda destas autarquias especiais. É bem verdade que se poderia tentar validar a teoria ressaltando-se que a esta deve ser vista de maneira mais ampla. Aproveitando-se da metáfora, não seria possível exigir funcionamento análogo à matriz caso o transplante fosse tímido, equivalente a um pequeno montante de células ou tecido destituído de funcionalidade. As agências reguladoras funcionam de maneira diversa nos EUA e no Brasil porque as instituições jurídicas circundantes – no caso, atribuição e prerrogativas do Poder Executivo e do Congresso Nacional também são distintas, propugna-se um transplante mais profundo, de todo o sistema. Veja-se que essa versão ‘forte’ de transplante legal apresenta ressonância com tendências imperialistas associadas ao Direito e Desenvolvimento, especialmente relacionadas à sua primeira fase. Nesta interpretação, se o transplante jurídico apresenta resultado aquém do esperado frente a comparação com o modelo original, a solução apontada seria um aumento do transplante jurídico. Contudo, retoma-se o exemplo para indiciar que as diferenças vão além do campo jurídico. No tocante à importação das agências reguladoras no cenário brasileiro, constata-se a oposição quase total na conjuntura política e econômica que implicou a sua criação, a ponto de Gustavo Binenbojm indicar que esta se deu com sinais trocados” ARAÚJO, Thiago Cardoso. *Análise Econômica do Direito no Brasil. Uma leitura à luz da teoria dos sistemas*. Op. Cit. pp. 254-255.

²⁸² Exemplos retirados de: FERRARI, Isabela. *Transadministrativismo: Uma teoria dos transplantes jurídicos aplicada ao direito administrativo*. Op. Cit., pp. 15-16.

²⁸³ Ibidem, p. 93.

Naturalmente, como parte das rejeições pode ocorrer por conta das particulares da ordem importadora, é importante sempre destacar como as condições do lugar de destino do transplante importam. Por conta disso, realizou-se, no primeiro capítulo, a análise das condições atuais da contratação de obras públicas no Brasil.

Com tudo isso em mente, passa-se à análise de um ordenamento jurídico que utiliza o seguro garantia na modalidade *performance bond* como instrumento de garantia de suas obras públicas.²⁸⁴

4.1.1. Estados Unidos (EUA).

Nos EUA, trata-se de instrumento utilizado há longa data, desde a promulgação do *Heard Act*, em 1894²⁸⁵. A origem do modelo, nos EUA, estava mais ligada à proteção de empregados e fornecedores dos contratantes com a Administração do que à salvaguarda dos interesses estatais.²⁸⁶

À época, o mercado americano de construção civil vivia dias incertos. Como não havia exigências específicas para a qualificação como construtor, e os custos iniciais eram baixos, praticamente qualquer pessoa poderia se qualificar como empreiteiro. Nesse cenário, diversos agentes econômicos se tornavam insolventes e a taxa de inadimplência era elevada, sendo frequente que muitas empreiteiras já estivessem em vias de falência antes mesmo das obras começarem,²⁸⁷ Para superar essa crise de confiança no mercado, foi editado o *Heard Act*.

²⁸⁴ Na presente dissertação decidiu-se apenas pela utilização do sistema americano como referência. Tal escolha se dá em razão do fato do *performance bond* em obras públicas estar mais consolidado em tal sistema jurídico, de forma que em outros ordenamentos ele concorre com outras espécies de garantia e termina por ser pouco utilizado, não fornecendo referências adequadas para a compreensão do fenômeno.

²⁸⁵ Nesse sentido: “A promulgação do *Heard Act* em 1894 estabeleceu proteção ao governo ao exigir dos empreiteiros a apresentação de uma única apólice de *performance e payment bond* para garantir as obras públicas federais, inclusive em relação às obrigações adicionais, como fazer pagamentos a todas as pessoas fornecendo-lhes trabalho e material de construção.” XAVIER, Vitor Boaventura. **O Seguro Garantia de Execução do Contrato – Performance Bond: Uma Análise dos Aspectos Regulatórios e Concorrenciais da sua Exigência pela Administração Pública no Brasil**. Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília – UnB. Orientadora: Prof.^a Dra. Ana de Oliveira Frazão Vieira de Mello. Brasília, 2017. p. 26.

²⁸⁶ Sobre a origem do instituto nos EUA, vide: FIEDLER, George, The Heard Act and the Miller Act after Fifty Years, 12 Ins. Counsel J. 22 (1945) Content downloaded/printed from *HeinOnline* <https://heinonline.org/HOL/Print?collection=journals&handle=hein.journals/defcon12&id=110> (acesso em 12/07/2018)

²⁸⁷ GOMES, Francisco Yokota Choucair. **Análise Econômica do Performance Bond nos Contratos de Obras Públicas**. [s.n.t.]. p. 17. Disponível em: https://www.academia.edu/30388405/AN%C3%81LISE_ECON%C3%94MICA_DA_PERFORMANC

Na promulgação do *Heard Act* estabeleceu-se a emissão em conjunto de um *performance bond*, o qual garantiria o interesse da Administração Pública, e de um *payment bond*, destinado a proteger os subcontratados e trabalhadores do executor da obra. A emissão conjunta do *performance* com o *payment bond* acabou se tornando “um impedimento à realização dos interesses do ente público beneficiário da apólice do *performance*, na medida em que seus interesses rivalizavam com os interesses dos subcontratados e trabalhadores beneficiários do *payment bond*”²⁸⁸

Durante o período do *New Deal*, marcado pelo avanço do investimento federal no setor de construção civil como forma de superar a grande depressão, as limitações materiais de procedimentais do *Heard Act* acabaram gerando algumas dificuldades para a execução das apólices.²⁸⁹ Com isso,

Embora o *Heard Act* tenha representado um avanço institucional significativo e proporcionado maior segurança aos investimentos da Administração, as dificuldades identificadas durante o período e as limitações procedimentais relacionadas ao *enforcement* da apólice motivaram o Congresso norte-americano a propor a chamada “alternativa Miller”, que estabeleceu definitivamente a separação entre as *performance* e as *payment bonds*. Os trabalhos foram bem sucedidos e, findaram na superação do *Heard Act* (1894) pelo *Miller Act* em 1935.²⁹⁰

Tal diploma normativo alterou algumas regras procedimentais e separou em instrumentos distintos o *performance* e o *payment bond*. Atualmente, o dispositivo legal que define e prevê a obrigatoriedade apresenta a seguinte redação:

(b) Tipos de apólices exigidas: Antes de qualquer contrato de US\$ 100.00 ou mais ser adjudicado para construção, alteração ou reparo de qualquer construção pública do Governo Federal, o contrato deve fornecer as seguintes garantias, que se tornam exequíveis após a adjudicação:

(1) Apólice de Garantia de Execução [*performance bond*] – uma apólice de garantia de execução com uma seguradora considerada satisfatória pelo contratante, e no valor considerado adequado à proteção do Estado;

[E BOND NOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS](#); Acesso em 27 de novembro de 2019.

²⁸⁸ XAVIER, Vitor Boaventura. **O Seguro Garantia de Execução do Contrato – Performance Bond: Uma Análise dos Aspectos Regulatórios e Concorrenciais da sua Exigência pela Administração Pública no Brasil**. Op. Cit. p. 27.

²⁸⁹ Nesse sentido: “Durante o período do *New Deal*, o governo federal norte-americano começou a ter dificuldades ao executar as apólices de *performance* atreladas às *payment bonds* nos grandes projetos de obras públicas” Idem.

²⁹⁰ Idem.

(12) Apólice de Garantia de Pagamento [*payment bond*] – uma apólice de garantia de pagamento com uma seguradora considerada satisfatória pelo contratante para a proteção de todos os trabalhadores e fornecedores envolvidos no contrato. O valor da Apólice de Garantia de Pagamento deve ser igual ao valor total pagável pelos termos do contrato, a menos que o ente adjudicante determine, de forma escrita e fundamentada, que uma apólice em tal valor seria impraticável, caso no qual este irá determinar o montante da apólice. O valor da Apólice de Garantia de Pagamento não pode ser inferior à Apólice de Garantia de Execução.²⁹¹

Ou seja, há a obrigatoriedade da emissão de um *performance bond* cobrindo 100% do contrato, para quaisquer tipos de serviços de construção ou reparos em prédios públicos quando a contratante for a Administração Federal Americana.²⁹²

“Todos os Estados americanos, e boa parte das prefeituras e condados”²⁹³, possuem normas no mesmo sentido do *Federal Miller Act Bonds*, sendo chamadas de *Little Miller Act Bonds*, prevendo, igualmente, a obrigatoriedade do uso de *performance bonds* com cobertura de 100% do contrato.²⁹⁴

Em estudo comparativo sobre o uso do seguro garantia em obras públicas, Francisco Galiza confrontou alguns ordenamentos que utilizam o *performance bond* em obras públicas²⁹⁵. Ao discorrer sobre o sistema americano, o autor listou algumas características gerais das exigências de seguros em diversos estados, elaborando uma tabela cujo conteúdo aqui se reproduz:

²⁹¹ Originalmente como: (b) Type of Bonds Required.— Before any contract of more than \$100,000 is awarded for the construction, alteration, or repair of any public building or public work of the Federal Government, a person must furnish to the Government the following bonds, which become binding when the contract is awarded: (1) Performance bond.— A performance bond with a surety satisfactory to the officer awarding the contract, and in an amount the officer considers adequate, for the protection of the Government. (2) Payment bond.— A payment bond with a surety satisfactory to the officer for the protection of all persons supplying labor and material in carrying out the work provided for in the contract for the use of each person. The amount of the payment bond shall equal the total amount payable by the terms of the contract unless the officer awarding the contract determines, in a writing supported by specific findings, that a payment bond in that amount is impractical, in which case the contracting officer shall set the amount of the payment bond. The amount of the payment bond shall not be less than the amount of the performance bond.” Estados Unidos da América. 40 United States Code. Title 40 > Subtitle II > Part A > Chapter 31 > Subchapter III > § 3131

²⁹² CARVALHOSA, Modesto. Performance Bonds: Quebra da Interlocução Direta entre Agentes Públicos e Privados na Execução de Contratos. In. **Infraestrutura: Eficiência e Ética**. Affonso Celso Pastore (org.). Editora Elsevier, Rio de Janeiro, 2017 [ebook; n.p.]..

²⁹³ Idem.

²⁹⁴ Idem.

²⁹⁵ GALIZA, Francisco. **Uma Análise Comparativa do Seguro Garantia de Obras Públicas**. Série Estudos sobre Seguros. Escola Nacional de Seguros. Rio de Janeiro. Novembro de 2015.

Tabela 3 - Características Gerais do *performance bond* pelos Estados Americanos²⁹⁶

<i>Peformance Bond</i> pelos Estados Americanos.	
Alabama	Mínimo de 50% do valor da obra, aplicável para obras cujo valor ultrapassa US\$ 50.000,00
Alaska ²⁹⁷	Para obras até US\$ 1.000.000,00, 40% do valor.
Arizona	100% do valor da obra, quando acima de US\$ 100.000,00
Arkansas	100% do valor da obra, quando acima de US\$ 20.000,00
Califórnia	100% do valor da obra, quando acima de US\$ 25.000,00
Colorado	100% do valor da obra, quando acima de US\$ 50.000,00
Connecticut	100% do valor da obra, quando acima de US\$ 100.000,00
Delaware	100% do valor da obra
Distrito de Columbia	No mínimo, 50% do valor da obra
Flórida	100% do valor da obra
Geórgia	100% do valor da obra
Havaí	100% do valor da obra
Idaho	No mínimo, 85% do valor da obra
Illinois	Dispensado para obras de baixo valor
Indiana	100% do valor da obra.
Iowa	Acima de 75% do valor da obra
Kansas	100% do valor da obra se acima de US\$ 100.000,00
Kentucky	100% do valor da obra
Louisiana	O percentual varia em função da dimensão da obra
Maine	100% do valor da obra
Maryland	50% do valor da obra
Massachusetts	No mínimo, 25% da obra
Michigan	100% do valor da obra, se acima de US\$ 50.000,00
Minnesota	100% do valor da obra
Mississippi	100% do valor da obra
Montana	100% em contratos estaduais; mínimo de 25% para contratos

²⁹⁶ Adaptada de: Idem, pp. 31-33.

²⁹⁷ Especificamente sobre a importância dos seguros na indústria de construção do Alasca recomenda-se: BARBOUR, Tracy. Contract Surety Bonds: Vital to Alaska's Construction Industry: Making sure project owners are safe. **Alaska Business Months**. February, 2011, pp. 52-55.

	municipais
Nebraska	100% do valor da obra
New Hampshire	100% do valor da obra, se acima de US\$ 35.000,00
New Jersey	100% do valor da obra
New Mexico	100% do valor, mas com a possibilidade de redução, pelo estado, para até 50%
New York	Dispensado para obras de valor inferior US\$ 50.000,00; sem percentual especificado
North Carolina	100% do valor da obra; dispensado em obras de valor inferior a US\$ 300.000,00
North Dakota	Cobertura total da mão de obra e material
Ohio	Cobertura total da mão de obra e material
Oklahoma	100% do valor da obra
Oregon	Dispensado para obras de valor inferior a US\$ 100.000,00
Pensilvânia	100% do valor da obra
Porto Rico	No mínimo, 25% do valor da obra
Rhode Island	Entre 50 e 100% do valor da obra
South Carolina	100% para estradas, 50% para os outros tipos de obra
South Dakota	Dispensado para obras de valor inferior a US\$ 25.000,00
Tennessee	No mínimo 25% do valor da obra
Texas	100% do valor da obra
Utah	100% do valor da obra
Vermont	Usado apenas para estradas
Virginia	Dispensado para obras de valor inferior a US\$ 350.000,00
Washington	100% do valor da obra. Em caso de obras de menor valor o percentual pode ser reduzido
West Virginia	Varia de acordo com o tipo de obra
Wisconsin	100% do valor da obra
Wyoming	25% do valor da obra; para obras de valor acima de US\$ 100.000,00, o percentual pode aumentar; quando o valor da obra for inferior a US\$ 7.500,00 pode ser dispensado

Embora, de fato, a tabela não forneça informações detalhadas sobre a aplicação do *performance bond* em cada estado da federação americana, ela fornece uma visão ampla do todo, e permite algumas conclusões.

A primeira delas é da boa aceitação do modelo pelos Estados Unidos. A obrigatoriedade do *performance bond*, originariamente limitada à Administração Federal, se espalhou por todos os Estados da Federação Americana. Importante notar que apesar da legislação depender de cada estado, “de um modo geral, segue um padrão lógico”²⁹⁸, revelando certa uniformidade na utilização do instituto.

Verifica-se, ainda, algumas variações em relação aos percentuais de cobertura obrigatória em dois sentidos: (i) diferentes estados eventualmente adotam percentuais diferentes, variando entre 25 e 100% o valor da obra, embora a grande maioria exija ao menos 50% de cobertura; (ii) de acordo com o valor da obra, os percentuais podem ser diferentes, sendo possível até mesmo a dispensa da garantia para obras de baixo valor.

O modelo, segundo estudos de Modesto Carvalhosa, foi exitoso nos EUA, que afirma:

A experiência americana com os performance bonds demonstra os benefícios práticos desse regime de garantias. As seguradoras elaboram criteriosa avaliação de subscrição de apólice com base em três elementos fundamentais: a obrigatoriedade da contratação de apólice de performance em todos os contratados de obras públicas; a importância assegurada em 100% do valor do contrato; e a atribuição de poder de fiscalização permanente à seguradora, tanto no canteiro de obras como na auditoria permanente da execução econômico-financeira do contrato.²⁹⁹

Vitor Boaventura Xavier reconhece que é possível encontrar, na literatura americana, algum descontentamento em relação ao *Miller Act*, mas a longevidade da norma seria um indicativo de como ela conseguiu representar um equilíbrio entre diversos interesses conflitantes.³⁰⁰ Portanto, o exemplo a ser tomado aos legisladores brasileiros é de conseguir uma norma que seja funcional em nosso sistema, mesmo que com algumas imperfeições.

²⁹⁸ GALIZA, Francisco. **Uma Análise Comparativa do Seguro Garantia de Obras Públicas**. Op. Cit., p. 34.

²⁹⁹ CARVALHOSA, Modesto. Performance Bonds: Quebra da Interlocução Direta entre Agentes Públicos e Privados na Execução de Contratos Administrativos. Op. Cit. [n.p.]

³⁰⁰ XAVIER, Vitor Boaventura. **O Seguro Garantia de Execução do Contrato – Performance Bond: Uma Análise dos Aspectos Regulatórios e Concorrenciais da sua Exigência pela Administração Pública no Brasil**. Op. Cit. p. 69.

4.2. Institutos Semelhantes Aplicáveis em Obras Públicas.

Neste tópico serão abordados institutos jurídicos, já existentes no Brasil, que podem funcionar sobre os incentivos de forma semelhante ao *performance bond* como fonte de bons incentivos. Escolheu-se a responsabilidade ambiental dos financiadores de projetos potencialmente causadores de dano ambiental e os acordos trilaterais da ARTESP. Nos dois casos ocorre a formação de uma relação trilateral na qual um dos polos é o Estado, dinâmica semelhante ao do *performance bond*.

4.2.1. Responsabilidade Ambiental do Financiador de Projetos.

A semelhança com o *performance bond* reside na estrutura da relação, que também acaba sendo trilateral. Tem-se, assim, os seguintes personagens: (i) a vítima do dano ambiental a ser reparada³⁰¹; (ii) o causador do dano; (iii) o financiador da atividade responsável pelo dano.

Não há uma relação direta entre o financiador com os afetados pela atividade do causador do dano. Todavia, aquele acaba responsabilizado por ato de terceiro com quem tem uma relação econômica.

A peculiaridade é que o banco não é o poluidor, o causador direto do dano ambiental, mas por ele se responsabiliza, considera-se a instituição financeira responsável pela capitalização do projeto como poluidora indireta³⁰², capaz de influenciar na prevenção à ocorrência do dano ambiental. De forma semelhante, no

³⁰¹ Como foge ao escopo da presente dissertação discussões sobre direito ambiental, para fins de simplificação, considera-se todos os possíveis vitimados por um dano ambiental, como um dos lados da relação. Naturalmente, não se ignora a natureza complexa dos danos ambientais, uma vez que o Direito ao Meio Ambiente Equilibrado é um direito difuso, não possuindo um titular definido.

³⁰² Nesse sentido: “A primeira questão consiste na distinção da natureza e campo de ação dos poluidores diretos em relação aos poluidores indiretos. Neste sentido, qualquer conduta que tenha sido realizada por um poluidor indireto, diferentemente do que ocorre com o poluidor direto, não irão concorrer de forma direta e imediata para o dano ambiental, ou seja, não é uma ação ou omissão do poluidor indireto que pode dar causa ao dano como consequência intrínseca do ato. O que ocorre é que os atos comissivos ou omissões do poluidor indireto podem contribuir para a futura ocorrência do dano ambiental, que será, portanto, consequência imediata do poluidor direto. (...), como poluidor indireto, a instituição financeira somente poderá ser responsabilizada quando presente o nexo de causalidade entre sua conduta omissa – o que se traduz na falta de observância dos aspectos legais e regulatórios exigidos para a concessão de financiamento – e o dano causado ao meio ambiente. Para o autor, não há como determinar que a instituição financeira fiscalizasse *in loco* o empreendimento ou a atividade por ela financiada, já que este é poder indelegável pertencente ao ente estatal fiscalizatório.” CHAVES, Vinicius Figueiredo; SUMAR, Cristina Carvalho. A Responsabilidade Civil Ambiental das Instituições Financeiras. **Revista Estação Científica** – Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora. Edição Especial VII Seminário de Pesquisa da Estácio e III Jornada de Científica da UNESA 2º semestre – 2015. Disponível em: https://portal.estacio.br/media/4622/a_responsabilidade_civil_ambiental_das_instituico%C2%B5es_financeiras.pdf Acesso em 23 de novembro de 2019. pp. 15-16.

performance bond a seguradora não é a contratada da Administração, mas se responsabiliza pelo adimplemento do contrato do terceiro, o tomador do seguro.

Do ponto de vista positivo, essa responsabilidade se fundamenta, essencialmente, no art. 12 da Lei n.º 6.803/1980 e no art. 14 da Lei n.º 6938/1981³⁰³.

O objetivo da norma é trazer para a análise de risco de crédito a análise de risco ambiental³⁰⁴. O risco de ser responsabilizado, na qualidade de poluído indireto, serviria para as instituições financeiras se comprometessem apenas com empreendedores nos quais confiavam em relação à política de prevenção de danos ambientais.

Ao integralizar o risco ambiental ao risco de crédito, o objetivo do legislador foi tornar o particular financiador do projeto em um auxiliar na fiscalização ambiental, uma vez que a instituição financeira também poderia se ver obrigada a suportar a responsabilidade pelos danos ambientais de seu financiado.³⁰⁵ Com isso, o particular selecionará como financiado apenas os agentes do mercado com as melhores políticas ambientais.

³⁰³ Muito embora também se encontre esse tipo de responsabilidade no art. 78-A do Código Florestal; Art. 2º, §4º da Lei n.º 11.105/2005.

³⁰⁴ Pode-se entender risco ambiental como “... uma medida de possíveis danos que uma atividade econômica pode causar ao meio ambiente. A correspondência entre o risco ambiental e demais enfrentados pelas empresas está fundamentada no princípio do poluidor-pagador. Por esse princípio se busca internalizar os custos da degradação ambiental no processo produtivo de qualquer atividade econômica, de modo a evitar que apenas os lucros de uma atividade sejam privatizados e os custos do dano ambiental sejam socializados. Assim, o risco ambiental passa a ser traduzido como custo financeiro.” BLANK, Dionis Mauri Penning; BRAUNER, Maria Claudia Crespo. A Responsabilidade Civil Ambiental das Instituições Bancárias pelo Risco Ambiental Produzido por Empresas Financiadas. **Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, v. 22, janeiro a julho de 2009. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/remea/article/view/2827/1597> Acesso em 23 de novembro de 2019. pp. 265.

³⁰⁵ Nesse sentido: “A existência de risco ambiental deve se unir ao risco de crédito da empresa e elevar seus custos financeiros, implicando na diminuição das receitas dos acionistas que, por isso, deverão levar seus investimentos ou ações para outras empresas livres de riscos ambientais. Ademais, os financiadores devem centralizar suas preocupações na responsabilidade ambiental das empresas financiadas, já que, mesmo diante de eventual penalidade ou indenização que se limite à empresa responsável direta ou indiretamente pelo dano, sem atingir os financiadores, esses serão atingidos pelo risco de crédito, caso não seja avaliado previamente o risco ambiental na contratação dos financiamentos. Isso acontece, pois a ocorrência de danos ambientais, quando não previstos na contratação dos financiamentos implica na reclassificação daqueles créditos para o elenco de ativos do banco com valorização, em vista das dificuldades de seu recebimento. Dessa maneira, é importante a prévia análise dos riscos e dos passivos ambientais antes da contratação de financiamentos, para evitar a expectativa da realização de receitas sobre determinadas transações que, depois, podem ser reclassificadas como duvidosas em função da dificuldade de adimplemento. Por sua vez, quando os financiamentos são contratados com empresas que cumprem adequadamente as normas ambientais, o financiador terá a tranquilidade de manter registrados seus ativos financeiros na melhor classificação de crédito, pois contratados com empresas que tiram proveito da sua adequação às normas legais e reduzirem os desperdícios ou reaproveitá-los para fabricação de novos produtos.” Ibidem, p. 266.

O instituto ainda é envolto por diversas questões na literatura especializada, especialmente quanto aos requisitos para se considerar a omissão de fiscalização do agente financiador como suficientes para configurar sua responsabilização³⁰⁶, bem como qual a teoria da Responsabilidade Civil mais adequada ao instituto³⁰⁷, questões que fogem ao escopo do presente estudo.

Porém, no momento importa apenas compreender o propósito da norma. Como foi destacado em parágrafo anterior, o objetivo desse instituto é criar um incentivo, por meio da responsabilização, para as instituições financeiras agirem como fiscais das práticas ambientais de seus financiados, somando-se ao Estado nos esforços para proteção do meio ambiente. Tal papel pode ser desempenhado a partir de uma série de medidas, a maioria de cunho fiscalizatório, as quais determinam o acompanhamento do projeto financiado, potencialmente causador de dano ambiental, bem como de outros fatores do agente econômico capazes de indicar a sua idoneidade em matéria ambiental.³⁰⁸

³⁰⁶ CHAVES, Vinicius Figueiredo; SUMAR, Cristina Carvalho. A Responsabilidade Civil Ambiental das Instituições Financeiras. Op. Cit., pp. 15-18

³⁰⁷ Luciane Moessa de Souza indica três visões principais: “(a) a que além de entender ser a responsabilidade do financiador também objetiva, adota a teoria do risco integral e não aceita a possibilidade de incidência de caso fortuito e força maior como excludente de responsabilidade (...) (b) a que admite ser a responsabilidade do financiador também objetiva, porém admitindo-se algumas excludentes de ilicitude (e afastando, portanto, a teoria do risco integral). (...) (c) a que, em tese, admite ser a responsabilidade do financiador também objetiva, porém, admite plena incidência das excludentes de responsabilidade e, além disso, entende que deve haver violação de um dever, adotando a teoria do risco criado” SOUZA, Luciane Moessa de, Responsabilidade Civil de Instituições Financeiras por Danos Socioambientais. **Veredas do Direito**, v. 15, n.º 32. Belo Horizonte, maio/agosto de 2018, pp. 357-396, disponível em: <http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/1302>; Acesso em 24 de novembro de 2019; p.363.

³⁰⁸ Nesse sentido, Luciane Moessa de Souza exemplifica diversas atividades a serem adotadas pelos bancos, a depender do tipo de atividade econômica viabilizada pelo financiamento: “ (A) verificação do licenciamento ambiental, seja on-line, seja mediante solicitação de certidão... (b) avaliação de impactos ambientais...; (c) verificação da regularidade ambiental no que diz respeito à reserva legal e às áreas de preservação permanente da propriedade rural.... (d) verificação junto aos órgãos ambientais da eventual sobreposição com áreas ambientalmente protegidas (unidades de conservação)...; (e) verificação junto à FUNAI de eventual sobreposição com áreas indígenas...; (f) verificação junto ao INCRA de eventual sobreposição com territórios de comunidades quilombolas...; (g) monitoramento remoto (utilizando o Google Earth ou ferramentas similares)...; (h) verificação da regularidade da outorga de direito de uso de recursos hídricos...; (i) verificação do enquadramento da atividade financiada no Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE)...; (j) verificação de existência de restrições ao uso da propriedade...; (l) verificação on-line ou solicitação de certidão ao Ministério do Trabalho quanto à existência, objeto e andamento de processos administrativos em matéria de saúde e segurança do trabalho...; (m) solicitação de certidões da Justiça do Trabalho, quanto ao número e objeto das ações envolvendo o empreendimento...; (n) verificação das ações judiciais envolvendo o empreendimento na Justiça Estadual e Federal, com foco e ações referentes a matéria ambiental ou envolvendo outros direitos coletivos...; (o) verificação junto ao Ministério Público Federal de inquéritos civis, ações civis públicas e termos de ajuste de conduta (TACs) envolvendo o empreendimento...; (p) verificação junto ao Ministério Público Estadual de inquéritos civis, ações civis públicas e termos de ajuste de conduta (TACs) envolvendo o empreendimento...; (q) verificação junto

Espera-se, com isso, transformar os bancos em “fiscais indiretos do cumprimento da lei e verdadeiros agentes de divulgação da legislação e das boas práticas de proteção ao meio ambiente”³⁰⁹.

A responsabilidade ambiental do financiador de projetos permite ser uma referência sobre como um terceiro pode agir como fiscal de um contrato. Nesse sentido, espera-se que a seguradora atue de forma semelhante ao financiador do projeto ambiental, garantindo a atuação adequada do agente contratado, a partir da fiscalização tanto da execução específica do objeto contratual, quanto de outros elementos capazes de indicar a (in)capacidade do particular em terminar projetos a seu cargo.

Em relação à responsabilidade ambiental do financiador, Luciane Moessa de Souza ressalta a necessidade de um quadro regulatório claro, “para dar segurança e parâmetros que fortalecessem tais sistemas nas instituições financeiras e investidores em geral”³¹⁰.

De maneira semelhante, é possível inferir a mesma necessidade no caso do *performance bond*. A regulamentação da sua emissão, bem como os procedimentos para quando sua execução for necessária devem, com a sua expansão, objeto de maiores cuidados, tanto dos legisladores, quanto dos reguladores (SUSEP), responsáveis pela construção do seu arcabouço normativo.

4.2.2. Acordos Trilaterais da ARTESP.

Recentemente, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), incluiu em contrato de concessão a possibilidade dos financiadores encamparem as

ao Ministério Público do Trabalho de informações sobre Termos de Ajustes de Contas (TACs) firmados em inquéritos civis ou ações civis públicas (ACPs)...; (r) *inspeções mediante comparecimento de especialistas junto ao local das atividades financiadas...*; (s) *pesquisa de mídia envolvendo o empreendimento e/ou o projeto financiado, bem como diálogo com instituições do terceiro setor...*; (t) *contratação de auditoria socioambiental independente...*; (u) *avaliação ambiental de garantias imobiliárias...*; (v) *solicitação de plano de ação para mitigar riscos socioambientais...*; (w) *existência de certificação(ões) por entidade(s) reconhecida(s) quanto à adequação dos sistemas de gestão ambiental e de gestão de saúde e segurança do trabalho...*; (x) *verificação das informações constantes dos relatórios de sustentabilidade/responsabilidade social corporativa...*; (y) *verificação da inclusão (ou não) em índices de sustentabilidade de Bolsas de valores*” (grifos da autora) Ibidem, pp. 371-374

³⁰⁹ BLANK, Dionis Mauri Penning; BRAUNER, Maria Cláudia Crespo. A Responsabilidade Civil Ambiental das Instituições Bancárias pelo Risco Ambiental Produzido por Empresas Financiadas. Op. Cit. p. 268.

³¹⁰ SOUZA, Luciane Moessa de, Responsabilidade Civil de Instituições Financeiras por Danos Socioambientais. Op. Cit., p. 392.

concessões rodoviárias como forma de recuperarem os empréstimos realizados para concretização do empreendimento. Nesse caso, há uma referência sobre como pode ser realizado o *step-in* contratual, no bojo de um típico Contrato Administrativo (Contrato de Concessão) por um terceiro.

Como tal tipo de contrato foi firmado apenas em 2017, e é aplicável apenas para dois lotes contratuais (Via Paulista³¹¹ e Entrevias³¹²) há pouca produção bibliográfica sobre o tema³¹³, nem houve aplicado da cláusula de encampação, de forma que aqui se caminha sobre um campo de incertezas e inferências. Não obstante, compreender a dinâmica de tal contrato, bem como conhecer as cláusulas reguladoras desse aspecto, permite visualizar algumas possibilidades aplicáveis ao *performance bond*, pois, em ambos os casos, forma-se uma relação trilateralizada (tripartite).

O contrato tripartite apresenta seu objeto contratual em sua cláusula primeira nos seguintes termos:

Constitui objeto deste Acordo os direitos e deveres conferidos às Partes por ocasião da ocorrência de um Evento de Alerta, conforme disciplina aqui contida, assim como o estabelecimento dos termos e condições em que, nessa hipótese, se darão a cessão da Concessão, a transferência do controle societário da Concessionária, a assunção do controle e a administração temporária da Concessionária, conforme disposições dos artigos 27 e 27-A da Lei n 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Um dos conceitos fundamentais para este acordo é o de evento de alerta. Trata-se de um rol de eventos previstos na cláusula oitava³¹⁴ (os quais incluem

³¹¹ Rodovia dos Calçados, operada pela ARTERIS. Contrato de Concessão e Anexos, entre os quais o contrato Tripartite, disponíveis em: <http://www.artesp.sp.gov.br/Style%20Library/extranet/rodovias/rodovia-interna.aspx?id=23>; Acesso em 03 de dezembro de 2019.

³¹² Inclui as rodovias do Centro-Oeste Paulista. Operado pela Entrevias. Contrato de Concessão e Anexos, entre os quais o contrato Tripartite: disponíveis em: <http://www.artesp.sp.gov.br/Style%20Library/extranet/rodovias/rodovia-interna.aspx?id=4>; Acesso em 03 de dezembro de 2019.

³¹³ Destaca-se o artigo de: JORDÃO, Tarcila Reis. Acordo Tripartite: Enfrentando os desafios de financiabilidade de projetos de concessão e Parcerias Público-Privadas no Brasil. In: **Direito, Instituições e Políticas Públicas. O papel do jusidealista na formação do Estado.** (Coord.) Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho; André Tito da Motta Oliveira; Rafael Hanze Issa. Rafael Wallbach Schwind. Editora Quartier Latin do Brasil. São Paulo, 2017. pp. 403- 428.

³¹⁴ 8.1. São Eventos de Alerta: a) o descumprimento de qualquer obrigação ou conjunto de obrigações do Contrato de Concessão que, como consequência, possa dar ensejo à execução das garantias prestadas pela Concessionária no âmbito do Contrato de Concessão, desde que reste configurada pelo menos uma das hipóteses a seguir listadas: i. represente(m), em conjunto ou isoladamente, conduta(s) infratora(s) sujeita(s) a multa(s) em montante igual ou superior a R\$ [--]; ii. represente(m) mais de [--] notificações

descumprimento de obrigações do contrato de concessão; multas e notificações a partir de determinado quantitativo; faltas relativas às obrigações financeiras contraídas pela concessionária) cuja ocorrência pode desencadear uma série de consequências previstas na cláusula nona³¹⁵, mais especificamente 9.5, entre as quais a possibilidade de o Agente Fiduciário³¹⁶, o qual representa a comunhão dos financiadores, assumir temporariamente a concessão, assumir o controle societário da concessionária e até mesmo optar pelo direito de ter cedido para si os direitos decorrentes do contrato de concessão.

Percebe-se que o foco do acordo tripartite, nesse caso, é a proteção dos interesses dos financiadores do projeto. Não obstante, como há, ainda, a previsão de aplicação da cláusula 9.5, em caso de inadimplemento do contrato no próprio contrato de concessão, não apenas na relação entre o concessionário e seus financiadores, estes acabam adquirindo, mesmo que por motivos diferentes dos verificados no *performance bond*, o papel de fiscalizadores do contrato. Conforme outras cláusulas do contrato tripartite determinam³¹⁷, a concessionária deve fornecer materialmente documentos para a troca de informações entre as partes.

Um ponto relevante sobre tais acordos é como eles preveem e organizam o procedimento de notificação dos eventos bem como prevê a possibilidade de um

emitidas com penalidade cominadas em níveis E e F na tabela de multas prevista no Anexo 11 - DAS PENALIDADES; iii. esteja em mora quanto ao pagamento de multas aplicadas e/ou valores devidos à ARTESP e/ou Poder Concedente. b) a instauração de processo administrativo para declaração da caducidade da Concessão; c) a instauração de processo administrativo para decretação de intervenção na Concessão; d) o descumprimento, pela Concessionária, das obrigações financeiras contraídas com os Credores ou de outras obrigações, que possam resultar na aceleração do pagamento da dívida ou no vencimento antecipado de suas dívidas, conforme previsões dos Documentos de Financiamento.

³¹⁵ 9.5. Caso a Concessionária não tenha sanado todos os inadimplementos identificados no Evento de Alerta dentro dos respectivos Períodos de Cura, será facultado ao Agente Fiduciário, representando os Credores, adotar uma das seguintes medidas: a) adimplir em seu próprio nome as obrigações pelas quais a Concessionária estiver em mora frente ao Poder Concedente ou à ARTESP; b) assumir temporariamente a administração da Concessionária para promover sua reestruturação financeira e, posteriormente, retornar à Concessionária a execução das atividades associadas ao Contrato de Concessão ("**Administração Temporária**"); c) assumir, caso detenha a propriedade resolúvel das ações, o controle societário da Concessionária nos termos do artigo 27-A da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 ("Lei 8.987/95") para promover a reestruturação financeira da Concessionária e assegurar a prestação dos serviços ("**Assunção de Controle**"); d) exercer sua opção para transferência dos direitos da Concessionária decorrentes do Contrato de Concessão a terceiro(s) que vier a indicar, nas hipóteses previstas na Cláusula 14 abaixo, ("**Transferência da Concessão**"); e) exercer suas prerrogativas previstas nos Documentos do Financiamento, inclusive o vencimento antecipado da dívida ou a execução de garantias ofertadas pela Concessionária.

³¹⁶ Assim definido na Cláusula segunda do acordo tripartite: Agente Fiduciário: representante da comunhão dos financiadores, incluindo os garantidores da operação, perante a ARTESP e o Poder Concedente, especificado no preâmbulo, a quem cabe o exercício dos direitos e obrigações que lhe são conferidos neste Acordo.

³¹⁷ Especialmente na cláusula sétima, a qual determina a troca de informações entre as partes.

período de cura³¹⁸, no qual a concessionária poderá regularizar a pendência motivadora da notificação.

A celebração de tais acordos no bojo das referidas concessões é defendido por Tarcila Reis Jordão com base em dois argumentos:

O primeiro argumento da necessidade de disponibilizar o acordo tripartite é o fato de sua assinatura implicar aprovação prévia pelo Poder Concedente do exercício dos direitos do Financiador. Esta aprovação prévia do Poder Concedente é relevante porque (a) confere mais segurança ao Financiador a respeito da efetividade dos seus direitos e (b) desburocratiza o procedimento que tradicionalmente condicionaria o exercício desses direitos. Significa que, nas hipóteses definidas no acordo tripartite, o Financiador goza da possibilidade de simplesmente acionar o rol dos seus direitos, sem mais depender de um juízo discricionário do Poder Concedente. De partida (com a assinatura do Acordo Tripartite), o Poder Concedente já terá aprovado as hipóteses que permitem o exercício dos direitos do Financiador. Nestas hipóteses, o Financiador deliberadamente decidirá se vai lançar mão do rol dos seus direitos. (...)

O acordo tripartite continuaria necessário na medida em que é ele que veicula a exequibilidade (*enforcement*) dos direitos e deveres por parte do Financiador em relação ao Poder Concedente. Trata-se do segundo argumento sobre a necessidade do acordo tripartite: é o acordo tripartite que permite que o financiador cobre do Poder Concedente a garantia do exercício dos seus direitos nas hipóteses definidas contratualmente. Sem o acordo tripartite, o Financiador não possui relação jurídica com o Poder Concedente e depende da intermediação do Concessionário para obter tais aprovações.

Mais, sem acordo tripartite, a despeito do flagrante “*alinhamento de interesses*” entre o Poder Concedente e o Financiador, estes não dialogam e não têm direitos e obrigações recíprocas. Não haveria, por exemplo, como exigir o dever de notificações recíprocas para deflagrar Períodos de Cura e de Exercício. Não haveria tampouco como o Financiador exigir diretamente ao Poder Concedente a garantia destes direitos. Em última análise, o alinhamento de interesses entre Poder Concedente e Financiador continuaria a depender do Concessionário, cujo interesse está normalmente em pólo oposto.³¹⁹

Com isso, os acordos tripartites cumprem a função de oferecer maior segurança aos financiadores, os quais poderão executar suas garantias de forma mais facilitada.

³¹⁸ Conforme previsão na Cláusula segunda: **Período de Cura:** prazo de 30 dias concedido pela ARTESP ou pelo Agente Fiduciário, conforme o caso, mediante notificação a Concessionária, para que sejam sanados descumprimentos observados neste Contrato, no Contrato de Concessão ou nos Documentos do Financiamento, conforme previsto na cláusula 9.4 abaixo. O prazo de 30 (trinta) dias não será aplicado caso haja previsão expressa no Contrato de Concessão, ou nos Documentos do Financiamento, de outro prazo para sanar Eventos de Alerta específicos, hipótese em que o Período de Cura será o mesmo prazo estabelecido no Contrato de Concessão, ou nos Documentos do Financiamento, conforme o caso.

³¹⁹ JORDÃO, Tarcila Reis. Acordo Tripartite: Enfrentando os desafios de financiabilidade de projetos de concessão e Parcerias Público-Privadas no Brasil. Op. Cit. pp. 405-409.

Para tanto, eles instrumentalizam a ligação entre o financiador e o poder concedente, de forma que tal relação não fica mais dependente do concessionário. Com isso, há um melhor alinhamento entre os interesses do financiador e do poder concedente, uma vez que a ligação entre eles é estreitada e, de certa maneira, deixa de ficar subordinada à relação entre poder público e concessionário.

As cláusulas de tais acordos tripartites, anexos aos recentes contratos de concessão da ARTESP, podem servir como um modelo para a instrumentalização do *performance bond*. Isto porque, apesar dos objetivos diferentes, enquanto o primeiro busca a proteção dos agentes financiadores da infraestrutura rodoviária, e o segundo é uma forma de garantir o adimplemento contratual em favor da Administração Pública, nos dois casos, ocorre a triangulação da relação jurídica entre Estado e Contratado, a partir da inserção de um particular, terceiro interessado no bom andamento contratual.

Não apenas isso, nos dois casos é possível a migração do terceiro interessado para a de executor do contrato. No caso do *performance bond* a seguradora pode assumir a concretização da obra, enquanto no acordo tripartite, o agente fiduciário pode encampar a concessão, de forma provisória ou até mesmo permanentemente, e, nas duas situações, em decorrência de alguma conduta falha, seja na execução contratual seja no cumprimento de obrigações financeiras, do contratado (tomador do seguro ou do financiamento)

Dessa maneira, o acordo tripartite é um instrumento que guarda características em comum com o seguro garantia de execução de obrigação, portanto a observância do desenvolvimento do primeiro é capaz de oferecer alguma orientação para a aplicação, no Brasil, do segundo.

4.3. Benefícios Esperados pela ampliação do *Performance Bond*.

No capítulo inicial, indicou-se como, hoje, funciona o sistema de contratações de obras públicas. O diagnóstico apresentado foi de um percentual muito elevado de obras inacabadas, atrasos consideráveis nas entregues e, ainda, a detecção de constante sobrepreço e frequentes irregularidades (como jogos de planilha).

Parte considerável dessas adversidades decorre de um desenho institucional inadequado. Preocupação excessiva com o procedimento e resultados colocados em segundo plano, principalmente na Lei Geral de Licitações.

Abaixo, serão apresentados efeitos esperados da utilização mais efetiva do Seguro Garantia, na modalidade *performance bond*, sobre a celebração e execução de contratos administrativos.

4.3.1. Quanto ao Incentivo à Conclusão de Obras Públicas por meio da Cooperação entre as Partes.

O instituto do seguro garantia tem o potencial de realinhar os incentivos das partes contratuais. Isso porque “cada uma das partes interessadas dispõe de incentivos suficientes para dirigir sua ação no sentido de adimplir as obrigações avençadas”³²⁰.

A seguradora tem o interesse na boa execução do contrato, pois em caso de inadimplemento, ela terá ou de assumir a obra ou de indenizar o beneficiário. Com isso, a fiscalização realizada, seja diretamente pela própria seguradora ou mediante a contratação de sociedades empresárias especializadas, será efetiva e dotada de *expertise* técnica maior.³²¹

Embora seja possível se ressarcir com seu segurado, este não é o melhor cenário para a seguradora, pois o próprio inadimplemento do tomador pode indicar uma má fase empresarial, vivenciando dificuldade de honrar seus compromissos, o que torna o reembolso da execução da apólice, no mínimo incerto.³²² Com isso, na

³²⁰ XAVIER, Vitor Boaventura. **O Seguro Garantia de Execução do Contrato – Performance Bond: Uma Análise dos Aspectos Regulatórios e Concorrenciais da sua Exigência pela Administração Pública no Brasil.** Op. Cit. p. 22.

³²¹ Sobre a fiscalização da seguradoras: “Após a subscrição da apólice e o início da execução contratual, as seguradoras acompanham as atividades mantendo constante vigilância. Nos Estados Unidos, as seguradoras têm competência para auditar e livremente fiscalizar o local de realização das obras e/ou prestação dos serviços. A competência para fiscalizar pode ser delegada a um terceiro especializado e selecionado pela própria seguradora. As *Surety Consulting Firms* são as empresas contratadas pelas seguradoras para fiscalizar a execução do contrato objeto de garantia. Essas empresas dispõem de corpo técnico especializado na atividade de acompanhamento e fiscalização de obras. Além disso, as empresas de auditoria especializada prestam uma função-chave na verificação do sinistro, pois a investigação das causas do sinistro e mensuração da sua importância devida a título de indenização. Esta atividade, que é de competência da seguradora pode ser delegada por ela às empresas de auditoria especializada.” Ibidem, p. 21.

³²² Sobre a vantagem para o beneficiário e os incentivos da seguradora: “A subscrição da *performance bond* traz vantagens consideráveis ao beneficiário, principalmente quando este for a Administração Pública, pois a seguradora verifica com maior *expertise* os riscos envolvidos na realização daquele projeto, prioritário ao interesse público. A seguradora dispõe de incentivo suficiente para assim agir pois, na relação contratual da apólice de *performance*, o tomador fica obrigado através de garantias ou contragarantias (*indemnity agreements*) exigidas pela seguradora a título de ressarcimento pelo eventual sinistro do tomador.” Ibidem, p. 18.

qualidade de garante, a seguradora terá incentivos para manter uma fiscalização ativa da execução contratual.³²³

Por outro lado, o tomador do serviço sabe que o inadimplemento, e a consequente execução da apólice, pode significar a impossibilidade de adquirir novo seguro e, portanto, de contratar com o Poder Público, ou até mesmo com um particular mais rigoroso quanto à prestação de garantias.

Já a Administração Pública possui o incentivo de seguir à risca o cronograma de desembolso e de transferência de recursos para os particulares, pois o comportamento em desacordo com as obrigações contratuais inicialmente avençadas pode ser interpretada como um aumento de risco incompatível com a garantia, ensejando a perda da sua cobertura³²⁴. Por exemplo, um atraso nos repasses de verbas para a realização do projeto, não entrega do sítio de obras no tempo programado, fatos capazes de dificultar a execução pelo seu contratado, podem ser utilizados pela seguradora como argumentos para negativa da cobertura do sinistro.³²⁵

Na realidade, até mesmo o tomador do seguro pode se beneficiar da utilização do *performance bond* como modalidade de garantia. Diferentemente da fiança bancária que costuma vir acompanhada de maiores exigências do ponto de vista financeiro, especialmente de contragarantias, e com isso acaba imobilizando ativos da empresa, o seguro garantia, a seu turno, é mais flexível em matéria de demandas financeiras e não demanda o mesmo nível e imobilização patrimonial do tomador. Portanto, há um menor comprometimento dos ativos do contratado, o que, inclusive, pode facilitar a execução contratual.³²⁶

³²³No mesmo sentido: “Nesse sistema, a seguradora torna-se terceira interessada na regular execução daquele contrato objeto de garantia e age com toda diligência para mitigar a eventual deflagração do sinistro (*default*).” Ibidem, p. 22.

³²⁴Sobre os atrasos de responsabilidade da Administração: “... as alterações no prazo, quando não são de responsabilidade do Empreiteiro, ocorrem geralmente devido a diversos problemas, dentre eles é possível citar: paralisação das obras devido à falta de orçamento público, alterações no projeto de execução, aumento de quantitativos inicialmente acertados nos contratos, atrasos nos repasses de valor para as empreiteiras, além de atrasos decorrentes de determinação judicial ou órgãos de controle.”. SILVA, Marcos José da. **Economia das Licitações, a Contratação de Obras e Reformas em Prédios Públicos: O caso da UFRGS**. Op. Cit. p. 62.

³²⁵Corroborando nossa afirmação: “O incentivo para o Estado, porém, surge do fato de que caso incorra em alguma falha contratual (por exemplo, um atraso nos pagamentos), concederá à seguradora um argumento de defesa que poderá livrá-la da obrigação de garantir a *performance* da empreiteira. É dizer, portanto, que o seguro-garantia institui um sistema de incentivos que não se resume ao melhor monitoramento da empreiteira pela seguradora, mas também das obrigações contratuais devidas pelo próprio Estado”. GOMES, Francisco Yokota Choucair. **Análise Econômica do Performance Bond nos Contratos de Obras Públicas**. Op. Cit. p. 28.

³²⁶Sobre esse aspecto: “Ele tem como objetivo liberar os ativos empresariais para que, com eles, o empresário possa fazer frente aos movimentos de rotina empresarial, atuando no mercado financeiro,

Dessa maneira, é possível enxergar um sistema de incentivos recíprocos a partir da utilização do *performance bond*.³²⁷ Isto é, todas as partes, em alguma medida, passam a convergir para uma melhor execução contratual, apoiando-se mutuamente na execução de suas obrigações. Na medida em que se pode entender contratos de obras como contratos relacionais (*relational contracts*)³²⁸, nos quais as partes se comprometem em um projeto de longo prazo, quão maior for a cooperação entre elas, melhor irá se desenvolver a execução contratual para todos.³²⁹

Nesse passo, a inclusão de um *performance bond*, embora, de fato, possa encarecer o momento inicial da contratação, como destacou-se em tópico anterior, é capaz de garantir a efetiva conclusão da obra e entrega da utilidade pública prometida, bem como pode até mesmo ensejar uma economia na execução do contrato e ser um fator que favoreça a manutenção dos seus custos dentro do orçamento inicialmente programado.³³⁰ Sintetizando o argumento:

..., podemos concluir que a contratação de uma obra com seguro-garantia será vantajosa se os ganhos de eficiência gerados pela transferência parcial dos custos de monitoramento e riscos do Estado para a seguradora superar os custos de transação que surgem em manter uma relação trilateral, ao invés de uma relação bilateral.

deixando a capacidade garantida pelo segurador pelo segurado para ser utilizada em algum negócio estratégico (...) O seguro garantia de cumprimento de obrigações é largamente utilizado com relação a obrigações de prestar serviços, entregar produtos, construir e entregar obras etc. Portanto, em especial em financiamentos de projetos, cujo pagamento depende da finalização da obra ou fornecimento de produto, aparecendo como eficaz instrumento na diminuição de risco, e, ainda, na estruturação e redução do custo de operações financeiras.” BURANELLO, Renato Macedo. **Do Contrato de Seguro: O seguro garantia de obrigações contratuais**. Op. Cit., pp.172-173

³²⁷ Sobre o sistema de incentivos recíprocos: “..., identificou-se que as *performance bonds* incentiva a execução regular dos contratos administrativos pois estruturam um Sistema de Incentivos Recíprocos (SIR) que atuam no sentido da execução contratual, com o adimplemento das obrigações assumidas pelas partes. Em detrimento da atual realidade, marcada pelo atraso na execução, pelo emprego de materiais de qualidade inferior à contratada, sobrepreço e cometimento de atos de corrupção, as *performance bonds* são uma alternativa de diminuição dos riscos de inadimplemento pelo contratado.” XAVIER, Vitor Boaventura. **O Seguro Garantia de Execução do Contrato – Performance Bond: Uma Análise dos Aspectos Regulatórios e Concorrenciais da sua Exigência pela Administração Pública no Brasil**. Op. Cit. p. 66.

³²⁸ Conceitua-se contratos relacionais da seguinte maneira: “There are situations in which parties want to commit themselves to a long-term cooperation framework because even though it is not fully specified, it seems to offer them advantages over a series of successive contracts. (...) A relational contract is considered to be opposite of an instantaneously performed contract. It is said to distinguish itself by the personal relationship between the parties over and beyond their economic relationship”. MACKAAY, Ejan. **Law and Economics for Civil Law Systems**. Op. Cit., p. 466.

³²⁹ Sobre o tema dos cotratos relacionais recomenda-se: MACEDO Jr., Ronaldo Porto. **Contratos Relacionais e Defesa do Consumidor**. 2ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 2007.

³³⁰ Sobre alocação de custos dos riscos: “... it is worthwhile preventing mishaps where this can be done at a cost lower than the damage they cause if left unattended. If a mishap is worth preventing, one must the ask how this should be accomplished: by the parties themselves – and which one of them – at their individual level, ...”. MACKAAY, Ejan. **Law and Economics for Civil Law Systems**. Op. Cit., p. 466., p. 414.

Portanto, a *performance bond* será vantajosa quando a seguradora possuir uma vantagem comparativa suficientemente superior ao governo, no que toca à capacidade de monitoramento e execução ou indenização em caso de inadimplência da contratada, que justifique a relação trilateral. A seguradora deve ser mais eficiente no monitoramento da empreiteira, minimizando consideravelmente os custos de monitoramento e os riscos envolvidos na operação.³³¹

Portanto, ao final, o custo da inclusão de tal garantia, em percentuais adequados, pode acabar compensando os custos da sua ausência no contrato, sendo assim uma cautela recomendável e capaz de beneficiar todas as partes do contrato, gerando mais segurança na execução do contrato e incentivando a cooperação.

4.3.1.1. Monitoramento e Assimetria de informações.

No capítulo inicial, destacou-se como a assimetria de informações e a dificuldade de monitoramento pelo poder pública acabam se convertendo em um espaço amplo para adoção de comportamentos oportunistas pelos contratados. Uma das razões apontadas, inclusive, era a dificuldade de se estruturar adequadamente a burocracia com pessoal qualificado (engenheiros, arquitetos, por exemplo), especialmente em municípios menores, para fiscalizar a execução das obras públicas.

O sistema trilateral é capaz, ao inserir um agente segurador, de mitigar um problema clássico das contratações públicas, o da assimetria de informações, induzindo a partilha de informações.³³²

Tal situação de desequilíbrio informacional ocorre porque os fornecedores possuem, quantitativa e qualitativamente, mais informações sobre os produtos, sua capacidade de operação e sobre o próprio mercado, que a Administração consumidora. Tanto pela especialização dos particulares quanto pela pouca capacidade de obtenção

³³¹ GOMES, Francisco Yokota Choucair. **Análise Econômica do Performance Bond nos Contratos de Obras Públicas**. Op. Cit. p. 25.

³³² Nesse sentido: “Para evitar tal comportamento oportunista, a reforma do sistema de contratações públicas deverá prever que a fiscalização do contrato não seja uma prerrogativa do poder público, mas uma função atribuída a um terceiro independente (expert naquela área de contratação). A expertise e a imparcialidade de um terceiro, inenunciável à influência das partes, farão com que, reduzida a assimetria de informações, o contrato seja mais bem fiscalizado.” FREITAS, Rafael Veras de, **Análise Econômica das Contratações Públicas**. Op. Cit. p. 28.

de informações do Poder Público, o qual geralmente busca informações no próprio mercado que irá concorrer no certame licitatório³³³.

Com a dinâmica do *performance bond*, a seguradora, com maior expertise em comparação com o Estado para o cálculo de riscos, faz uma avaliação sobre a capacidade técnica e financeira do licitante de cumprir o objeto contratual.

Parte da maior capacidade das seguradoras, se justifica pelo fato de, no momento de decidirem sobre a emissão da apólice, poderem utilizar instrumentos outros, indisponíveis aos contratantes públicos, reduzindo o problema de assimetria de informações sofrido pela Administração. Destaca-se entre tais mecanismos os de reputação no mercado, o qual será utilizado para avaliar o agente econômico aspirante a parceiro do Estado, decidindo não emitir a apólice caso considere o concorrente inapto ao serviço ou sua proposta inexequível.³³⁴

Como são “especializadas na gestão do risco e no monitoramento das condições da tomadora em realizar a obra de acordo com as especificações, classificam estas considerando sua performance pregressa”³³⁵, a negligência de uma construtora irá se converter, no futuro, em maiores dificuldades de contratação. Empreiteiras menos confiáveis irão pagar mais caro pelo seguro, logo, suas ofertas nos certames tenderão a ser mais caras para o Estado, enquanto as “empresas que possuem um histórico de maior confiabilidade podem, então, oferecer preços mais competitivos ao Estado, porquanto paguem um prêmio menor para obtenção do seguro-garantia”³³⁶. Mais além, ao fazer a análise da construtora para emissão do *performance bond*, as seguradoras acabam, indiretamente, realizando uma espécie de “pré-qualificação” dos licitantes.

Nesse sentido, a *performance bond* constitui-se como basicamente de um serviço de pré-qualificação do tomador da obra, baseado em sua saúde financeira e expertise técnica, acrescido dos custos de

³³³ Os orçamentos de estimativa dos valores dos produtos costumam ser pedidos pela Administração no próprio mercado, muitas vezes de agentes que poderão futuramente participar daquela competição. Nesse cenário, não há incentivos para munir o comprador estatal com informações precisas.

³³⁴ Sobre o tema, recomenda-se o seguinte artigo: BANERJEE, Abhijit. DUFLO, Esther. Reputation Effects and the Limits of Contracting: A Study of the Indian Software Industry. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 115, No. 3, (Aug., 2000), pp. 989-1017 Published by: The MIT Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2586901>. O qual afirma: “We interpret these results as showing that reputation (except for ISO certification) does influence the way the overruns are shared between the client and the firm.” p. 1007.

³³⁵ GOMES, Francisco Yokota Choucair. **Análise Econômica do Performance Bond nos Contratos de Obras Públicas**. Op. Cit. p. 31.

³³⁶ Idem.

monitoramento ao longo do contrato. Por esse motivo, ela é concedida quando há expectativa mínima de perda, e o prêmio é eminentemente uma taxa para o serviço de pré-qualificação.³³⁷

Com isso, a avaliação dos potenciais licitantes é feita por um terceiro independente, a qual possui todo o interesse na regular execução contratual pelo tomador do seguro.³³⁸

Desse modo, com a inclusão das seguradoras na relação, uma das maiores dificuldades da Administração Pública, obter informações reais e precisas sobre a real capacidade de seus potenciais contratados de concluir o projeto licitado poderá ser suprida. Até porque, para obter o seguro a um preço mais favorável para si, as empreiteiras tentarão mostrar o máximo de informações possíveis capazes de corroborar a sua capacidade técnica. Quanto às tentativas de ludibriar as seguradoras, a longo prazo, elas irão realizar uma análise reputacional das empreiteiras levando em conta, inclusive a confiabilidade das informações que fornecem, opção atualmente fora do leque do Poder Público contratante.

As seguradoras funcionariam como um sistema indireto de *rating*. Tal sistema já foi apontado como uma possível solução para melhora de qualidade das compras públicas.³³⁹ No caso do *performance bond*, as próprias seguradoras atuariam como o terceiro independente e os preços dos prêmios cobrados, os quais impactariam as propostas no certame, poderiam operacionalizar tal sistema, ainda que de forma indireta.

³³⁷ Ibidem, p. 10.

³³⁸ Pode-se ir além e elencar mais vantagens desse procedimento de pré-qualificação pela empreiteira: “Cada seguradora elabora sua pré-qualificação baseada em critérios próprios, de maneira que o interessado que não obtiver êxito na pré-qualificação em uma seguradora procurará outras, o que auxilia a garantir a pulverização e o fomento da competição no mercado de seguros. Schubert (200) menciona três vantagens proporcionadas aos beneficiários pela pré-qualificação feita pelas Seguradoras: i) evita o custo de pré-qualificar cada licitante potencial; ii) evita a oportunidade de favorecimento a concorrentes durante a fase de habilitação para a licitação; iii) garante a avaliação dos concorrentes por terceiro independente, que é uma empresa solvente e capaz de garantir esta avaliação. Às vantagens explicitadas por Schubert é acrescido o ganho em segurança na conclusão regular do contrato. XAVIER, Vitor Boaventura. **O Seguro Garantia de Execução do Contrato – Performance Bond: Uma Análise dos Aspectos Regulatórios e Concorrenciais da sua Exigência pela Administração Pública no Brasil**. Op. Cit. p. 19

³³⁹ Nesse sentido: “Para além de uma auditoria independente, poderia se cogitar da instituição de um adastro de fornecedores independentes (*rating*), por intermédio do qual seriam cadastradas informações qualitativas dos serviços prestados ao poder público, as quais poderiam servir como critério técnico de julgamento de propostas em futuras licitações. Com isso, seriam reduzidos os custos de transação decorrentes, seja das controvérsias a propósito da inexecução do contrato, seja do custo de dirimi-las perante o Poder Judiciário, seja ainda pelo custo de manter um aparato burocrático fiscalizador inócuo”. FREITAS, Rafael Veras de, **Análise Econômica das Contratações Públicas**. Op. Cit. p. 28.

4.3.1.1.1. Combate ao Risco Moral (*Moral Hazard*) e à seleção adversa.

De acordo com o exposto no capítulo inicial, duas das principais decorrências da assimetria de informação são o risco moral (*moral hazard*) e a seleção adversa. O primeiro se materializa com a mudança do comportamento do contratado após a celebração contratual. Ou seja, antes da contratação, o licitante tem incentivos para mostrar ser idôneo à realização do objeto avençado, mas depois da assinatura do termo, ele passa a agir de forma a se beneficiar às custas do contratante, utilizando insumos de menor qualidade, empregando mão de obra insuficiente e utilizando de atrasos nos cronogramas para obter reajustes indevidos, por exemplo. Destacou-se, ainda, como o risco moral acaba levando ao jogo de planilhas e ao problema de *hold up* da Administração.

Já a seleção adversa se traduz na escolha equivocada pela Administração de seus parceiros, por desconhecer a real capacidade do agente contratado de executar o objeto. Com isso, acaba correndo o risco de se vincular a uma empreiteira incapaz de concluir a obra, ou de fazê-lo com grandes atrasos.

No tópico anterior, destacou-se como o *performance bond* em percentuais adequados pode ser um instrumento para a redução das assimetrias de informação. A partir daí, é possível inferir que se a principal causa do risco moral e da seleção adversa for atacada, estes também serão atingidos por essa dinâmica contratual.

Pelo lado do risco moral, ao se inserir a seguradora como garante do contrato, ela se torna, ao mesmo tempo, também fiscal da boa execução contratual. Caso o contratado decida utilizar insumos capazes de, futuramente, comprometer o seguimento adequado da obra, ou reduza o emprego da mão de obra, a seguradora certamente irá notar esse aumento de risco e notificará o empreiteiro.

Até porque, um dos problemas evidenciados para o caso das licitações é que embora seja um jogo repetitivo, pois o Poder Público terá sempre de licitar para contratar um prestador de serviços, ele acaba funcionando como um jogo de rodada única para a Administração. Ela se vincula ao procedimento licitatório, e tirando os casos de punições impeditivas do direito de contratar com a administração (declaração de inidoneidade e suspensão no direito de contratar), não poderá eliminar um concorrente por um desempenho ruim em um contrato. Logo, para a Administração, é como se ela voltasse para a primeira rodada do jogo, enquanto o particular possui o incentivo de sempre se comportar de forma oportunista na sua atuação, pois não sofrerá uma punição grave “na próxima rodada” do jogo licitatório.

Com o alargamento *performance bond* a seguradora acaba funcionando como um elemento repetidor dos jogos em favor do Estado, pois o agente privado deverá, necessariamente, buscar no mercado de seguros uma apólice, mas seu comportamento pregresso será analisado. Portanto, o desvio em uma obra (uma rodada) será punido pela seguradora, seja mediante a cobrança de prêmios mais elevados, reduzindo a competitividade do particular, ou até mesmo pela própria negativa do seguro, em casos mais graves.

Já no caso da seleção adversa, ao buscar a obtenção da apólice, o empreiteiro deverá demonstrar como pretende concluir o projeto ao qual aspira se comprometer. Dessa maneira, a seguradora saberá, de antemão, se a lista de insumos utilizados será capaz de levar à conclusão da obra, bem como se está ocorrendo algum desvio capaz de caracterizar o jogo de planilhas.

Portanto, ao endereçar a questão da assimetria de informações, a ampliação do *performance bond*, por consequência, será capaz de mitigar as frequentes ocorrências de risco moral e seleção adversa nas contratações públicas.

4.3.1.2. Continuidade do Projeto e Menor Custo de Substituição do Contratado.

A marca distintiva do Seguro Garantia de execução de obrigação, como evidenciado no capítulo dois, é a possibilidade de conclusão do objeto do contrato, no caso da presente dissertação, uma obra pública, pela própria seguradora.

Por mais que o objetivo elementar do instituto seja evitar o inadimplemento, uma de suas vantagens se manifesta, paradoxalmente, quando este ocorre.

Se a seguradora pode assumir a execução do projeto, é natural inferir que isso dispensa a realização de uma nova licitação, e todo o custo que tal atividade traz consigo. Até porque, licitações de projetos em andamento acabam saindo mais custosas para o Poder Público, na medida em que a deterioração do canteiro de obra, e dos objetos já incorporados demanda o refazimento de parte do trabalho. Ademais, os licitantes na retomada não tem noção exata de qual nível de degradação irão encontrar no canteiro abandonado, caracterizando mais um risco para ser precificado nas propostas oferecidas.

A garantia de conclusão da obra, pela seguradora, reflete em maior segurança para o Estado contratante, de forma mais evidente, mas também para os fornecedores, subcontratados e à mão de obra empregada no projeto.³⁴⁰

A continuidade do projeto pela própria seguradora permite a continuidade das relações econômicas subjacentes àquela obra públicas, as quais poderiam ser paralisadas subitamente em caso da rescisão contratual por inadimplemento da construtora. Nesse sentido:

O *performance bond* garante que se a empreiteira inadimplir o contrato, outro agente econômico irá se fazer presente com fundos suficientes para cumprir as obrigações assumidas pelo contratado original. Subcontratados valorizam a continuidade da execução contratual com alguém capaz de ratificar seus contratos sem a necessidade do enfrentamento de novo processo licitatório.³⁴¹

Assim, para os agentes econômicos que orbitam no entorno do projeto, também há uma vantagem. A continuidade dos investimentos e a retomada rápida da construção evitam considerável desperdício de recursos que o abandono e retomada, depois de um período incerto e não muito previsível, pode causar.

A continuidade do contrato, também, é capaz de endereçar parte do problema de *hold up* contratual da Administração Pública. Na medida em que o inadimplemento contratual da empreiteira responsável pode ser resolvido com a ativação da seguradora, aquela não se encontra mais em uma espécie de monopólio temporário com a Administração Pública. Pois esta passa a ter a opção de iniciar um procedimento de notificação de sinistro para investigar a conduta da contratada. Logo, reduz-se a chance do Estado ficar refém de um contratado oportunista e presa a um contrato desvantajoso.

4.3.2. Quanto ao Combate à Corrupção

³⁴⁰ Nesse sentido: “Fornecedores, subcontratados e a mão-de-obra envolvida na construção pública não participam da decisão a respeito da contratação da *performance bond* e, por isso, aquilo que os afete pode ser considerado uma externalidade. Assim, uma externalidade positiva decorrente da *performance bond* é a maior segurança que traz aos fornecedores, subcontratados e à mão de obra.” GOMES, Francisco Yokota Choucair. **Análise Econômica do Performance Bond nos Contratos de Obras Públicas**. Op. Cit. p. 31.

³⁴¹ Livremente traduzido de: “The performance bond ensures that if the contractor defaults on the project someone else will be there with sufficient funds to see that the contractor’s obligation to perform is completed. Subcontractors value having the performance continue with someone able to reaffirm the subcontracts without having to rebid the work under public bidding laws.” SCHUBERT, Lynn. The Legal Basics of Surety Bonds. **ABC Construction Executive Magazine**. November, 2003. p. 50. Disponível em: https://suretyinfo.org/news_room/products/legal_basics.pdf; acesso em 28 de novembro de 2019.

Fala-se muito, no Brasil e no mundo³⁴², de combate à corrupção por meio de normas de enfrentamento direto, como a Lei Anticorrupção. Este, de fato, pode ser um caminho para a redução das práticas ilícitas muito frequentemente encontradas nas relações envolvendo o Estado. Todavia, também é possível a utilização de meios indiretos para esse combate, mediante o alinhamento de incentivos e a quebra da interlocução direta entre os agentes públicos e seus contratados. Até porque não é possível confiar piamente na potencial de programas de *compliance* como um instrumento capaz de, sozinho, acabar com toda a rede de interlocução direta entre dirigentes de grandes construtoras e agentes estatais.³⁴³

O problema da corrupção pode ser visto como um multiplicador de danos à sociedade. Pare além do prejuízo imediato causado pela conduta ilícita, ela também funciona como gatilho para outros, como a construção de infraestruturas que demandam manutenção em níveis acima do normal, por conta de construção ineficiente, atrasos constantes, aditamentos desnecessários, entre outras questões maléficas ao erário.³⁴⁴

³⁴² Nesse sentido: “Hoje em dia, a percepção universal, encampada pela ONU, é que a corrupção dos governos de grande parte dos países, em conluio com as empresas – locais e multinacionais –, é a causa do grande desperdício de recursos do Estado, ...” CARVALHOSA, Modesto. *Performance Bonds: Quebra da Interlocução Direta entre Agentes Públicos e Privados na Execução de Contratos Administrativos*. Op. Cit. [n.p.]

³⁴³ Sobre a efetividade de programas de *compliance*: “O compromisso com a ética e com o regime de integridade não são efetivos nessas empresas, porque a política de interlocução com os agentes públicos se dá em outro nível – o das relações externas – que não é atingido pelas regras e sistemas de controle, próprio do *compliance*. Nas empresas cujos proprietários e principais dirigentes estão sendo processados pelos crimes de corrupção, o regime de *compliance* constitui mera falácia, que tem por objetivo único permitir a restauração espúria do direito de contratar com o Poder Público e diminuir as multas aplicáveis e – ainda mais grave – dispensar o ressarcimento cabal dos danos causados ao Estado...” Idem [n.p.]

³⁴⁴ Sobre esse efeito: “A corrupção não se restringe aos subornos – *bribes*; *pot de vin* – que representam apenas a parte visível dessa praga. Hoje em dia tem-se a noção clara que o seu efeito devastador decorre da impossibilidade de amortização do investimento feito pelos governos em seus orçamentos para contratos com o setor privado, notadamente de obras públicas, que com frequência não são entregues, ou são abandonadas como sucatas ou ainda, quando entregues, o são com atrasos e qualidade inferior, e, que, por isso, demandam constantes reparos, elevação dos custos de manutenção e, até mesmo, o refazimento de serviços. É comum que as obras sejam submetidas a constantes aditamentos de preços que, na grande maioria dos casos, não se devem à impossibilidade de prever todas as ocorrências na execução da obra. Os contratos são incompletos, sem projetos básicos efetivos devido à pura fraude, que os tornam, na maioria dos casos, muito mais caros que o valor inicialmente estimado. E, sempre, as grandes concorrências são dirigidas a grupos cartelizados, formados por empresas multinacionais e locais.” (...) “Muito mais grave, no entanto, é o montante de perda de investimento (*Impairment*) decorrente do superfaturamento e da não entrega das obras e serviços pelas empreiteiras e fornecedoras: R\$ 42 bilhões. Por aí se vê a imensa diferença entre o valor do suborno, R\$ 6,2 Bilhões de propinas – e a não amortização do capital nas obras superfaturadas: R\$ 42 Bilhões” Idem [n.p.]

Modesto Carvalhosa assevera que, no cenário nacional, a situação é agravada em razão da persistência de um sistema de capitalismo de laços, também chamado de *crony capitalism*³⁴⁵. Este pode ser entendido como uma espécie de capitalismo no qual o sucesso nos empreendimentos decorre primeiro das relações entre os empresários e os agentes estatais, no lugar de ser baseado na competição livre e igualitária entre agentes econômicos, a partir da produtividade, no mercado³⁴⁶.

Como consequência desse sistema, há o favoritismo de determinadas empresas para a contratação de obras e serviços, a partir da manipulação e fraude a projetos básicos e ainda fraudes em aditivos superfaturados³⁴⁷ e execuções incompletas e/ou defeituosas.³⁴⁸

Com isso, para o endereçamento efetivo da corrupção envolvendo contratações estatais, seria necessário romper com essa lógica de capitalismo de laços. Um dos instrumentos para tanto é “a quebra da interlocução direta das empreiteiras e fornecedoras com os agentes políticos e administrativos”³⁴⁹.

Um instrumento capaz de realizar tal ruptura, nos contratos envolvendo obras públicas, é o *performance bond*. Isso porque a sua estrutura determina, necessariamente a inclusão de um terceiro na relação contratual. Mais além, trata-se de

³⁴⁵ Idem. [n.p.]

³⁴⁶ Nas palavras do autor: “No Brasil, da mesma forma como em muitos outros países, prevalece o capitalismo de laços, o *crony capitalismo*. No Brasil, o capitalismo de laços é liderado pelas empreiteiras de obras públicas que, na sua quase totalidade são controladas por grupos familiares, o que permite uma manipulação pessoal continuada das relações com os agentes políticos e administrativos. Nesta forma de capitalismo anacrônico, que tem como característica básica o fato de que o sucesso nos negócios depende fundamentalmente das relações entre os empresários e os agentes públicos. Vale mais o relacionamento com autoridades, buscando a obtenção de vantagens, do que o aumento da produtividade, buscando a redução de custos.” Idem, [n.p.]

³⁴⁷ Quanto aos aditivos superfaturados: “Não se pode deixar de notar que, no Brasil, o comportamento oportunista de contratadas pelo setor público é frequente, até mesmo pelas falhas proporcionadas pelo procedimento licitatório e pela contratação em obras públicas, além do fator corrupção. Como ressalta Eduardo Fiuza (2009, p. 247-248), o conhecimento especializado da empreiteira é utilizado antes mesmo que a construção comece por meio da detecção de falhas de projeto, o que a permite realizar o denominado jogo de planilha, caracterizado por lances baixos em itens com quantitativo exagerado e lances altos em itens com quantitativo baixo (subsídio cruzado). Esses quantitativos são posteriormente revistos por meio da proposição de aditivos para sanar as falhas de projetos. GOMES, Francisco Yokota Choucair. **Análise Econômica do Performance Bond nos Contratos de Obras Públicas**. Op. Cit. p. 26

³⁴⁸ Corroborando o afirmado: “Daí resulta o favoritismo de determinadas empresas que contratam obras, serviços e fornecimentos para o Estado. Esses laços levam à manipulação e à fraude de projetos básicos quando existem das concorrências e dos leilões, bem como dos termos e das cláusulas permissivas dos contratos firmados com os governos e as estatais. Permitem esses laços, na sequência, a fraude permanente em tais contratos, mediante aditivos superfaturados, a execução incompleta ou defeituosas das obras etc”. CARVALHOSA, Modesto. *Performance Bonds: Quebra da Interlocução Direta entre Agentes Públicos e Privados na Execução de Contratos Administrativos*. Op. Cit. [n.p.]

³⁴⁹ Idem. [n. p.].

terceiro com interesse na regular execução da obrigação do contrato pela Administração Pública³⁵⁰.

Como ficou claro em seções anteriores, o objetivo primordial desse tipo de garantia é assegurar, a partir da conduta diligente da seguradora, a não ocorrência do sinistro. Entre os instrumentos para tanto, o garantidor realiza uma criteriosa pré-qualificação e acompanha a realização da obrigação pelo seu segurado. Portanto, o segurador funciona como um fiscal do contrato, e como foi explicado, para os dois lados, uma vez que a apólice do seguro garantia cria obrigações tanto para o tomador quanto para o beneficiário.

A fiscalização das seguradoras, para evitar a possibilidade de sinistros, englobará questões além do próprio comportamento do segurado, nesse sentido:

É razoável assumir que falhas no projeto e propensão a atos de corrupção são fatores a serem observados pelas seguradoras, na medida em que ampliam seus riscos, consubstanciado no aumento do grau de incerteza de uma obra. Embora a fiscalização da seguradora não elimine essas incertezas, certamente concorrem para sua diminuição. Portanto, considerando a grande quantia de dinheiro envolvida em uma obra, pode-se concluir que um dos benefícios do *performance bond* é o incentivo dado à seguradoras para que fiscalizem os recursos ali utilizados, servindo como aliado no combate à corrupção.³⁵¹

Portanto, o *performance bond* pode funcionar como um instrumento indireto de combate à corrupção nos contratos de obras públicas. A inserção de um terceiro fiscal na relação dificulta o conluio entre os agentes públicos e os empreiteiros e com a atuação da seguradora como um intermediário na relação entre as partes há a dificuldade de uma interlocução aberta e direta entre contratante e contratado, aumentando os custos de transação para condutas ilícitas.³⁵²

³⁵⁰ Nesse sentido: “Ela [o *performance bond*] estrutura um sistema no qual um terceiro se insere na relação contratual, na condição de interessado em sua regular execução.” Idem, [n. p.].

³⁵¹ GOMES, Francisco Yokota Choucair. **Análise Econômica do Performance Bond nos Contratos de Obras Públicas**. Op. Cit. p. 26.

³⁵² Nesse mesmo sentido conclui Modesto Carvalhosa sobre o *performance bond*: “Trata-se, com efeito, de importante mecanismo de incentivo à execução regular de obras públicas e de ação anticorrupção, pela quebra da interlocução direta entre agentes públicos e privados. A estruturarão de um regime de garantias contratuais que atribua poder fiscalizatório às seguradoras e maximize os patamares legais da importância segurada (100%) objetiva trazer à seguradora, na qualidade de terceira interessada na regular execução do contrato, os incentivos adequados para oferecer esse produto. A eficiência gerada pelo sistema de *performance bond* aponta o caminho para o aprimoramento dos instrumentos de ética pública e a aferição da capacidade de execução contratual, objetivando a amortização do capital alocado

4.4. Dificuldades à Implantação.

Todavia, a utilização de seguros não é, per si, a solução de todos os problemas envolvendo a estrutura contratual do Estado. Dessa maneira, esse novo desenho contratual pode sofrer dificuldades na implantação, bem como se mostrar, na prática, insuficiente para solucionar as disfunções contratuais apontadas.

4.4.1. Insuficiência do Mercado.

A primeira delas está relacionada com a capacidade, ou falta dela, de o mercado brasileiro de *performance bond* fazer frente à ampliação da demanda, no caso do aumento do percentual exigido nas licitações.

Embora tenha-se mostrado no capítulo anterior um recente crescimento desse mercado, não necessariamente está pronto para o aumento súbito que uma mudança normativa é capaz de causar.³⁵³

O modelo utilizado como exemplo nessa dissertação foi o americano, onde o mercado de *performance bond* existe há mais de um século, então, de fato, deve-se observar a reação do setor de seguro à expansão da demanda, bem como se tal expansão repentina pode acabar se refletindo em uma inflação de preços, ao menos no estágio inicial da ampliação do instituto.

Como alternativa para o aumento da capacidade de absorção do mercado é possível citar a utilização de operações de cosseguro e/ou resseguro bem como a admissão de novos agentes internacionais. Porém, o uso da segunda opção,

pelo Estado nas obras contratadas.” CARVALHOSA, Modesto. Performance Bonds: Quebra da Interlocução Direta entre Agentes Públicos e Privados na Execução de Contratos Administrativos. Op. Cit. [n.p.]

³⁵³ Nesse sentido: “Segundo anota Laan (2016), existem dúvidas a respeito da capacidade do mercado segurador brasileiro em absorver a demanda gerada pela obrigatória contratação da apólice e ampliação do patamar de importância assegurada para 100% do valor do contrato. Igualmente aos EUA, onde as regras do *United States Treasury* limitam que cada apólice emitida pela seguradora não ultrapasse 10% por cento de seu excedente, no Brasil, a retenção de riscos do setor de seguro é de 5% do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA). Nesse sentido, qualquer elevação nos atuais patamares de importância assegurada deve observar os limites de absorção do mercado brasileiro, pois há limitada capacidade de retenção para este produto específico.”

atualmente, dependeria de mudanças normativas para permitir a entrada de operadores estrangeiros no mercado de Seguro Garantia.³⁵⁴⁻³⁵⁵

4.4.2. Capacidade Regulatória da SUSEP.

Outro ponto passível de questionamento é se a SUSEP encontra-se adequadamente estruturada para regular o crescimento desse produto no mercado de seguros. A regulação pode ser vista como “fundamental para manter uma atuação criteriosa das seguradoras durante o processo de subscrição da apólice e para certificar níveis adequados de competição nos mercados envolvidos”³⁵⁶. Em 2012, o Fundo Monetário Internacional realizou uma avaliação sobre a observância, no Brasil, dos princípios da Associação Internacional de Supervisores de Seguro, a qual congrega reguladores e supervisores de seguros de mais de 200 países e responde por 97% dos prêmios de seguro no mundo³⁵⁷. Tal relatório realizou uma avaliação do funcionamento e atuação da SUSEP, bem como da moldura regulatória do setor de

³⁵⁴ XAVIER, Vitor Boaventura. **O Seguro Garantia de Execução do Contrato – Performance Bond: Uma Análise dos Aspectos Regulatórios e Concorrenciais da sua Exigência pela Administração Pública no Brasil**. Op. Cit. p. 43.

³⁵⁵ Não se pode ignorar, ainda, os efeitos da entrada de operadores internacionais de seguro, como ocorreu no caso da sua entrada no mercado de resseguros em 2007, quanto a isso: “Laan (2016) relembra que ‘a própria abertura de mercado de resseguros doméstico, a partir de 2007, esteve associada a essa mesma necessidade de contratação de grandes obras públicas, incluindo os investimentos bilionários no pré-sal’. A propósito, as operações de resseguro são uma alternativa relevante para ampliar a capacidade de retenção de riscos. Entretanto, a abertura nacional de resseguros aos resseguradores internacionais pode ter sido prejudicial, tanto na perspectiva regulatória, pois a Susep absorveu atribuições do antigo IRB de maneira insatisfatória, como na perspectiva do desenvolvimento do mercado segurador nacional. A esse respeito, afirmou Tzirulnik (2015), ao mencionar o jargão da prática profissional: “quem controla o resseguro controla o seguro”, que o desmantelamento do monopólio do IRB teria representado o distanciamento da realidade em que o resseguro atendia ao desenvolvimento social e econômico, assim como equilibrava a competitividade do mercado segurador local” Ibidem, pp. 43-44.

³⁵⁶ Ibidem, p. 44.

³⁵⁷ Sobre a *International Association of Insurance Supervisors*: “Established in 1994, the IAIS is a voluntary membership organization of insurance supervisors and regulators from more than 200 jurisdictions, constituting 97% of the world's insurance premiums. It is the international standard-setting body responsible for developing and assisting in the implementation of principles, standards and other supporting material for the supervision of the insurance sector. The IAIS also provides a forum for Members to share their experiences and understanding of insurance supervision and insurance markets. In recognition of its collective expertise, the IAIS is routinely called upon by the G20 leaders and other international standard setting bodies.” Disponível em: <https://iaisweb.org/page/about-the-iais> Acesso em: 29 de novembro de 2019.;

seguros pela Superintendência, apresentando sugestões de melhorias e propondo reformas.³⁵⁸

No relatório foi destacado como as normas estruturantes da SUSEP podem ser uma fonte de enfraquecimento da sua independência e capacidade regulatória, recomendando, inclusive, a adoção de procedimentos mais transparentes para a nomeação de dirigentes e aumento de exigências técnicas para a edição de atos normativos.³⁵⁹⁻³⁶⁰

Portanto, para a ampliação saudável do uso do Seguro Garantia, e a consequente expansão do mercado, seria necessário o aumento da capacidade regulatória da SUSEP. Até porque, atualmente, já é possível notar algumas omissões legislativas e regulamentares relevantes, como a ausência de normas sobre a fiscalização das seguradoras sobre o tomador do serviço³⁶¹, e a falta de regramento quanto ao *step-in* do garante no projeto, quando constatado o sinistro.

Com isso, para a harmonização entre os interesses divergentes entre segurador, tomador e beneficiário, é necessário o reforço das estruturas regulatórias, no caso da SUSEP, para acompanhar e garantir o desenvolvimento do mercado, elaborar e fiscalizar o cumprimento de normas técnicas e avaliar a estrutura regulatória. Mais

³⁵⁸ XAVIER, Vitor Boaventura. **O Seguro Garantia de Execução do Contrato – Performance Bond: Uma Análise dos Aspectos Regulatórios e Concorrenciais da sua Exigência pela Administração Pública no Brasil**. Op. Cit. p. 45.

³⁵⁹ Conforme itens 23 e 24 do mencionado relatório: “ 23. **The legal framework governing SUSEP contains elements that undermine the independence and capacity of the supervisor to fulfill effectively its mandate and objectives:** The CNSP can and has issued regulation based on limited technical input from SUSEP. The requirements of operational use of the allocated budget, like the approval of international travel, needs the approval of the MOF. There is no framework for the nomination of the Superintendent and Directors and there are no minimal requirements on their qualification. The Superintendent and the Directors of SUSEP are nominated and can at any time be dismissed by the President of the Republic. Similarly, the officers of SUSEP are nominated and can at any time be dismissed by the Superintendent. Dismissal reasons are not published. 24. **SUSEP operational independence needs to be strengthened by introducing a transparent appointment procedure,** requiring technical input on any regulation and providing autonomy on the use of the allocated budget.

³⁶⁰ No mesmo sentido: “Particularmente em relação ao princípio da supervisão/regulação, são alarmantes os resultados, sobretudo na perspectiva da capacidade regulatória da Susep. O FMI afirma que o quadro legal que rege a Susep contém elementos que minam sua independência e capacidade de realizar plenamente os seus objetivos de supervisão do mercado. XAVIER, Vitor Boaventura. **O Seguro Garantia de Execução do Contrato – Performance Bond: Uma Análise dos Aspectos Regulatórios e Concorrenciais da sua Exigência pela Administração Pública no Brasil**. Op. Cit. p. 45.

³⁶¹ Atualmente não há qualquer norma que forneça parâmetros, indique meios e estabeleça direitos e deveres das partes especificamente quanto a esse tema, o qual é muito sensível no contexto do *performance bond*, quanto a isso, tem-se que: “A fiscalização – função essencial à estruturação do sistema de incentivos a regular completude do contrato – fica prejudicada diante da omissão legislativa e regulamentar, de modo que, no Brasil, as seguradoras podem encontrar a dificuldade de ingressar no canteiro de obra por elas garantidos.” Ibidem, p. 42.

ainda, o regulador pode funcionar como um agente informador dos agentes econômicos, fomentando a compreensão e o crescimento do instituto.³⁶²

4.4.3. Prejuízo à Concorrência (competitividade) na Licitação.

Pode-se incluir, ainda, como mais um risco da exigência do *performance bond* em percentuais mais elevados em licitações a possibilidade de prejuízo à concorrência nos certames licitatórios.

Não se pode deixar de considerar o *performance bond* como uma exigência adicional aos licitantes, dessa maneira, eles precisarão buscar a apólice no mercado de seguros, e nem todos conseguirão, portanto é possível inferir a redução de concorrentes no certame licitatório.³⁶³ Maiores requisitos para a participação na licitação podem se converter em barreiras de entrada para operadores com menor porte, ou ainda muito recentes no mercado, reduzindo a própria competitividade da licitação³⁶⁴.

Nesse sentido, deve-se atentar para o *trade-off* posto em questão: de um lado, a exigência do *performance bond* trará maior segurança para a Administração em seus contratos de obras públicas; mas por outro, reduzirá a competitividade dos certames, fato com potencial de ensejar lances mais caros, logo menos vantajosos, para o Estado. Portanto, é importante a observância das condições fáticas das compras públicas para

³⁶² Sobre a atuação do regulador: “Nesse contexto, a regulação assume um papel central para garantir a necessária harmonização dos interesses divergentes, no sentido da persecução dos mencionados elementos de funcionalidade do novo regime de *performance bond*. Ela é fundamental para acompanhar a atividade do mercado, para elaborar as normas técnicas, para verificar o seu cumprimento e para proceder avaliações sobre a efetividade da política regulatória em andamento. Outra função relevante do regulador seria a de orientar os atores envolvidos, mediante a produção de cursos e a divulgação de cartilhas, manuais e toda sorte de informações sobre o produto e como utilizá-lo.” Ibidem, p. 66.

³⁶³ Nesse sentido: “A posição de Graells (2011) bem representa a posição contrária à exigência de quaisquer garantias contratuais por parte da Administração Pública na licitação. O autor sustenta que do ponto de vista do Antitruste, ao exigir o cumprimento de determinados requisitos como critérios de qualificação à participação no pleito licitatório, o poder público restringe o acesso esperado pela livre concorrência. Assim, são vistos em perspectiva negativa os *surety bonds* (gênero do qual as *performance bonds* são uma espécie) ou *document bonds* (exigência de prévia experiência no objeto da licitação) por impactarem substantivamente a dinâmica e o nível de competição dos mercados. Ibidem, p. 47.

³⁶⁴ Dessa maneira: “uma vez exigida a apresentação do *performance bond* como um requisito necessário para a execução contratual, a apólice causaria prejuízo à concorrência na licitação pública, em contrariedade ao princípio da liberdade de concorrência do mercado”. Ibidem, p. 49.

tomar uma decisão quanto à exigência ou não de níveis mais elevados de *performance bond*.³⁶⁵

4.5. Comentários sobre o Projeto de Lei n.º 1292/1995.

Atualmente tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n.º 1.292/1995, o qual consolida diversos projetos de lei com o objetivo de alterar a Lei n.º 8.666/1993. Em relação ao ponto focal do presente trabalho, o uso do seguro garantia em contratos de obras públicas, destacam-se as seguintes disposições, constante do capítulo das garantias, da redação atual³⁶⁶:

Art. 95. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos.

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I – caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, emitidos sob a forma escritural mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II – seguro-garantia;

III – fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

§ 2º Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

§ 3º O edital fixará prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data da homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista no inciso II do § 1º deste artigo.

Art. 96. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante a Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta Lei:

³⁶⁵ Nesse sentido: “O *trade-off* decorrente da proposta de exigência da apólice de *performance bond* como única garantia dos contratos administrativos consiste, de um lado, na legítima persecução da regular execução contratual pela Administração Pública e, por outro lado, a igualmente legítima persecução de níveis adequados de concorrência na licitação. Apesar de tratar-se de *trade-off*, que implica uma escolha com perdas e ganhos, é necessário um esforço de harmonização entre ambos os objetivos, que são de grande relevância para a eficiência da licitação e o desenvolvimento nacional.” Ibidem, p. 49.

³⁶⁶ Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1819390; Acesso em 15 de dezembro de 2019.

I – o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;

II – o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.

Parágrafo único. Nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data da renovação ou do aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 95 desta Lei.

Art. 97. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

Parágrafo único. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos com vigência superior a 1 (um) ano, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais previstos no caput deste artigo.

Art. 98. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia, na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada prevista no art. 101 desta Lei, em percentual equivalente a até 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato.

Art. 99. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Art. 100. Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela Administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia.

Art. 101. Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese em que:

I – a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente, e poderá:

- a) ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal;
- b) acompanhar a execução do contrato principal;
- c) ter acesso a auditoria técnica e contábil;
- d) requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento;

II - a emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal;

III – a seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente.

Parágrafo único. Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes disposições:

- I – caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice;
- II – caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância segurada indicada na apólice.

A atual redação do projeto de lei em questão apresenta avanços relevantes para o instituto, especialmente quanto a sua aplicação no contexto de contratos de obras.

Inicialmente, a proposta define o instituto do seguro garantia bem como determina sua vigência mínima e ainda prevê que o inadimplemento do prêmio pelo tomador não afeta os direitos do beneficiário, conforme as normas regulatórias sobre o tema.

Inovação importante proposta pelo projeto é a possibilidade de ampliação do percentual coberto pela garantia em tal categoria de contratos para até 30% do valor do contrato, enquanto nos contratos em geral, de fornecimento de bens ou serviços, os percentuais ficam limitados ao patamar atual de 5 a 10% do valor do contrato, conforme o arts. 97 e 98.

Com isso, reconhece-se a necessidade de maiores cuidados nos contratos de obras públicas em comparação com outras espécies de contratos administrativos. Ademais, tal instrumento passa a ser obrigatório em obras públicas, o que endereça um dos obstáculos apontados nesta dissertação a maior utilização do *performance bond*, qual seja, a possibilidade de o contrato escolher a garantia, o que o levava a buscar outros mecanismos, mais fáceis de se adquirir no mercado e que não são tão eficazes para atestar sua capacidade de executar o objeto contratual.

Embora o percentual de 30% ainda possa parecer pequeno, trata-se de um patamar aceito pelo mercado, o qual ainda não parece preparado para um *performance bond* no estilo americano, de cobertura total. Nesse sentido:

(...) a elevação proposta de 30% do valor do contrato é bem aceita pelo mercado tendo em vista que se o percentual fosse elevado para 100% o valor do prêmio seria inviável ao negócio, sendo assim, essa elevação permitiria que as seguradoras tenham fôlego para garantir a retomada da obra, cobrindo os custos necessários para a contratação de uma nova construtora após a quebra de contrato.³⁶⁷

³⁶⁷ DORIA, Thaila Renata Teixeira Doria. **Seguro Garantia como Alternativa às Obras Públicas Paralisadas no Brasil**. Op. Cit. p. 53.

Com a previsão de tal percentual permite-se uma instalação mais paulatina do instrumento no Brasil, sem exigir que o mercado segurador tenha que se adaptar rapidamente a uma demanda subitamente ampliada. Ou seja, é possível experimentar o *performance bond* e, em caso de sucesso na realidade brasileira, pensar em ampliar a sua utilização em reformas legislativas futuras.

Ademais, houve considerável avanço na previsão de direitos para a seguradora, facilitando a sua atuação fiscalizatória. Como destacado em tópico anterior, uma das dificuldades à implantação do *performance bond* é a falta de normatização quanto à atuação fiscalizatória do segurador, tal questão é tratada no art. 101, I, o qual abre à seguradora a possibilidade de ter o acesso às instalações em que for executado o contrato principal, o acompanhamento da execução do contrato principal, o acesso a auditoria técnica e contábil e a requisição de esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento, prerrogativas essenciais para a supervisão do serviço executado pelo tomador.

Igualmente relevante é a participação da seguradora como anuente nas avenças relativas ao contrato principal, inclusive termos aditivos. Tal participação, pode funcionar como um instrumento capaz de mitigar a utilização desviada de termos aditivos

Merecem, ainda, destaque as previsões relativas ao inadimplemento pelo contratado, tomador do seguro. A norma abre à seguradora a possibilidade de escolher entre pagar o valor previsto na apólice ou assumir a conclusão da obra segurada, mediante a (sub)contratação de terceiros, total ou parcialmente.

Dessa maneira, embora o projeto de lei não trate de todos os detalhes levantados ao longo desta dissertação, especialmente quanto ao procedimento de *step-in*, em relação à regulamentação do seguro garantia, ele deixa uma estrutura consideravelmente mais sólida que as normas atuais para a Administração Pública detalhar, até mesmo por meio de cláusulas padrão em contratos administrativos.³⁶⁸

³⁶⁸ Acredita-se que com o tempo e acúmulo de experiência pelo Poder Público, será possível a aprendizagem institucional que poderá levar ao aproveitamento das possibilidades de tal instrumento de garantia.

5. CONCLUSÃO

Por mais que seja um tema muito trabalho pela literatura administrativista no Brasil, o campo de estudo das compras públicas e contratos administrativos ainda tem muito espaço para receber influxos de diferentes matrizes teóricas, especialmente da Análise Econômica do Direito, como se demonstrou na presente dissertação.

A pergunta de pesquisa inicialmente apresentada foi: como a utilização do Seguro Garantia, na espécie de garantia de execução (*performance bond*), pode ser um instrumento para gerar incentivos ao adimplemento de contratos de obras públicas?

A hipótese inicial de pesquisa é que o *performance bond*, o seguro garantia na espécie garantia de cumprimento de obrigação, é um mecanismo contratual apto a incentivar a execução adequada, e o consequente adimplemento, nos contratos de obras públicas, a partir do alinhamento dos incentivos dos polos contratuais, contribuindo, ainda, para dificultar práticas de corrupção.

Para responder tal pergunta e avaliar a nossa hipótese inicial, buscou-se utilizar o método da Análise Econômica do Direito para compreender de uma forma não limitada apenas ao arcabouço jurídico do sistema contratação de obras públicas. Isto é, tentou-se ir além do estudo das previsões legais sobre o tema, para entendê-lo a partir de como o sistema de incentivos desenhado pelas normas acaba influenciando no comportamento das partes.

Com isso, no primeiro capítulo realizou-se um diagnóstico de como o sistema em análise encontra-se disfuncional. Prova disso é o elevado índice de empreitadas paralisadas, praticamente uma em cada três obras iniciadas se encontram em estado inercial.

Como possível solução para o cenário pouco animador encontrado, aventou-se a possibilidade da ampliação do uso do Seguro Garantia de Execução de Obrigação Contratual, também conhecido como *performance bond*, instituto utilizado desde o final do século XIX nos EUA. Atualmente, no Brasil, sua aplicação em contratos administrativos está limitada ao percentual de 10% do valor do contrato, limitando muito todas as potencialidades da utilização mais ampla do instituto. A subutilização é agravada, ainda, em razão da escolha da garantia a ser oferecida na assinatura do contrato administrativo caber ao contratado, não ao poder público, de forma que

aquele tem incentivos para, apenas, minimizar seus custos e apresentar o instrumento de garantia mais barato, mesmo que seja o menos benéfico para o Estado.

Não obstante, antes de se aplicar algum instrumento jurídico a determinada situação, é recomendável compreender a natureza, nuances e aplicação do instituto em questão. Para tanto, no segundo capítulo, realizou-se uma discussão sobre como se pode entender o *performance bond* e de que maneira ele pode ser qualificado no direito brasileiro. Concluiu-se pela sua natureza securitária, em razão da aplicação do arcabouço normativo dos seguros a sua operacionalização.

Finalmente, no capítulo conclusivo, aplicou-se o instrumento jurídico exposto no segmento intermediário, ao problema identificado na parte inicial.

Dessa maneira, explicou-se como o *performance bond* pode ser um instrumento apto a realinhar os incentivos das partes em um contrato administrativo, as fazendo convergir para uma relação mais cooperativa, em detrimento de uma baseada em antagonismos. Para tanto, utilizou-se como modelo o ordenamento jurídico americano, no qual o *performance bond* possui uma história secular e se tornou um instituto comum a todos os estados da federação ianque.

Todavia, não se trata de uma solução imediata e sem qualquer tipo de custos, As dificuldades de implantação devem ser levadas em conta ao se pensar na mudança de aplicação de um instrumento jurídico.

Como atualmente não há a obrigatoriedade de sua apresentação pelos licitantes e seu percentual máximo exigido é de 10%, o instituto tem pouca efetividade no Brasil, fazendo, inclusive, com que muitos questionem a sua real existência no contexto de contratos públicos. Ampliar o percentual e tornar sua apresentação obrigatória em obras públicas, certamente, causaria um impacto considerável no mercado desse seguro no Brasil, o qual não necessariamente teria capacidade operacional para absorver esse aumento súbito de demanda.

Mais que isso, há problemas a serem enfrentados pelos reguladores, conforme relatório do FMI. A SUSEP, responsável pelo setor, atualmente, possui obstáculos a sua atuação como regulador do mercado de seguros, o que acaba refletindo em insegurança para os agentes econômicos e dificultando a consolidação do mercado do seguro garantia.

Ademais, caso a ampliação do *performance bond* seja exitosa, é possível que a competitividade da licitação seja afetada em alguma medida, pois os agentes

econômicos interessados em participar do certame licitatório deverão cumprir mais uma exigência, o que pode reduzir os interessados.

Assim sendo, aparentemente, há um *trade-off* a ser enfrentado: por um lado, a segurança da execução dos contratos de obras públicas é ampliada, mas por outro, a competitividade pode ser reduzida.

A partir de todo o exposto, tendo em vista o cenário fático no qual o percentual de obras paralisadas é altíssimo, assim como o sobrepreço e as atuações oportunistas dos contratos, a utilização de um *performance bond* mais efetivo (obrigatório em obras públicas e em percentuais mais elevados) parece recomendável, mesmo que às custas de algum nível de competitividade. Tal opção, no contexto atual das obras públicas no Brasil, apresenta maiores benefícios líquidos ao Estado e, conseqüentemente, à população.

Portanto, quanto à hipótese de pesquisa aventada, de fato, o *performance bond* se afigura como um instrumento jurídico capaz de melhorar o atual cenário dos contratos de obras públicas e fomentar o seu adimplemento em níveis mais adequados para a Administração Pública. Não obstante, não se pode perder de vista as dificuldades para sua implementação na realidade brasileira.

Finalmente, o *performance bond* não deve ser encarado como capaz de endereçar todos os problemas relativos às contratações públicas, mas sim como apenas mais uma peça dentro de todo um arcabouço normativo atualmente em gestação no Congresso Nacional por meio do PL 1.292/1995, o qual, conforme apontado no capítulo final, em relação ao *performance bond*, na redação atual, já realiza consideráveis avanços se comparado com a legislação atualmente em vigor.

6. REFERÊNCIAS

ABD&E – Associação Brasileira de Direito e Economia, Memorial apresentado pela ABD&E na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.655. [s.n.t.]. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/18464/2012_nov_memorial_abde_adi_4655_reg_dif_de_contratacoes.pdf?sequence=1&isAllowed=y; Acesso em 12 de dezembro de 2019.

ADANALI, Y. K. Rational choice theory: its merits and limits in explaining and predicting cultural behaviour. **Erasmus Journal for Philosophy & Economics**, [s. l.], v. 10, n. 1, p. 137–141, 2017. Disponível em: <<https://search.ebscohost.com.sbxproxy.fgv.br/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=124889693&lang=pt-br&site=eds-live>>. Acesso em: 27 jan. 2019.

ADNAN, Hamimah; SUPARDI, Azizan. Legal Analysis on Malaysian Construction Contract: Conditional versus Unconditional Performance Bond. **Journal of Politics and Law**. Vol. 2, n.º 3. Malásia, Setembro, 2009, pp. 25-34.

AFONSO, Marjorie Gressler. **A EFICIÊNCIA DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS: um estudo comparado entre as licitações dos contratos de recuperação, restauração e manutenção rodoviária do DNIT sob o RDC e sob a Lei no 8.666/93**. Trabalho de Conclusão de Curso, sob orientação da professora Patricia Regina Pinheiro Sampaio e co-orientação de Thiago Cardoso Araújo apresentado à FGV DIREITO RIO como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito. 2014. Disponível em:

<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/13895/TCC%20MARJORIE%20GRESSLER%20AFONSO.pdf>. Acesso em 22 de outubro de 2019. ALEXY, Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros. 2008

ALFONSO, Luciano Parejo. **Eficacia y administración: três estudos**. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1995.

ALVES, Murilo Rodrigues; BORGES, André; MERGULHÃO, Alfredo. **Das dez maiores obras do primeiro PAC, apenas duas foram concluídas**. Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-noticia,1824792> (Acesso em 22/05/2019).

ARAGÃO, Alexandre Santos de. O princípio da eficiência. **Revista de Direito Administrativo**, Rio de Janeiro, v. 237, p. 1-6, jul. 2004. Disponível em:

<<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/44361/44784>>. Acesso em: 17 Jan. 2019. Pp. 1; 3

ARAÚJO, Thiago Cardoso. **Análise Econômica do Direito no Brasil. Uma leitura à luz da teoria dos sistemas**. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2017.

ARAÚJO, Thiago Cardoso; MENDONÇA, José Vicente de. **O jardim das veredas que se bifurcam e a Análise Econômica do Direito no Brasil**. A discussão entre Ricardo Lewandowski e Luís Roberto Barroso sobre AED. Disponível em <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-jardim-das-veredas-que-se-bifurcam-e-a-analise-economica-do-direito-no-brasil-04062018> (Acesso em 10/07/2018).

ÁVILA, Humberto. Moralidade, Razoabilidade e eficiência na atividade Administrativa. Revista Eletrônica de Direito do Estado – REDAE. Número 4 – outubro/novembro/dezembro de 2005 – Salvador, Bahia, Brasil.

BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Introduction & Fundamentals. In: **Understanding Regulation. Theory, Strategy, and Practice**. 2a ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.

BANERJEE, Abhijit. DUFLO, Esther. Reputation Effects and the Limits of Contracting: A Study of the Indian Software Industry. **The Quarterly Journal of Economics**, Vol. 115, No. 3, (Aug., 2000), pp. 989-1017 Published by: The MIT Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2586901> (Acesso em 28/04/2018)

BINENBOJM, Gustavo. **Poder de Polícia, Ordenação, Regulação. Transformações político-Jurídicas, Econômicas e Institucionais do Direito Administrativo Ordenador**. Editora Fórum. Belo Horizonte, 2016.

BLANK, Dionis Mauri Penning; BRAUNER, Maria Claudia Crespo. A Responsabilidade Civil Ambiental das Instituições Bancárias pelo Risco Ambiental Produzido por Empresas Financiadas. **Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, v. 22, janeiro a julho de 2009. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/remea/article/view/2827/1597> Acesso em 23 de novembro de 2019.

BRASIL. Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações resultantes da Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994, e da Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998. **Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 jun. 1993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/18666cons.htm (Acesso em 10/07/2018).

_____. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm Acesso em 30 de outubro de 2019.

_____. **Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm; Acesso em 15 de dezembro de 2019.

_____. **Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. Institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC; altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, a legislação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); cria a Secretaria de Aviação Civil, cargos de Ministro de Estado, cargos em comissão e cargos de Controlador de Tráfego Aéreo; autoriza a contratação de controladores de tráfego aéreo temporários; altera as Leis nºs 11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112462.htm; Acesso em 15 de dezembro de 2019.

_____. **Lei nº 6.803, de 2 de julho de 1980. Dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição, e dá outras providências.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6803.htm; Acesso em: 15 de dezembro de 2019.

_____. **Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 16 da Lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências.** Disponível em;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm; Acesso em 15 de dezembro de 2019.

_____. Decreto-lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986. **Dispõe sobre licitações e contratos da Administração Federal e dá outras providências.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2300-86impressao.htm; Acesso em 15 de dezembro de 2019.

_____. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG (2007). **Mapeamento e Análise dos Custos Operacionais dos Processos de Contratação do Governo Federal - Relatório Técnico 12 – Consolidação do Levantamento de Custos.** Disponível em: <https://groups.google.com/group/nelca/attach/384e45db63a7e8/RT%2012%20-%20Levantamento%20de%20custos%20-%20consolida%C3%A7%C3%A3o%20de%20todos%20os%20%C3%B3rg%C3%A3os.pdf?part=0.1> Acesso em 16 de outubro de 2019.

_____. Tribunal de Contas da União. TC 011.196/2018-1. **Diagnóstico das obras paralisadas. Identificação das principais causas e das oportunidades de melhoria. Recomendações. Monitoramento.** Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2019/05/011.196-2018-1-VR-diagnóstico-de-obras-paralisadas.pdf> Acesso em: 17 de outubro de 2019.

_____. Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). **Circular n.º 477 de 30 de setembro de 2013.** Disponível em: <http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=31460> Acesso em: 29 de outubro de 2019.

BRIGLIA, S. J.; ETCHEVERRY, E. The construction defect hot potato: the interplay between the performance bond and CGL policy - a surety's perspective. **Defense Counsel Journal**, [s. l.], n. 1, p. 30, 2010. BURANELLO, Renato Macedo. **Do Contrato de Seguro: O seguro garantia de obrigações contratuais.** Editora Quartier Latin do Brasil. São Paulo, 2006.

DIMITRI, Nicola; PIGA, Gustavo; SPAGNOLO, Giancarlo. Introduction. In: **Handbook of Procurement.** Edited By Nicola Dimitri; Gustavo Piga; Giancarlo Spagnolo. Cambridge University Press. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo. 2006.

CALABRESI, GUIDO; MELAMED, A. DOUGLAS. Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral. **Harvard Law Review**, [s. l.], v. 85, n.

6, p. 1089, 1972. Disponível em: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=edsjsr.10.2307.1340059&lang=pt-br&site=eds-live>>. Acesso em: 11 de outubro de 2019.

CAMPOS, Mariana. **A contumaz inadimplência da Administração Pública e os instrumentos legais à disposição do particular**. Disponível em : <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI212150,31047-A+contumaz+inadimplencia+da+Administracao+Publica+e+os+instrumentos> (acesso em: 28/08/2019).

CARVALHO. Victor Aguiar de. A função regulatória da licitação como instrumento de promoção da concorrência e de outras finalidades públicas. **Fórum de contratação e Gestão Pública – FCGP**, Belo Horizonte, ano 16, n. 186, p. 65-74, jun. 2017.

CARVALHOSA, Modesto. A Corrupção Sistêmica Gerada pelo Capitalismo de Laços – O Instrumento Do Performance Bond. **Revista dos Tribunais**. Vol. 967/2016. Pp. 13 – 19. Maio de 2016.

_____. Combate efetivo à corrupção depende da quebra do capitalismo de laços. **CONJUR**. Publicado em 14 de junho de 2016. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-jun-14/modesto-carvalhosa-combate-corrupcao-ataca-capitalismo-lacos> (Acesso em 22/06/19).

_____. Performance Bonds: Quebra da Interlocação Direta entre Agentes Públicos e Privados na Execução de Contratos Administrativos. In. **Infraestrutura: Eficiência e Ética**. Affonso Celso Pastore (org.). Editora Elsevier, Rio de Janeiro, 2017 [ebook].

CHAVES, Vinicius Figueiredo; SUMAR, Cristina Carvalho. A Responsabilidade Civil Ambiental das Instituições Financeiras. **Revista Estação Científica – Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora**. Edição Especial VII Seminário de Pesquisa da Estácio e III Jornada de Científica da UNESA 2º semestre – 2015. Disponível em: https://portal.estacio.br/media/4622/a_responsabilidade_civil_ambiental_das_instituicoes_financeiras.pdf Acesso em 23 de novembro de 2019.

COASE, R. H. The Problem of Social Cost. **The Journal of Law & Economics**, Vol. 3 (Oct., 1960). The University of Chicago Press for The Booth School of Business, University of Chicago and The University of Chicago Law School. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/724810> (Accessed: 05-03-2018), Pp. 1-44.

COOTER, Robert; ULEN, Thomas. **Direito & Economia**. Porto Alegre. Brokman Companhia Editora. 5ª ed., 2010.

_____._____, **Law and Economics**. 6th edition. 2016. Berkeley Law Books. Disponível em: <https://scholarship.law.berkeley.edu/books/2/>. Acesso em 11 de outubro de 2019

CROLEY, Steven P. Beyond Capture: Towards a new theory of regulation. In: LEVI-FAUR, David. **Handbook on the Politics of Regulation**. Cheltenham, Uk: Edward Elgar Publisher, 2011. Pp. 50-65.

DALBY, Joseph. A Performance Bond, Deconstructed. **Business Law International**. Vol, 11, n.º 2, May, 2010.

DIAS, Maria Tereza Fonseca. **Análise Econômica do Direito nas Contratações Públicas: estudo de casos da legislação e experiência brasileira**. Trabalho apresentado e debatido no “II Congresso Internacional de Compras Públicas: Para um crescimento da Economia Assente na Contratação Pública Sustentável, Inteligente e Inovadora”, promovido pelo Serviço Nacional de Contratação Pública (SNCP) de Angola em colaboração com a Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas de Cabo Verde (ARAP) e a Universidade do Minho, entre os dias 16 a 18 de novembro de 2016, em Luanda.

DORIA, Thaila Renata Teixeira Doria. **Seguro Garantia como Alternativa às Obras Públicas Paralisadas no Brasil**. Dissertação apresentada ao curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento Econômico. Orientador: Prof. Dr. José Guilherme Silva Vieira. Curitiba, 2019.

DWORKIN, Ronald. O Modelo de Regras I. In: DWORKIN, Ronald. **Levando os direitos a sério**. São Paulo: Martins Fontes, 2002. Pp. 23-72.

Estados Unidos da América. **United States Code**. Title 40

FERRARI, Isabela. **Transadministrativismo: Uma teoria dos transplantes jurídicos aplicada ao direito administrativo**. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2018.

FIEDLER, George, The Heard Act and the Miller Act after Fifty Years, 12 Ins. **Counsel J.** 22 (1945) Content downloaded/printed from *HeinOnline* <https://heinonline.org/HOL/Print?collection=journals&handle=hein.journals/defcon12&id=110> (Acesso em 12/07/2018)

FIUZA, Eduardo P. S. (2009). “Licitações e contratos no Brasil: a visão dos economistas.” In: SALGADO, L. H.; FIUZA, E. P. S. (Ed.). **Marcos regulatórios no Brasil: é tempo de rever regras?** Rio de Janeiro: Ipea. 2009.

_____; MEDEIROS, Bernardo Abreu de. **Nota Técnica nº 8. A Reforma da Lei 8.666/93 e do Arcabouço Legal de Compras Públicas no Brasil: contribuições do IPEA à Consulta Pública do Senado**. IPEA. Brasília, outubro de 2013.

FOY, S. L.; SCHLEIFER, C.; TIRYAKIAN, E. A. The Rise of Rational Choice Theory as a Scientific/Intellectual Movement in Sociology. **The American Sociologist**, [s. l.], n. 1, p. 16, 2018. Disponível em: <<https://search.ebscohost.com.sbxproxy.fgv.br/login.aspx?direct=true&db=edsgao&AN=edsgcl.528813966&lang=pt-br&site=eds-live>>. Acesso em: 27 jan. 2019;

FREITAS, Rafael Veras de, **Análise Econômica das Contratações Públicas**. S. N. T. Disponível em: [https://www.compraspublicasbrasil.gov.br/portal/pdf/2018-05-22 - Análise Econômica das Contratações Públicas.pdf](https://www.compraspublicasbrasil.gov.br/portal/pdf/2018-05-22_-_Análise_Economica_das_Contratações_Públicas.pdf); Acesso em 13 de outubro de 2019.

FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL. **Brazil: Detailed Assessment of Observance of Insurance Core Principles of the International Association of Insurance Supervisors**. IMF Country Report n.º 12/334. Washington, D. C. (EUA): International Monetary and Capital Markets Department, 2012. Disponível em: <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Brazil-Detailed-Assessment-of-Observance-of-Insurance-Core-Principles-of-the-International-40168>; Acesso em 29 de novembro de 2019.

GABARDO, Emerson. Princípio da Eficiência. **Enciclopédia Jurídica da PUC-SP. Tomo II (recurso eletrônico) Direito Administrativo e Constitucional**. Coord.: Vidal Serrano Nunes Jr. São Paulo. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017.

GABRIEL, Yasser Reis. O regime diferenciado de contratações: um caso de Institutional Bypass?. **Revista de Direito Público da Economia – RDPE**, Belo Horizonte, ano 13, n. 49, p. 223-246, jan./mar. 2015.

GALIZA, Francisco. **Uma Análise Comparativa do Seguro Garantia de Obras Públicas**. Série Estudos sobre Seguros. Escola Nacional de Seguros. Rio de Janeiro. Novembro de 2015.

GARCIA, Flávio Amaral, **Licitações e Contratos Administrativos: casos e polêmicas**. 4ª edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2016.

GAROUPA, Nuno; PARGENDLER, Mariana. A Law and Economics Perspective on Legal Families. **European Journal of Legal Studies**. 33, 2014, p.54.

GICO Jr. Ivo Teixeira. **Notas Sobre a Análise Econômica do Direito e Epistemologia do Direito**. Trabalho Publicado nos anais do XVIII Congresso

Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo, SP, nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2009. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/sao_paulo/2662.pdf (Acesso em 10/07/2018).

_____. Introdução à Análise Econômica do Direito. In: RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; KLEIN, Vinicius (coord.). **O que é Análise Econômica do Direito: Uma Introdução**. 2ª Edição. Belo Horizonte, Editora Fórum, 2016.

GOMES, Francisco Yokota Choucair. **Análise Econômica do Performance Bond nos Contratos de Obras Públicas**. [s.n.t.] Disponível em: https://www.academia.edu/30388405/AN%C3%81LISE_ECON%C3%94MICA_DA_PERFORMANCE_BOND_NOS_CONTRATOS_DE_OBRAS_P%C3%94BLICAS; Acesso em 27 de novembro de 2019.

HERMES, Felipe. **11 obras públicas inacabadas que não param de sugar dinheiro do seu bolso**. Disponível em: <https://spotniks.com/11-obras-publicas-inacabadas-que-nao-param-de-sugar-dinheiro-do-seu-bolso/> (acesso em 22/05/2019).

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS. Sítio Virtual: <https://www.iaisweb.org/home> Acesso em 29 de novembro de 2019.

JORDÃO, Tarcila Reis. Acordo Tripartite: Enfrentando os desafios de financiabilidade de projetos de concessão e Parcerias Público-Privadas no Brasil. In: **Direito, Instituições e Políticas Públicas. O papel do jusidealista na formação do Estado**. (Coord.) Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho; André Tito da Motta Oliveira; Rafael Hanze Issa. Rafael Wallbach Schwind. Editora Quartier Latin do Brasil. São Paulo, 2017. pp. 403- 428.

KLEIN, Vinicius. Teorema de Coase. In: RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; KLEIN, Vinicius (coord.). **O que é Análise Econômica do Direito: Uma Introdução**. 2ª Edição. Belo Horizonte, Editora Fórum, 2016.

KLOH, Gustavo, Teoria Econômica da Propriedade e dos Contratos” In: **Direito e Economia Diálogos**. (Coord) Armando Castelar Pinheiro; Antônio José Maristrello Porto; Patrícia Regina Pinehiro Sampaio. Rio de Janeiro, FGV Editora, 2019.

KORNHAUSER, LEWIS A.. The New Economic Analysis of Law: Legal Rules as incentives. In: **Law And Economics**. Recent Economic Thought Series. Nicholas Mercuro (org.). Kluwer Academic Publishers. Boston; Dordrecht; London. 1988. pp.27-55

KOROBKIN, Russell. ULEN. Thomas. Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from Law and Economics. **Law and Economics Research Paper Series**. Research Paper N° 00-01. California Law Review, Vol. 88. September, 2000.

LEAL, Fernando. Propostas para uma abordagem teórico-metodológica do dever constitucional de eficiência. **Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico - REDAE**. Salvador, ago./set./out. 2008.

LEMOS, Patrícia Helena Murta. **Custos de Transação dos Contratos Administrativos Celebrados Através da Modalidade Pregão Eletrônico**. S.n.t. Disponível em: <https://www.correios.com.br/sobre-os-correios/a-empresa/revista-de-estudo-de-direito-postal-da-ect/edicao-atual/pdf/2016/artigo6.pdf> Acesso em 16 de outubro de 2019.

MACEDO Jr., Ronaldo Porto. **Contratos Relacionais e Defesa do Consumidor**. 2ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 2007.

MACKAAY, Ejan. **Law and Economics for Civil Law Systems**. Edward Elgar. Massachusetts, USA, 2013.

MANKIW, N. Gregory. **Introdução à Economia**. Tradução da 6ª edição norte-americana. Tradução: Allan Vidigal Hastings; Elisete Paes e Lima; Ez2 Translate. Revisão Técnica Manuel José Nunes Filho. São Paulo. Cengage Learning, 2018.

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Vêras de. **O Futuro das Contratações Públicas. O procedimento licitatório virou “um campeonato de papelada”**. Artigo Publicado no Jota em 12/03/2018. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-futuro-das-contratacoes-publicas-12032018> (Acesso em 17/09/2018).

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 32ª edição. São Paulo: Malheiros. 2015.

MENEZES, Flávio M. Uma Introdução à Teoria dos Leilões. **Revista de Econometria**. Rio de Janeiro, v. 14, nº. 2, Pp. 235-255, novembro 1994/março 1995

MENDONÇA, José Vicente de. **Direito Constitucional Econômico**. 2ª Edição. Belo Horizonte. Editora Fórum, 2018.

MODESTO, Paulo. Notas para um Debate sobre o Princípio Constitucional da Eficiência. **Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico – REDAE**. Bahia. Número 10 – maio/junho/julho, 2007.

MONTEIRO, Alexandre Almeida. **Maldição do Vencedor” (*Winner’S Curse*)? Uma Análise das Ofertas nos Leilões da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).** Monografia de Bacharelado. Orientador: Prof. Ronaldo Fiani. Instituto de Economia. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Março, 2015.

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. **Curso de Direito Administrativo. Parte introdutória, parte geral, parte especial.** 16ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2014.

NÓBREGA, Marcos. Novos Marcos Teóricos em Licitação no Brasil: Olhar para além do sistema jurídico. **Revista Eletrônica de Direito do Estado – REDE.** N.º 30, abril/maio/junho de 2012, Salvador, Brasil.

_____. O Leviatã retroalimentado: quem paga a conta das Cláusulas Exorbitantes? **Revista Direito do Estado.** Ano 2018, n.º 397. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/marcos-nobrega/o-leviata-retroalimentado-quem-paga-a-conta-das-clausulas-exorbitantes>; Acesso em: 15 de dezembro de 2019.

NORTH, Douglas. **Custos de Transação, Instituições e Desempenho Econômico.** Trad. Elizabete Hart. Instituto Liberal, Rio de Janeiro, 1994.

PINAR, Guzel Ozdemir; FUAT, Tanhan; OSMAN Ozdemir. Rational Choice Theory in Psychiatry. **Psikiyatride Guncel Yaklasimler** , Vol 10, Iss 4, Pp 484-495 (2018), [s. l.], n. 4, p. 484, 2018. Disponível em: <<https://search.ebscohost.com.sbxproxy.fgv.br/login.aspx?direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.78c05edce5049e2a226c288edef9bd4&lang=pt-br&site=eds-live>>. Acesso em: 27 de janeiro. 2019.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil: Volume III: Contratos** Revisão e Atualização: Caitlin Mulholland. 23ª edição. Rio de Janeiro. Editora Forense, 2019.

POLETO, Gladimir Adriani **O Seguro Garantia: em busca de sua natureza jurídica.** Série Cadernos de Seguros: teses, v. 8, n.º 17. Fundação Escola Nacional de Seguros (FUNENSEG), Rio de Janeiro, 2003.

POMBO, Bárbara. **Lei Anticorrupção: cinco perguntas para Modesto Carvalhosa.** Disponível em: <https://www.jota.info/livros/lei-anticorruptao-cinco-perguntas-para-modesto-carvalhosa-14032015>. (Acesso em 03/07/2018)

POSNER, Richard A. **Economics Analyses of Law.** 8ª ed. Aspen Publishers, 2010.

_____. The Economic Approach to Law. **Texas Law Review.** 1975, Pp. 757-782.

ROSE-ACKERMAN, S. **Economics of administrative law**. [s.l.] : Cheltenham : Edward Elgar, c2007., 2007.

ROSILHO, André Janjácomo. **As Licitações Segundo a Lei 8.666: um Jogo de Dados viciados?** S.n.t. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2675943/mod_resource/content/1/20120312%20-%20As%20licita%C3%A7%C3%B5es%20segundo%20a%20Lei%208666_um%20jogo%20de%20dad%E2%80%A6%20%282%29.pdf; Acesso em: 12 de dezembro de 2019.

_____. **Qual é o Modelo Legal das Licitações no Brasil? As reformas legislativas federais no sistema de contratações públicas**. Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, como requisito parcial para a obtenção do título de MESTRE no Programa de Mestrado em Direito e Desenvolvimento. Orientador: Prof. Dr. Carlos Ari Sundfeld. São Paulo, 2011. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8824/20111018%20-%20Vers%C3%A3o%20Final%20Disserta%C3%A7%C3%A3o%20%28dep%C3%B3sito%29%20.pdf>. (Acesso em 03/07/2018).

RUDOLPH, Harold W. **Performance Bond Servicing of Government Contracts**, 19 Ins. Counsel J. 171 (1952). Content downloaded/printed from HeinOnline. (Acesso em 02/07/2018).

SANTOS, Altair. **Brasil tem mais de 20 mil obras públicas inacabadas** <https://www.cimentoitambe.com.br/brasil-obras-publicas-inacabadas/> (acesso em 22/05/2019);

SANTOS, Alvacir Correa dos. **Princípio da Eficiência da Administração Pública**. São Paulo: LTR, 2003.

SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. ARAÚJO, Thiago Cardoso. Previsibilidade ou Resiliência? Notas sobre a repartição de riscos em contratos Administrativos. **Revista de Direito da Procuradoria Geral**, Rio de Janeiro, (Edição Especial): Administração Pública, Risco e Segurança Jurídica. 2014, pp. 311-333.

SILVA, Marcos José da. **Economia das Licitações, a Contratação de Obras e Reformas em Prédios Públicos: O caso da UFRGS**. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Economia da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do

título de Mestre em Economia. Orientador: Prof. Dr. Giacomio Balbinotto Neto. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Ciências Econômicas. Porto Alegre, 2018.

SINGER, Eric M. Competitive Public Contracts. **Virginia Law Review**, Vol. 102, No. 5 (September 2016), pp. 1297-1354 (disponível em: <http://www.jstor.org/stable/43923337>). (Acesso em 01/07/2018).

SOUZA, Sergio Ricardo de Magalhães. **Seguro Garantia**. 7ª Edição. Escola Nacional de Seguros, Diretoria de Ensino Técnico. Rio de Janeiro, 2016.

SOUZA, Luciane Moessa de, Responsabilidade Civil de Instituições Financeiras por Danos Socioambientais. **Veredas do Direito**, v. 15, n.º 32. Belo Horizonte, maio/agosto de 2018, pp. 357-396, disponível em: <http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/1302>; Acesso em 24 de novembro de 2019.

STIGLER, George J. The Theory of Economic Regulation. **The Bell Journal of Economics and Management Science**. Vol. 2, nº 1. Rand Corporation. (Spring. 1971), Pp. 3-21

SUMAR, Cristina Carvalho. A Responsabilidade Civil Ambiental das Instituições Financeiras. Revista Estação Científica – Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora. Edição Especial VII Seminário de Pesquisa da Estácio e III Jornada de Científica da UNESA 2º semestre – 2015. Disponível em: https://portal.estacio.br/media/4622/a_responsabilidade_civil_ambiental_das_instituico%C2%B5es_financeiras.pdf Acesso em 23 de novembro de 2019.

TABAK, Benjamin Miranda. **A Análise Econômica do Direito: Proposições Legislativas e Políticas Públicas**. Núcleos de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa. Texto para discussão 157. Outubro de 2014. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td157> Acesso em 05 de novembro de 2019.

THEAN, L. P. The Enforcement of a Performance Bond: The perspective of the underlying contract. **19 Singapore Law Review**. 1998, pp. 389-421.

TULLOCK, Gordon; SELDON, Artur, BRADY, Gordon L. **Government Failure: a primer in public choice**. Catho Institute. Washington, DC. 2005.

ULEN, Thomas S. Um Prêmio Nobel Para Ciência Jurídica: teoria, trabalho empírico e o método científica no estudo do direito. In: PORTO, Antônio José Maristrello,

SAMPAIO, Patrícia. **Direito e Economia em dois mundos: doutrina jurídica e pesquisa empírica**. Editora FGV. Rio de Janeiro, 2014. Pp. 29-93

SCHÄFER, Hasn-Bernd; OTT, Claus. **The Economic Analysis of Civil Law**. Edward Elgar. Massachusetts, USA, 2004.

SCHUBERT, Lynn. The Legal Basics of Surety Bonds. **ABC Construction Executive Magazine**. November, 2003. Disponível em: https://suretyinfo.org/news_room/products/legal_basics.pdf; acesso em 28 de novembro de 2019.

VERAS, Rafael. O que a Análise Econômica do Direito tem a ver com os contratos administrativos? **Revista Eletrônica de Direito do Estado**. Ano 2016. Número 294. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/Rafael-Veras/o-que-a-analise-economica-do-direito-tem-a-ver-com-os-contratos-administrativos>. (Acesso em 10/07/2018).

XAVIER, Vitor Boaventura. **O Seguro Garantia de Execução do Contrato – Performance Bond: Uma Análise dos Aspectos Regulatórios e Concorrenciais da sua Exigência pela Administração Pública no Brasil**. Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília – UnB. Orientadora: Prof.^a Dra. Ana de Oliveira Frazão Vieira de Mello. Brasília, 2017.